

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН

Бр. 2



Ниш, 2011. године

БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ИЗДАВАЧ: Intermex, Београд, Булевар војводе Мишића 37/II
За издавача: Љиљана Миланковић-Васовић, директор

**ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ
УРЕДНИК:** Новица Стефановић,
судија Апелационог суда у Нишу

**ЗАМЕНИК
ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ
УРЕДНИКА:** Владислав Богдановић,
судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКЕ ГРУПЕ
За кривично право: судија Снежана Милошевић - руководиоца групе
судија Вера Милошевић - члан
судија Мирјана Ђорђевић - члан

За грађанско право: судија Зоран Ђорђевић - руководиоца групе
судија Јелена Јовановић - члан
судија Ранко Динић - члан

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Златица Петровић, судијски сарадник

ШТАМПАРИЈА: "CICERO", Београд

СIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
34

БИЛТЕН Апелационог суда у Нишу / главни и
одговорни уредник Новица Стефановић. - бр. 1, 2010-
. - Београд (Булевар војводе Мишића 37/II) : Intermex,
2010- (Београд : "CICERO"). - 22 cm

Три пута годишње. - Је наставак: Билтен судске
праксе - Окружни суд у Нишу = ISSN 1452-6603
ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу -
COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из овог Билтена представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама члана 187. Закона о ауторском и сродним правима, и члана 199. Кривичног законика).

Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

САДРЖАЈ

ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ ЗА 2011. ГОДИНУ	5
ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2011. - 30.09.2011.	11
ПРАВНА СХВАТАЊА	13
СУДСКА ПРАКСА	
<i>ГРАЂАНСКО ПРАВО</i>	<i>27</i>
<i>КРИВИЧНО ПРАВО</i>	<i>51</i>
<i>КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО</i>	<i>81</i>
ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА	
<i>Слободан Стојилковић</i> Методологија и систематика израде првостепене пресуде у кривичном поступку	123
<i>Слађана Стојановић</i> Правична накнада за рад и заштита тог права у судском поступку	130
<i>Слађана Ђуричковић</i> Насиље у породици и мере породичноправне заштите члан 197. и члан 198. ПЗ	148

**ИЗВОД ИЗ ГОДИШЊЕГ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА
АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ
ЗА 2011. ГОДИНУ**

I

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи председник суда.

За заменике председника суда одређују се судије Братислав Крстић и Владислав Богдановић.

Заменицима председника суда, поред општих послова, поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то:

- доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника суда, а које нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда;
- поступање по притужбама и захтевима за изузеће судија;
- поступање по захтевима за давање информација у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
- спровођење и праћење Програма решавања старих предмета.

У случају спречености или одсутности председника суда замењиваће судија Братислав Крстић.

Посебне обавезе поверавају се судији Снежани Милошевић за информисање и контакте с јавношћу и медијима (портпарол).

II

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

За председнике судских одељења одређују се и то:

1. У Одељењу судске праксе: Новица Стефановић, вршилац функције председника суда; за заменике судија Снежана Милошевић и судија Зоран Ђорђевић.
2. У Кривичном одељењу: судија Братислав Крстић, а за заменика судија Снежана Милошевић.
3. У Грађанском одељењу: судија Владислав Богдановић, а за заменика судија Мирослава Миловановић

III

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

1.

I - ВЕЋЕ

1. Вера Милошевић, председник већа
2. Љиљана Миљковић, члан
3. Ранко Банковић, члан

II - ВЕЋЕ

1. Братислав Крстић, председник већа
2. Весна Стевановић, члан
3. Драгана Живадиновић, члан
4. Горана Митић, члан

Ово веће ће примати предмете у поступцима према малолетницима, те ће чинити и веће за малолетнике.

III - ВЕЋЕ

1. Снежана Милошевић, председник већа
2. Слободан Љубић, члан
3. Љубомир Јовановић, члан

IV - ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
2. Зоран Поповић, члан
3. Слободан Стојилковић, члан

Ово веће ће примати предмете у вези кривичних дела против Војске Србије, те ће чинити и веће за предмете против Војске Србије.

Веће за одлучивање у трећем степену биће у сваком конкретном предмету одређено посебно наредбом председника суда.

Председника замењује први члан већа.

Попуна већа до пуног састава вршиће се према посебном распореду који ће месечно утврђивати председник Кривичног одељења.

За руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу одређује се судија Снежана Милошевић, а за заменика судија Вера Милошевић.

Дежурна већа за време годишњих одмора у Кривичном одељењу:

- у јулу месецу - III ВЕЋЕ
- у августу месецу - IV ВЕЋЕ

IV

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I - ВЕЋЕ

1. Владислав Богдановић, председник већа
2. Јасмина Андрејевић, члан
3. Слободанка Китановић, члан

II - ВЕЋЕ

1. Ранко Динић, председник већа
2. Слађана Ђуричковић, члан
3. Љиљана Јовановић, члан

III - ВЕЋЕ

1. Зоран Ђорђевић, председник већа
2. Весна Вукас, члан
3. Тања Ристић, члан

IV - ВЕЋЕ

1. Јелена Јовановић, председник већа
2. Милица Манић, члан
3. Зорица Цветковић, члан

V - ВЕЋЕ

1. Миодраг Марјановић, председник већа
2. Марина Милановић, члан
3. Александар Пантић, члан

VI - ВЕЋЕ

1. Мирослава Миловановић, председник већа
2. Данијела Николић, члан
3. Олгица Спасић, члан

VII - ВЕЋЕ

1. Ивана Рађеновић, председник већа,
2. Љубиша Милојевић, члан
3. Слађана Стојановић, члан

Судије II већа примаће и предмете у вези породичних и статусних спорова, те ће читнити посебно веће за наведене спорове.

Судије III, IV, VI и VII већа примаће предмете у вези радних спорова, те ће чинити посебна већа за наведене спорове.

За руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, одређује се судија Зоран Ђорђевић, а за заменика судија Јелена Јовановић.

Предмети "РЕХ" у зависности од материје расподељиваће се по редоследу пријема у том одељењу.

V

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине судије:

1. Новица Стефановић, вршилац функције председника суда;
2. Братислав Крстић, заменик председника суда и председник Кривичног одељења;
3. Владислав Богдановић, председник Грађанског одељења;
4. Снежана Милошевић, руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу;

Зоран Ђорђевић, руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу.

ИЗВОД ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

Деветомесечни

Редни број	Материја	Број судија у материји	Нерешено на почетку		Примљено		Просечан прилив предмета по судији	Укупно у раду	Укупно решено					Просечно прешено по судији у одељењу	Нерешено на крају	
			Укупно	Старих	Укупно	Нових			Мериторно	На други начин	Укупно решено	Решено спроведеним извршењем	Старих		Остало у раду као нерешено	Старих
1	Кж	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
2	Кж1	13	2003	1539	2743	2557	23.44	4746	1977	14	1991	0	1265	17.02	2755	506
3	Кж2	13	70	22	974	897	8.32	1044	900	20	920	0	48	7.86	124	5
4	Кж3	6	1	0	5	5	0.09	6	0	0	0	0	0	0.00	6	0
5	Кжм	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0		0	0
6	Кжм1	4	10	5	35	32	0.97	45	34	0	34	0	6	0.94	11	0
7	Кжм2	4	1	0	10	9	0.28	11	10	0	10	0	0	0.28	1	0
8	Крм	4	2	1	3	3	0.08	5	2	0	2	0	0	0.06	3	1
9	Гж	15	923	635	1974	1811	14.62	2897	1621	162	1783	0	648	13.21	1114	119
10	Гж1	12	852	523	1962	1838	18.17	2814	1859	91	1950	0	516	18.06	864	98
11	Гж2	6	2	0	297	260	5.50	299	278	5	283	0	6	5.24	16	0
12	Р	20	5	0	33	33	0.18	38	26	6	32	0	1	0.18	6	0
13	Кж1 По1							0			0					
14	Кж2 По1							0								
15	Кр По1							0								
16	Кж1 По2							0								
17	Кж2 По2							0								
18	Кр По2							0								
19	Кр	13	2	0	47	47	0.4017	49	41	8	49	0	0	0.4188	0	0
20	Рех	3	0	0	3	3	0.11	3	2	0	2	0	0	0.07	1	0
21	УКУПНО	34	3871	2725	8086	7495	26.42	11957	6750	306	7056	0	2490	207.53	4901	729

Статистичар,
Милена Рондовић

ЗА ПЕРИОД 01.01.2011. - 30.09.2011.

извештај о раду

Просечно предмета у раду по судији у одељењу		КВАЛИТЕТ											
Укупно	Старих	Разматраних жалби	Потврђено		Преиначено		Укинуто		Делимично преиначено или укинуто		Савладавање прилива	Процент решених	Укупан квалитет
			број	%	број	%	број	%	број	%			%
		0	0		0		0		0				
211.92	38.92	4	0	0.00	2	50.00	2	50.00	0	0.00	72.58	41.95	99.80
9.54	0.38	0	0		0		0		0		94.46	88.12	100.00
1.00	0.00	0	0		0		0		0		0.00	000	
0.00	0.00	0	0		0		0		0				
2.75	0.00	0	0		0		0		0		97.14	75.56	100.00
0.25	0.00	0	0		0		0		0		100.00	90.91	100.00
0.75	0.25	0	0		0		0		0		66.67	40.00	100.00
74.27	7.93	6	5	83.33	0	0.00	1	16.67	0	0.00	90.32	61.55	100.00
72.00	8.17	18	15	83.33	3	16.67	0	0.00	0	0.00	99.39	69.30	100.00
2.67	0.00	8	4	50.00	1	12.50	3	37.50	0	0.00	95.29	94.65	100.00
0.30	0.00	0	0		0		0		0		96.97	84.21	100.00
0.13	0.00	11	11	100.00	0	0	0	0	0	0	104.26	0	0
0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0
144.15	21.44	47	35	74.47	6	12.77	6	12.77	0	0	87.26	59.01	100.00

В.Ф.ПРЕДСЕДНИКАСУДА
Новица Стефановић

ПРАВНА СХВАТАЊА

**КОНАЧНИ ТЕКСТ ПРАВНОГ СХВАТАЊА
О ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ
ПРОУЗРОКОВАНЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ**

Одредбом чл. 377. ЗОО, је прописано да кад је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично дело је предвиђен дужи рок застарелости, захтев за накнаду штете према одговорном лицу застарева кад истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења (став 1.). Прекид кривичног гоњења повлачи за собом и прекид застаревања захтева за накнаду штете (став 2). Исто важи и за застој застаревања (став 3.).

Према томе, оштећени има право да потражује накнаду штете у предвиђеном року сходно чл. 377. ст. 1. ЗОО, везан за застарелост кривичног гоњења, који се може прекидати само по правилима кривичног поступка и то до истека рока за апсолутну застарелост кривичног гоњења. За застарелост потраживања накнаде штете проузроковане кривичним делом није од утицаја правноснажност пресуде и моменат сазнања за коначан обим штете, јер је реч о року застарелости чијим протеком оштећени апсолутно губи право на потраживање накнаде штете.

(Усвојено као правни закључак на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу, одржаној дана 17.06.2011. године а верификовано дана 21.09.2011. године).

**ПРЕКИД ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ
ПРОУЗРОКОВАНЕ КРИВИЧНИМ ДЕЛОМ**

Након увида у коначни текст правног схватања усвојеног на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу одржаној дана 17.06.2011. године, а верификовано дана 21.09.2011. године, у складу са одредбом чл. 23. ст. 3. Судског пословника, достављам издвојено мишљење које се прилаже изворнику.

Покретањем и вођењем кривичног поступка прекида се застарелост потраживања накнаде штете проузроковане кривичним делом. Рок застарелости почиње поново да тече од дана правноснажно-

сти осуђујуће пресуде кривичног суда, а не од дана када је извршено кривично дело, односно од дана настанка штете.

Уколико су постојале процесне сметње због којих је било немогуће да се поступак против учиниоца кривичног дела покрене и оконча (смрт учиниоца, непознат учинилац, потраживање накнаде ратне штете проузроковане припадницима бивше ЈНА), у парници се изузетно, као претходно питање може утврђивати да ли је штета проузрокована таквом радњом која у себи садржи елементе кривичног дела, а привилеговани рок застарелости тече од дана настанка штете, обзиром да до прекида застарелости није ни дошло, јер из објективних разлога није ни могао бити покренут или окончан кривични поступак.

Одредбом чл. 377. ЗОО, прописано је да кад је штета проузрокована кривичним делом, а за кривично гоњење је предвиђен дужи рок застарелости захтев за накнаду штете према одговорном лицу застарева кад истекне време одређено за застарелост кривичног гоњења (став 1). Прекид кривичног гоњења повлачи за собом и прекид застаревања захтева за накнаду (став 2). Исто важи и за застој застаревања (став 3).

У ситуацији кад постојање или непостојање кривичног дела представља једну од чињеничних претпоставки за настанак неког грађанског субјективног права, због чије је заштите покренут парнични поступак, **правноснажна пресуда кривичног суда** директно утиче на чињенични основ одлуке парничног суда и исход парнице, јер представља несумњив доказ о постојању одређене правно релевантне чињенице, за чије постојање правила материјалног грађанског права, везује одређене правне последице.

Такође, одредба чл. 13 Закона о парничном поступку, предвиђа да је суд у погледу постојања кривичног дела и кривичне одговорности учиниоца везан за правноснажну пресуду кривичног суда којом се оптужени оглашава кривим.

а)

Уколико је штета проузрокована кривичним делом, по посебној одредби чл. 377. ст. 1. ЗОО, а у вези чл. 360. и 361. ЗОО, предвиђен је дужи рок застарелости за остваривање потраживања накнаде штете, а то је време одређено за застарелост кривичног гоњења.

Постојање кривичног дела и кривичне одговорности штетника, као **услов** за примену чл. 377. ЗОО, утврђује се само правноснажном осуђујућом пресудом кривичног суда. У супротном, уколико није донета правноснажна осуђујућа пресуда кривичног суда нема места примени чл. 377. ЗОО, јер сумња и постојање обележја кривичног дела нису услови које прописује наведена норма.

Када оштећени у парници захтева накнаду штете, као последицу обележја конкретног кривичног дела, за коју је оптужени-штетник оглашен кривим, тиме су се стекли услови за примену привилегованог рока застарелости.

Одредбом чл. 377. ст. 2. ЗОО, прописано је да прекид застаревања кривичног гоњења **повлачи за собом** и прекид застаревања захтева за накнаду штете.

Прекид застарелости кривичног гоњења регулисан је у одредби чл. 104. ст. 3. Кривичног законика Републике Србије и подразумева предузимање сваке процесне радње у циљу откривања кривичног дела или ради откривања и гоњења учиниоца због учињеног кривичног дела. Одредба чл. 104. ст. 6. истог закона предвиђа да застарелост кривичног гоњења настаје у сваком случају кад протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења.

Стога, **покретањем и вођењем** кривичног поступка (чл. 377. ст. 2.), прекида се застаревање потраживања накнаде штете, јер у том моменту нема основа за примену чл. 377. ЗОО, обзиром да кривично дело и кривична одговорност није утврђена, све до доношења одлуке кривичног суда, што је релевантна чињеница од које зависи примена чл. 377. ЗОО, дејство прекида и поновни ток застарелости.

После прекида, застаревање почиње тећи поново, а време које је протекло пре прекида, не рачуна се у законом одређени рок за застарелост, како предвиђа одредба чл. 392. ст. 1. ЗОО. Доношењем правноснажне пресуде кривичног суда којом је штетеник оглашен кривим за догађај из кога је штета проистекла, застарелост почиње да тече изнова и навршава се кад протекне онолико времена колико је законом одређено за застаревање које је прекинуто, у складу са чл. 392. ст. 6. ЗОО.

Дакле, рок застарелости, услови за примену појединих одредаба којим је регулисана застарелост, прекид и почетак поновног тока застарелости, у парници се цене у складу са одредаба Закона о облигационим односима, а не у складу са правилима кривичног права. Одредба чл. 377. ЗОО одређује привилеговани рок застарелости (ст. 1), као и прекид застарелости захтева за накнаду штете, који се везује само за чињеницу покретања и вођења кривичног поступка (ст. 2), са дејством прекида у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

Осим тога, одредба чл. 104. ст. 6. КЗРС (апсолутна застарелост), не регулише прекид застаревања, већ одређује када настаје застарелост кривичног гоњења, па стога нема основа за аналогну примену наведене одредбе у рачунању рока застарелости потраживања накнаде штете, од дана учињеног кривичног дела односно настанка штете, јер то не произилази ни из циљног, нити из језичког тумачења одредбе чл. 377. ЗОО.

б)

Накнада штете проузроковане кривичним делом може се остварити и истицањем **имовинско правног захтева** у кривичном поступку. То правно средство доводи до прекида застаревања потраживања накнаде штете, па у случају да је оптужба одбијена или је из неког другог разлога који се не тиче суштине ствари окончан кривични поступак и оштећени упућен на парницу, применом чл. 390. ЗОО, сматра се да је наступио условни прекид, уколико оштећени поднесе тужбу за накнаду штете у року од три месеца од дана правноснажности одлуке, јер у тој ситуацији нема услова за примену чл. 377. ЗОО.

в)

Привилеговани рок застарелости потраживања накнаде штете причињене кривичним делом (утврђен правноснажном осуђујућом пресудом) може се применити само у односу на извршиоца кривичног дела.

Међутим, ради заштите права оштећеног на накнаду штете проузроковане кривичним делом, у досадашњој судској пракси изражено је становиште да се у парници као претходно питање може утврђивати да ли је штета проузрокована таквом радњом, која у себи садржи елементе кри-

вичног дела, али само уколико су постојале **процесне сметње** због којих је било немогуће да се против учиниоца кривичног дела поступак покрене и оконча (смрт учиниоца, непознат учинилац, недоступан органима гоњења, **ратна штета** проузроковане припадницима бивше ЈНА, погибија, рањавање и сл.). У таквој ситуацији у складу са одредбом чл. 377. ст. 1. ЗОО, привилеговани рок застарелости тече од дана настанка штете, обзиром да **до прекида застарелости није ни дошло**, јер из објективних разлога није ни могао бити покренут или окончан кривични поступак.

Судија,
Ивана Рађеновић

**СПОРОВИ ПО ТУЖБИ ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА
НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА НА ИМЕ ДУГА
ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ**

(Прекид застарелости)

Основан је приговор застарелости туженог у спору по тужби ЈП за дистрибуцију електричне енергије ради остваривања новчаног потраживања на име дуга за испоручену електричну енергију који се односи на збир свих месечних дуговања за вишегодишњи период, иако је тужени у периоду од годину дана до подношења тужбе вршио једну или више мањих уплата јер оне не прекидају застарелост у смислу чл. 387. ЗОО, не представљају одрицање од застарелости у смислу чл. 365. ЗОО нити признање застареле обавезе у смислу чл. 366. ЗОО обзиром да је обавеза већ застарела у смислу чл. 378. ст. 1. тач. 1. ЗОО, па је у конкретном случају тужени дужан на исплату само незастарелог дуга насталог у периоду од годину дана до подношења тужбе.

Образложење:

Пред Основним судовима је велики број спорова по тужбама ЈП за дистрибуцију електричне енергије због дуга, у којима се тужбеним захтевом тражи исплата износа означеног збиром свих месечних дуговања за вишегодишњи период, а туженици истичу приговор застарелости потраживања.

Првостепени судови одређују извођење доказа вештачењем ради утврђивања висине износа на име незастарелог дуга, за период од годину дана до подношења тужбе, па се испоставља да су тужени у овом периоду извршили једну или више мањих уплата.

Спорно питање је да ли се наведеним уплатама прекида застаривање целокупног дуга на који се односи тужбени захтев. Сматрам да прекида застарелости нема и за своје мишљење истичем следеће разлоге:

Пропис чл. 360. ст. 1. и 2. ЗОО предвиђа да застарелошћу престаје право захтевати испуњење обавезе, а застарелост наступа када протекне законом одређено време у коме је поверилац могао захтевати испуњење обавезе.

Према чл. 361. ст. 1. ЗОО застарелост почиње тећи првог дана после дана када је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе, а наступа када истекне последњи дан законом одређеног времена како то предвиђа чл. 362. ЗОО.

У конкретном случају ради се о приговору застарелости дуга за испоручену електричну енергију. За овакву врсту потраживања, када је у питању домаћинство, рок застарелости износи годину дана како то регулише чл. 378. ст. 1. тачка 1. ЗОО. У оваквим случајевима електрична енергија се континуирано испоручује, а утрошак се мери и вредност обрачунава за сваки месец. Самим тим обавеза плаћања настаје по истеку обрачунског периода тј. од дана достављања рачуна. Ставом два чл. 378. ЗОО предвиђено је да застарелост тече иако су испоруке продужене.

Закључак је да застарелост тече за сваки месец и не може се везивати ни на који начин за протекли период.

Када наступи застарелост наступа последица губљења права захтевати испуњење обавезе.

Пропис чл. 387. ст. 1. ЗОО предвиђа да се застарелост прекида када дужник призна дуг а према ставу 2. признање се може учинити не само изјавом повериоцу него и на посредан начин као што су давање отплате, плаћање камате, давање обезбеђења.

Из изложеног произилази следеће:

О прекиду застарелости може бити говора само за време док застарелост тече, а плаћање се може односити само на дуговање које није застарело. Према томе, ако је дужник нешто платио у периоду док застарелост тече, тј. док није наступила, то се искључиво односи на обавезу која још није застарела. Због тога се не може прихватити гледиште да је оваквим плаћањем наступио прекид застарелости обавезе која је већ застарела.

Када испоручилац електричне енергије поднесе тужбу за дуговање и износ означи збиром свих месечних дуговања па такав збир садржи и застареле обавезе не може се узети да тако добијена сума представља јединствено дуговање те да би се на то применио принцип прекида застарелости плаћањем неке суме јер као што је речено обавеза плаћања постоји за сваки месец, односно за сваку такву месечну обавезу застарелост посебно тече.

Такође се не може говорити ни о признању застареле обавезе јер пропис чл. 365. ЗОО предвиђа да се дужник не може одрећи застарелости пре него што протекне време одређено за застарелост. Доследно томе, за признање застареле обавезе потребно је да буду испуњени посебни услови. Тако пропис чл. 366. ЗОО предвиђа да се писмено признање застареле обавезе сматра као одрицање од застарелости односно исто дејство има давање залоге или ког другог обезбеђења. Значи, не може се сматрати као признање застареле обавезе ако је дужник после истека рока застарелости нешто платио и то у време када постоје текућа потраживања из истог односа јер код застареле обавезе по закону не може да наступи прекид застарелости јер се прекид искључиво односи на оно потраживање које је у току. Према чл. 367. ЗОО последица испуњења застареле обавезе састоји се само у томе што дужник не може да тражи повраћај плаћеног ни по ком основу, па макар и да је био у заблуди.

Обзиром на све наведено несумњиво је да плаћање након што је наступила застарелост обавезе није уопште предвиђено као могућност за било какав прекид застарелости.

Стога произилази да у конкретном случају тужени има обавезу на исплату само незастарелог дуга.

(Правно схватање усвојено на седници Грађанског одељења Апелационог суда у Нишу одржаној дана 30.03.2011. године)

РЕФЕРАТ 1.**ВЕЋА ГРАЂАНСКОГ ОДЕЉЕЊА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ
РАДИ УСВАЈАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ СТАВА О ПОСТУПАЊУ
У СПОРОВИМА ПО ТУЖБИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА НА ИМЕ ДУГА
ЗА ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ**

Јавном предузећу "Електропривреда" законом је поверено вршење јавних овлашћења и оно је основано ради обављања електропривредних делатности које обухватају производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије.

Дистрибуција електричне енергије врши се под условима који су прописани Одлуком о општим условима за испоруку електричне енергије, сада Уредбом и наплата електричне енергије се врши на начин који је прописан наведеним општим условима. Уговори који су закључени у вези са испоруком електричне енергије представљају уговор по приступу.

Поднетим тужбама Електродистрибуција је покренула спор против потрошача ради наплате потраживања, насталог постојањем уговорно претплатничког односа. У парничном поступку Електродистрибуција у својству повериоца тражи да суд наложи потрошачу да испуни његово потраживање исплатом одговарајућег износа за одређени период.

Поступање првостепених судова у оваквој врсти спора састоји се у томе да суд по изјављеном приговору да је потраживање туженог означено у рачуну застарело, одређује извођење доказа вештачењем. Вештаци у свом налазу и мишљењу утврђују висину дуговања купца струје и уколико суд оцени да је приговор застарелости основан, пресудом обавезује туженог да тужиоцу исплати накнаду за утрошену електричну енергију за временски период од 1 године који је претходио подношењу тужбе.

Поводом жалбе тужиоца Привредног друштва за испоруку електричне енергије изјављене против пресуда донетих по тужби наведеног тужиоца поднетој против купаца струје, за остваривање потраживања на име дуга за утрошену електричну енергију, донете су различите другостепене одлуке.

Тако је решењем 1 већа Гж.бр.813/10 од 24.02.2010. године укинута првостепена пресуда те је указано првостепеном суду да је потребно да

употпуни чињенично стање и да потом поново оцени приговор туженог, да је потраживање из тужбе застарело, у складу са одредбом чл. 387. Закона о облигационим односима и у складу са одредбом чл. 392. ст. 1. и 2. истог закона, имајући у виду да сваком учињеном отплатом, рок застарелости почиње тећи изнова, а да се време које је протекло пре прекида не рачуна у законом одређени рок застарелости.

Нема сагласности у поступању у споровима по тужби за остваривање новчаног потраживања на име дуга за испоручену електричну енергију.

Приликом оцене приговора застарелости треба применити одредбе материјалног права и то чл. 360, 378. ст. 1. тач. 1, чл. 387. 388. и чл. 392. ст. 1. и 2. Закона о облигационим односима који говоре о правилу застарелости као институту материјалног права који води престанку облигације и који се базира на протеклу времена.

Застарелост почиње да тече првог дана после дана када је поверилац имао право да захтева испуњење обавезе, односно после дана у коме је дужник био у обавези да испуни чинидбу, а која наступа када истекне последњи дан законом одређеног рока. (чл. 362.).

Потраживање накнаде за испоручену електричну и топлотну енергију застарева за једну годину чл. 378. ст. (1) тач. (1).

Чл. 387. говори о признавању дуга у току трајања рока застарелости. Признањем дуга (1) брише се већ протекло време застарелости и оно почиње изнова у потпуном трајању. Признање може бити учињено непосредно или на посредан начин (2), односно давањем отплате, плаћањем камате, давањем обезбеђења и сл., што води прекиду рока застарелости.

Према чл. 392. (2) застаревање прекинуто признањем од стране дужника, почиње тећи изнова од признања, а према ставу (1) после прекида застаревања почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида не рачуна се у законом одређени рок за застарелост.

Застаревање се прекида подизањем тужбе и сваком другом повериоцевом радњом предузетом против дужника пред судом, ради остварења потраживања (чл. 388.) Признањем дуга прекида се застарелост потраживања у оној мери, односно висини у којој је исто признато.

У односу на предње, став 1. већа Грађанског одељења је, да давањем отплате у оквиру једногодишњег рока застарелости, застарелост се прекида. Застарелост се прекида и подношењем тужбе од стране повериоца. Уколико од учињене отплате до подношења тужбе није протекао рок од једне године, потраживање повериоца није застарело, јер није протекао једногодишњи рок за ову врсту потраживања.

Код оцене да ли је давањем отплате застарелост прекинута има места једино примени правила о прекиду застаревања почев од одредбе чл. 387. закључно са одредбом чл. 393. ЗОО.

СУДСКА ПРАКСА

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ПРАВО СТАНОВАЊА (HABITATIO)

(Члан 194. Породичног закона и члан 3. став 2.
Конвенције о правима детета)

Право становања се може установити и на делу породичне зграде у сувласништву бившег супружника, његове мајке и сестре коју су наследили ако је и после развода брака тужена наставила да их користи заједно са малолетним дететом које јој је поверено на чување, васпитање и издржавање.

Из облазложења:

У току брака трећетужилац и тужена су заједно са малолетним дететом били корисници дела породичне стамбене зграде сувласништва тужилаца коју су мајка, кћи и син наследили од свога претка. После правноснажне пресуде о разводу брака тужена је наставила коришћење дела стамбеног простора са дететом које јој је поверено на чување, васпитање и издржавање. У спору за иселење тужена се позвала на засновано право становања из чл. 194. Породичног закона.

Оцењујући законитост првостепене пресуде о одбијању тужбеног захтева Апелациони суд је закључио да су жалбени наводи неосновани. Тужена нема решено стамбено питање, пресудом јој је мал. дете поверено а тужиоци нису доказали да би то коришћење било очигледна неправда за њих независно од тога што су против тужене покренули кривични поступак за више кривичних дела за која није оглашена кривом нити је поступак окончан, независно од чињенице да је трећетужилац само сувласник, незапослен, из сувласничке куће се самовољно иселио и нашао други стан. Право становања (habitatio) из наведене законске одредбе може се установити и на породичној згради која је сувласничка. Овоме иде у прилог и одредба чл. 3. ст. 2. Конвенције о правима детета која прописује обавезу државе да детету обезбеди такву заштиту и бригу која је неопходна за његову добробит узимајући у обзир права и обавезе његових родитеља који су правно одговорни за дете.

(Из пресуде Апелационог суда Ниш Гж.41/11 од 25.01.2011. године)

Приредио: Ранко Динић,
судија Апелационог суда у Нишу

**ПОТПУНО ЛИШАВАЊЕ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА
ОСИМ ДУЖНОСТИ ИЗДРЖАВАЊА МАЛОЛЕТНЕ ДЕЦЕ**
(Члан 81. став 3. Породичног закона)

За одлуку о потпуном лишењу родитељског права над малолетном децом неопходно је утврдити присуство озбиљних разлога који доводе у сумњу подобност родитеља за правилно чување, васпитање и издржавање деце.

Из објасњења:

У поступку је утврђено да је отац често физички кажњавао чланове своје породице, страхом уређивао односе у породици супруге и троје малолетне деце, старију децу присиљавао да обављају одређене физичке послове недостојне њиховом узрасту и утицао на њихов емоционални развој и правноснажно осуђен због насиља у породици. Мајка то није успевала да надомести већ је временом постајала пасивнија и јуна 2008. године отишла од куће у непознатом правцу а вратила се интервенцијом полиције фебруара 2009. године када је константовано да је психички оболела, па су деца смештена у хранитељску породицу, обоје родитеља потпуно лишено родитељског права и обавезани да плаћају издржавање у одређеним износима, па су правилно примењене одредбе чл. 81. ст. 3. и 162. Породичног закона.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж2. бр. 187/10 од 13.07.2010. године)

Приредио: Ранко Динић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПОВЕРАВАЊЕ ДЕТЕТА
(Члан 266. став 1. Породичног закона)

У спору за заштиту права детета и вршење родитељског права суд је увек дужан да се руководи најбољим интересом детета, а у случају постојања противуречности мишљења вештака појединца и Центра за социјални рад, ако не дође до усаглашавања, потребно је

прибављање мишљења установе из области заштите менталног здравља и психијатрије развојног доба одговарајућег клиничког центра.

Из објасњења:

Пресудом о разводу брака мал. син странака рођен 2003. године поверен је туженом на чување, негу и васпитање а тужила обавезана да плаћа издржавање у одређеном износу. Одлука је заснована на налазу и мишљењу вештака појединца (психолога) који је супротан Мишљењу Центра за социјални рад које је образложено да отац не препознаје најбољи интерес детета, да дете није адекватно заштићено у делу његовог права да остварује контакте са мајком са којом актуелно не живи и да очево понашање не може послужити као добар модел због губљења контроле у испољавању беса. Пре опредељења за мишљење коме треба поверити дете првостепени суд није покушао усаглашавање налаза и мишљења према одредбама чл. 259. ст. 2. и 3. ЗПП, нити вештачење поверавао другој установи, па је пресуда укинута.

(Из пресуде Апелационог суда Ниш Гж2.бр. 199/10 од 17.8.2010. године)

Приредио: Ранко Динић,
судија Апелационог суда у Нишу.

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ИЗДРЖАВАЊУ
(Члан 164. Породичног закона)

Одлука о висини издржавања може бити промењена само уколико је дошло до промене релевантних околности на основу којих је донета претходна одлука.

Из објасњења:

Према утврђеном чињеничком стању, тужила је правоснажном пресудом обавезана да доприноси издржавању тада мал. деце – тужених са износима од по 8.000,00 динара месечно, почев од 17.08.2005. године па у будуће док за то постоје законски услови. У то време тужила је са другим супругом живела у Швајцарској где је обављањем повремених по-

слова остваривала зараду од 300 до 400 франака месечно. У другом браку је родила друго дете 13.03.2007. године, а по рођењу детета се развела и вратила у Србију где и сада живи у изнајмљеном стану. Запослена је у једној трговинској радњи са месечном зарадом од 16.000,00 динара, без своје имовине, а за закуп стана издваја износ од 100 евра месечно. Њен супруг је из другог брака обавезан да на име доприноса за издржавање мал. детета плаћа 670 швајцарских франака и за издржавање тужиље 110 швајцарских франака, али како не извршава своју обавезу против њега се води кривични поступак због кривичног дела неплаћања алиментације. Тужена је студент треће године приватног правног факултета, где за упис године издваја 1200 евра. Тужени је редован студент факултета за спорт и физичко образовање. Они плаћају закуп стана у Нишу у износу од 150 евра, а њихове укупне месечне потребе су 400 евра. Отац тужених је незапослен, живи у сеоском домаћинству са својим родитељима и бави се пољопривредом од које остварује зараду за своје издржавање и издржавање деце.

На основу утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је изменио претходну одлуку о висини издржавања, одређујући исту у износу од по 20% од личног дохода који остварује, за сваког туженог понаособ. Апелациони суд је преиначио првостепену пресуду и одбио тужбени захтев. Врховни Касациони суд је прихватио правно становиште првостепеног суда и ревизију тужиље одбио као неосновану.

На страни тужиље има промењених околности јер је у међувремену родила још једно дете према коме има обавезу издржавања, развела је други брак и вратила се из Швајцарске у Алексинац, где са мал. дететом живи у изнајмљеном стану и где је засновала радни однос. Међутим, и потребе тужених су се временом повећале јер су сада старији, обоје су студенти, а у време доношења претходне пресуде били су ученици средњих школа. Тужилца је остварила право на деџе и супружничко издржавање од бившег супруга и према годинама живота и здравственом стању у могућности је да стиче зараду и да додатним радом доприноси издржавању тужених који су на редовном школовању. Због тога нису испуњени услови из чл. 164. Породичног закона за измену претходне пресуде о издржавању. Поред наведеног, тужени као повериоци издржавања имају право избора да ли ће се издржавање плаћати у фиксном месечном износу или у проценту од редовних месечних примања дужника издржавања. Према чл.

162. ст. 1. Породичног закона, па обавеза тужиље није могла бити одређена у проценту јер су тужени тражили фиксни месечни износ.

Иако су потребе тужених веће, обзиром на остале околности на страни тужиље, није основан ни њихов захтев за повећање издржавања на износ од по 10.000,00 динара месечно, па је првостепени суд правилно одлучио када је одбио противтужбени захтев.

(Пресуда Основног суда у Нишу – Судска јединица у Алексинцу I-30 П2. 291/10 од 08.03.2010. године, пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2. 131/10 од 20.05.2010. године и пресуда Врховног Касационог суда рев. 3355/10 од 04.11.2010. године)

Приредила: судија Данијела Николић

ПРЕСТАНАК ИЗДРЖАВАЊА

(Члан 167. став 1. тачка 1. и став 2, члан 155. став 2. Породичног закона)

Нису испуњени услови за укидање издржавања пунолетног детета које се налази на редовном школовању, а није навршило 26 година живота, иако је факултет уписало две године након завршетка средње школе.

Из обласложења:

Тужилац је правоснажном пресудом обавезан да доприноси издржавању туженог као свог сина са 30% од својих редовних месечних примања. Он је сада пензионер и прима пензију у износу од 30.000,00 динара месечно, живи у стану своје мајке, а нема друге имовине ни обавезу издржавања према трећим лицима. Тужени је рођен 01.08.1988. године и живи у заједничком домаћинству са мајком која је власник приватног предузећа у чијем саставу се налазе две продавнице и месечно остварује зараду од око 40.000,00 динара. Редован је студент на филозофском факултету Универзитета у Нишу у школској 2009/2010 години у статусу самофинансирајућег студента. Није био запослен и није пријављен на евиденцији за незапослене.

Код оваквог чињеничног стања, Апелациони суд је нашао да нису основани жалбени наводи тужиоца, да првостепени суд није ценио чињеницу да тужени после завршене средње школе није наставио одмах са редовним школовањем већ је факултет уписао након подношења тужбе за укидање издржавања и то две године после завршетка средње школе, у ком периоду је радио и остваривао приходе за сопствено издржавање, због чега је одбио као неосновану жалбу тужиоца и потврдио првостепену пресуду којом је одбијен тужбени захтев за укидање издржавања. Врховни Касациони суд је ревизију тужиоца оценио неоснованом и потврдио пресуду Апелационог суда.

Пунолетно дете има право на издржавање од родитеља било да се само финансира или је финансирано из буџета све до завршетка редовног школовања а најкасније до навршене 26 године живота, у смислу чл.155. ст. 2. Породичног закона РС. Сходно томе, неосновани су жалбени наводи тужиоца да се једном изгубљено правно на издржавање не може поново остварити, јер се издржавање одређује за време трајања редовног школовања а најкасније до навршене 26-те године живота. Није од утицаја ни чињеница да је тужени након завршетка средње школе једно време остварио зараду сопственим радом. Дужност родитеља да даје издржавање пунолетном детету у периоду између два степена образовања, конкретно између средњег и високог, зависи у којој мери је пунолетно дете у могућности да покрије своје животне потребе п приходима од своје имовине или рада, у границама своје радне способности за време између два степена школовања, односно могућности за запослење, здравственог стања и других околности од којих зависи одлука о издржавању пунолетног детета у том периоду. Тужени је у том периоду остваривао приходе повременим радом, који нису били довољни за његово издржавање, те стога стоји обавеза тужиоца, као оца, да му у том периоду плаћа издржавање.

(Пресуда Општинског суда у Алексинцу П. 125/09 и П. 501/09 од 30.09.2009. године, пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2. 65/10 од 04.03.2010. године, пресуда Врховног Касационог суда рев. 3356/10 од 04.11.2010. године)

Приредила: судија Данијела Николић

**ИЗДРЖАВАЊЕ ПУНОЛЕТНОГ ДЕТЕТА
КОЈЕ СЕ РЕДОВНО ШКОЛУЈЕ**
(Чл. 155. ст. 2. и 4. Породичног закона)

Родитељи су након стицања пунолетства дужни да издржавају своје дете које се редовно школује и њихова обавеза траје до истека времена трајања школовања у одговарајућој школи односно факултету, а у сваком случају престаје када дете наврши 26 година живота.

Из обласложења:

Првостепени суд је правилно и потпуно утврдио чињенично стање, да је тужилац као отац тужене правоснажном пресудом обавезан да на име свог доприноса у њеном издржавању плаћа 22% месечно од своје месечне зараде коју остварује у Предузећу "ПИК" на Алексиначком руднику, а у случају да не остварује стална месечна новчана примања од износа минималне зараде у Републици за претходни месец почев од 01.06.2001. године. Тужилац је 2001. године засновао нови брак из кога има малолетну ћерку рођену 1999. године. Са супругом и том ћерком живи у Делиграду, у теткиној кући са којом има закључен Уговор о доживотном издржавању чији је предмет кућа и пољопривредно имање од 1,5ха. Тужилац је бившој супрузи са којом живи и тужена поравнањем о деоби имовине стечене у браку, оставио плац и кућу у Корману. Тужилац остварује пензију од 45.000,00 динара месечно и других прихода нема, а здравље му је нарушено. Тужена има 25 година, живи са мајком која је незапослена и апсолвент је на Вишој техничкој школи у Нишу који је уписала школске 2004/2005 године на буџету. Школске 2009/2010 године обновила је апсолвентски стаж. Студије на овој школи трају 3 године, а просечно студирање 5 година. Последњи испит положила је 16.04.2010. године као самофинансирајући студент и до краја студија има још 3 испита и дипломски испит.

Код овако утврђеног чињеничног стања, погрешно је првостепени суд применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца и укинуо издржавање туженој, налазећи да је неоправдано продужила школовање, због чега је Апелациони суд преиначио првостепену пресуду и одбио тужбени захтев. Врховни Касациони суд је одбио као неосновану ревизију тужиоца и потврдио пресуду Апелационог суда.

Одредбом чл. 155. ст. 2. и 4. Породичног закона предвиђено је да пунолетно дете које се редовно школује има право на издржавање од родитеља сразмерно њиховим могућностима а најкасније до навршене 26 године живота, с тим да нема право на издржавање ако би прихватање његовог захтева представљало очигледну неправду за родитеље односно друге крвне сроднике. Сходно овој законској одредби, један од услова за остваривање права на издржавање пунолетног детета је да се оно налази на редовном школовању што подразумева да редовно извршава школске обавезе, полаже испите и уписује наредне школске године, при чему није од утицаја да ли се ради о студенту који се финансира из буџета или је самофинансирајући. У конкретном случају, просечно трајање студија на овој школи је 5 година, па се студирања тужене креће у границама просека. Тужена се налази при крају школовања (остала су јој још 3 испита и дипломски испит) па се не може закључити да је запоставила своје обавезе у вези школовања. Не стоје ни разлози због којих би давање издржавања од стране тужиоца представљало очигледну неправду за њега, јер тужилац остварује пензију, стамбено је ситуиран а мајка тужене не ради и њих две не остварују приходе па се издржавају од помоћи рођака.

(Пресуда Основног суда у Нишу – Судске јединице у Алексинцу I-30 П2. 690/10 од 01.06.2010. године, пресуда Апелационог суда у Нишу Гж2. 196/10 од 23.07.2010. године, пресуда Врховног Касационог суда Рев. 3461/10 од 22.12.2010. године)

Приредила: судија Данијела Николић

**ОДГОВОРНОСТ ДРЖАВЕ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ
ПРИЧИЊЕНУ ТЕШКИМ ТЕЛЕСНИМ
ПОВРЕЂИВАЊЕМ ЗАТВОРЕНИКА
(Члан 180. ст. 1. и 3. и члан 200. ЗОО)**

Држава је одговорна за нематеријалну штету коју затвореник претрпи у просторијама КПЗ у току издржавања казне затвора проузроковане активношћу другог затвореника по принципу објективне одговорности.

Из објасњења:

Тужилац је као затвореник за време издржавања казне тешко телесно повређен од другог затвореника тако што му је оптужени у просторијама павилјона, док је седео у ТВ сали, неприметно пришао с леђа и из позиције леве бочне стране задао му три удараца ручно прављеним боджом (шилом) и то један у пределу предњег трбушног зида, други у пределу шестог и седмог међуребарног простора и трећи са задње стране које су тешке и по живот опасне повреде. Правноснажном пресудом оптужени је оглашен кривим и осуђен на временску казну. У поступку по тужби за нематеријалну штету против државе тужена оспорава правни основ за накнаду штете јер сматра да је ову причинио други затвореник тако да евентуално може да има места подељеној одговорности са штетником. Овакво правно становиште другостепени суд сматра неприхватљивим јер се подељена одговорност не може односити на треће лице већ евентуално може бити речи о солидарној одговорности државе и штетника и то прве по основу објективне одговорности и другог по основу кривице. Како сваки дужник солидарне обавезе одговара повериоцу за целу обавезу, то је оштећени као поверилац у смислу чл. 414. ЗОО могао захтевати испуњење обавезе од кога хоће све док накнада штете не буде потпуно испуњена а држава може да захтева регрес од лица које је штету проузроковало у смислу чл. 180. ст. 3. ЗОО.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 4. Гж. 934/11 од 14.06.2011. године)

Приредио: Ранко Динић,
судија Апелационог суда у Нишу

СТИЦАЊЕ ВЛАСНИШТВА НА СТАНУ ПРЕДУГОВОРОМ

(Члан 45. ст. 4. и 5. ЗОО и члан 20. ЗОСПО)

Предуговором се преузима уговорна обавеза да се касније закључи главни уговор са утврђеним битним елементима па из предуговора не настаје и обеза испуњења одређене обавезе главног уговора.

Из објасњења:

Тужиоци су као купци са туженим као продавцем, закључивали предуговоре о купопродаји станова у изградњи по систему "кључ у руке" са ознакама броја стана, спрата, површине, цене, рокова, исплате и предаје стана. По предуговорима су поједини купци у целости извршили своје уговорне обавезе исплатом уговорене цене док је друга уговорна страна само грубо озидала станове и то зидове, међуспратне плоче и димњаке и уградила прозоре и врата без довршавања станова и прибављања употребне дозволе. Првостепеном пресудом је утврђено право својине на становима у изградњи и туженом наложено да то призна и омогући упис у јавне књиге. У поступку по жалбама је првостепена пресуда преиначена. Одредбе чл. 45. ст. 4. и 5. ЗОО дају овлашћење заинтересованој страни да од суда тражи налагање обавезе другој страни да приступи закључењу главног уговора у року од 6 месеци од истека рока предвиђеног за закључење, а ако није предвиђен онда од дана када је према природи посла и околностима, уговор требао бити закључен. Међутим, тужиоци то нису тражили па по налагању Апелационог суда предуговором не настаје обавеза на испуњење одређене чинидбе односно неке обавезе из главног уговора, већ једино на закључење главног уговора и кад буде закључен, настаје обавеза испуњења чинидбе која је предмет споразума.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 4. Гж. 792/11 од 16.05.2011. године)

Приредио: Ранко Динић,
судија Апелационог суда у Нишу

ИЗМЕНА УГОВОРЕНИХ УСЛОВА РАДА

(Члан 171. Закона о раду)

Чињеница да је тужилац премештен на послове који одговарају његовој врсти и степену стручне спреме, по аутоматизму не подразумева да су испуњени услови прописани одредбом чл. 171. и 172. Закона о раду, јер запослени треба да зна због чега је послодавац покренуо поступак премештаја и да ли су разлози за понуду субјективне или објективне природе.

Из објасњења:

Правилно је становиште првостепеног суда у оцени испуњености услова за примену чл. 171. Закона о раду, да предстојеће организационе промене код послодавца не могу бити разлог за премештај запосленог, јер се ради о будућој и неизвесној чињеници у време давања понуде и заправо разлога који још није наступио.

Чињеница да је тужилац премештен на послове који одговарају његовој врсти и степену стручне спреме, по аутоматизму не подразумева да су испуњени услови прописани наведеном одредбом и да је премештај био законит, уколико разлози нису наступили и уколико у понуди разлози нису јасно и прецизно изнети, из којих разлога нису основани наводи жалбе.

Наиме, премештај запосленог код истог послодавца може да уследи због потреба које се јављају при увођењу нових, односно укидању старих послова, услед статусних или организационих промена, размештају запослених зависно од њихових способности, примени мера за унапређење рада и радних поступака, отклањању узрока застоја у раду, лоших односа међу запосленима или увођења мера за боље функционисање делова система рада и у другим ситуацијама.

Тужени у току поступка пред првостепеним судом није доказао да је фактички постојао било који разлог за премештај запосленог у време учињене понуде и у време закључења анекса, не само у погледу статусних и организационих промена, јер је до измене правилника дошло након вишемесечног периода, већ и у погледу евентуалних радних способности тужиоца или мана у функционисању радног процеса и у чему се састоје евентуално недостаци у комуникацији учесника тог процеса, као узрочно последичне везе потребе послодавца да понуди анекс уговора, јер запослени треба да зна због чега је послодавац покренуо поступак премештаја и да ли су разлози субјективне или објективне природе, што је у конкретном случају изостало.

Осим тога, одредбом чл. 48. Закона о раду ("Службени гласник РС" број 24/05, 61/05) прописано је да директор може да заснује радни однос на одређено или неодређено време, да се заснива уговором о раду, а радни однос на одређено време може да траје до истека рока на који је изабран директор, односно до његовог разрешења.

У конкретном случају из списка предмета произилази да је тужилац по одлуци о избору кандидата од 30.05.2006. године постављен за директора филијале у Прокупљу на основу решења од 23.06.2006. године и то на период од 5 година, а у складу са чл. 278. Закона о раду, закључен је уговор од 27.12.2007 године. Међутим, у конкретном случају како произилази из чињеничног основа мандат тужиоцу на пословима директора филијале није истекао, нити се указује на постојање услова и разлога за разрешење, те да је покретан и вођен евентуално поступак разрешења. У случају истека мандата или разрешења из одређених разлога и уколико се ради о запосленом који је у радном односу на неодређено време, послодавац би имао обавезу да понуди и анексом уговора о раду регулише радно-правни статус запосленог, ради обављања других одговарајућих послова у смислу чл. 172. Закона о раду. Међутим како се у конкретном случају не ради о анексу уговора који је последица истека мандата или разрешења, то је правилан закључак првостепеног суда да је анекс уговора о раду који су тужени и тужилац закључили 27.12.2007. године ништав, услед пропуста туженог да у понуди искаже конкретне разлоге премештаја субјективне или објективне природе, нити је тужени доказао да је постојао фактички разлог за премештај.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1.2852/10 од 04.02.2011. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

**ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
КОД ПОСЛОДАВЦА
(Члан 254. Закона о раду)**

Ништав је колективни уговор закључен између послодавца и једног од репрезентативних синдиката, уколико није постигнута сагласност воља свих учесника који су имали преговарачку легитимацију, односно уколико и други репрезентативни синдикат који је учесник у колективном преговарању није дао сагласност. Колективни уговор код послодавца не доноси се изгласавањем, него се закључује

у поступку преговарања, као продукт усаглашавања и компромиса учесника у закључивању колективног уговора о садржини и обиму међусобних права, обавеза и одговорности из радног односа.

Из облажложења:

Одредбом чл. 263. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05) прописано је да се колективни уговор закључује на период од 3 године, а одредбом чл. 264. истог закона, предвиђено је да важење колективног уговора, пре истека рока из чл. 263. може да престане споразумом свих учесника или отказом на начин утврђен тим уговором, а у случају отказа колективни уговор се примењује најдуже 6 месеци од дана подношења отказа, с тим што су учесници дужни да поступак преговарања започну најкасније у року од 15 дана од дана подношења отказа.

Колективни уговор закључен дана 02.10.2006. године потписан је од стране првотуженог као послодаваца и два репрезентативна синдиката, првотужиоца и друготуженика. Наведени колективни уговор отказао је послодавац, изјавом у писменом облику, актом од 18.10.2007. године, који је достављен осталим уговарачима, дакле репрезентативним синдикатима, од када отказ дејствује, што није спорно међу странкама. За учеснике отказаног колективног уговора, настала је обавеза да преговарају о закључењу новог колективног уговора и та обавеза траје док траје и отказни рок. Преговори су започети 30.10.2007. године, дакле у року од 15 дана од дана достављања отказа.

Одредбом чл. 254. Закона о раду, предвиђено је да су учесници у закључивању колективног уговора, дужни да преговарају, јер је колективни уговор као и сваки други уговор производ сагласности воља оних који га закључују. Пошто се до те сагласности може доћи једино споразумевањем, закон не прописује дужност закључивања колективног уговора, већ обавезу преговарања, јер како ће процес преговарања тећи и како ће бити окончан, зависи од учесника и успешности, односно неуспешности преговарања, из којих разлога у том делу нису основани наводи жалбе. Колективни уговор је увек продукт компромиса у којем преговарачи у тимовима износе и заступају становишта учесника у закључивању колективног уговора, а у случају да се не постигне договор постоји могућност образовања арбитраже за решавање спорних питања у смислу ст. 2. одредбе чл. 254. или судског решавања у смислу чл. 265. ст. 4. Закона о раду и чл. 18. Закона о мирном решавању колективних спорова.

Када се у току преговора не постигне сагласност за закључивање колективног уговора у року од 45 дана од дана започињања преговора, учесници могу да образују арбитражу за решавање спорних питања, што подразумева дакле могућност, а не обавезу, те уколико до истека напред наведеног рока не образују арбитражу, губе правну моћ да то учине, па им преостаје да спор реше на други начин, уз обавезу преговарања док траје отказни рок, јер протеком отказног рока престаје важење колективног уговора, као последица неуспелог преговарања.

Наиме, у процесу колективног преговарања, треба да се исказе воља и спремност на компромис и социјални партнери треба да ускладе противречне интересе и колективним уговором регулишу, односно изнова уреде међусобна права, обавезе и одговорности из радног односа. Међутим, међу уговарачима долази до несагласности у погледу садржине и обима појединих колективних права, установљених колективним уговором и когентним равноправним нормама и управо из тих разлога, треба да наставе процес преговарања, до потпуног усаглашавања односно постизања сагласности свих учесника.

Дакле, колективни уговор као општи акт у поступку доношења и преговарања, не доноси се изгласавањем, него се закључује у поступку преговарања, а за његово закључење није довољна само сагласност воља учесника, већ је потребно да оно што је било предмет усаглашавања, изрази се и у писменој форми.

Стога, нису основани наводи жалбе којима се указује на то да преговори нису текли успешно ни аргументовано од стране тужиоца. Како наведене законске одредбе не предвиђају дужност и обавезу закључења колективног уговора, већ само обавезу преговарања, то овај суд налази да је правилан закључак првостепеног суда, да је ништав колективни уговор од 19.02.2008. године, закључен између првотуженика, као послодавца и друготуженика, као једног од репрезентативних синдиката, обзиром да није постигнута сагласност свих учесника колективног преговарања, па самим тим није ни могао да произведе дејство, без обзира на то што је постигнута сагласност само појединих учесника у колективном преговарању.

Одредбом чл. 262. Закона о раду прописано је да колективни уговор код послодавца обавезује и оне запослене који нису чланови синдиката, потписника колективног уговора. Колективни уговор закључује се на

нивоу конкретне радне средине и њега закључују синдикати код послодавца који су репрезентативни, али у тренутку када је постигнута сагласност свих репрезентативних синдиката и послодавца и када колективни уговор буде објављен, одредбе тог уговора, као општег акта, примењују се и на запослене који нису чланови ни једног синдиката или су чланови неког другог синдиката, који није репрезентативан, дакле обавезује све запослене код послодавца.

Стога, нису основани наводи жалбе којима се указује на то да је било довољно, да само један од репрезентативних синдиката закључи колективни уговор са послодавцем у случају да други репрезентативни синдикат, који је учествовао у колективном преговарању није дао сагласност.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 854/10 од 26.03.2010. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

**НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ
ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА**
(Члан 191. став 2. Закона о раду)

Штета коју неко претрпи може бити последица не само туђег него и властитог понашања у случају када оштећени својим поступцима омогући другоме да му штету проузрокује или допринесе да буде већа него што би иначе била сходно чл. 192. ЗОО. Кривица оштећеног у смислу грађанско правне одговорности може бити разлог за искључење или умањење одговорности починиоца штете у зависности од удела једне и друге стране у проузроковању штете, јер штета може настати и радњом која није кривично дело.

Из објасњења:

За одлучивање о праву на накнаду штете због незаконитог отказа од значаја су околности и чињенице у погледу разлога због којих је дошло до престанка радног односа, као и разлога због којих је утврђена његова незаконитост, јер одсуство услова који се тиче узрочне везе између штетне рад-

ње-незаконитог отказа и штете, због околности која ту везу прекида, утичу на грађанско правну одговорности и остваривања права на накнаду.

Штета коју неко претрпи може бити последица не само туђег него и властитог понашања у случају кад оштећени својим поступцима омогући другоме да му штету проузрокује или допринесе да буде већа него што би иначе била сходно чл. 192. ЗОО. Кривица оштећеног, у смислу грађанско правне одговорности, може бити разлог за искључење или умањење одговорности починиоца штете у зависности од удела једне и друге стране у проузроковању штете, јер штета може настати и радњом која није кривично дело.

Стога становиште првостепеног суда да тиме што тужиоцу радни однос није ни престао због повреде радне обавезе или услед акта недисциплине, већ из разлога прописних у чл. 179. ст. 1. тач. 4. Закона о раду, те да није доказано да је тужилац учинио кривично дело на раду или у вези са радом, из којих разлога налази да тужбени захтев није основан, за сада се не може прихватити.

Имајући у виду изнете примедбе, првостепени суд је потребно да сходно чл. 220. и 221. ЗПП одлучи о свим предлозима за извођење доказа, а затим оценом доказа и на основу резултата целокупног поступка, сходно чл. 8. и 223. ЗПП, утврди основ и услове одговорности послодавца за настану штету и с тим у вези да ли постоје околности које прекидају узрочно-последичну везу између незаконитог акта о престанку радног односа и штете, те да ли је тужилац савесно поступао или је својом радњом или пропуштањем створио услове за настанак штете, па ће правилном применом материјалног права ценити да ли је послодавац одговоран да тужиоцу накнади штету или су се стекли услови за примену чл. 192. ЗОО, односно услови за искључење одговорности, дајући разлоге за свој закључак о основаности тужбеног захтева.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1.1812/11 од 16.09.2011. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда

**ПОВРЕДА РАДНЕ ОБАВЕЗЕ ЗБОГ НЕОВЛАШЋЕНОГ
САОПШТАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ПОДАТАКА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈЕ, ПЕРСОНАЛНЕ
И ДРУГЕ ПРИРОДЕ**

(Члан 179. став 1. тачка 2. Закона о раду)

Коришћење података и информација до којих запослени долази у току рада са кредитним бироом, супротно одредбама Закона о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/08), дакле без сагласности клијента и неовлашћено коришћење тих података и омогућавање да подаци буду доступни трећим неовлашћеним лицима, представља повреду радне обавезе, због које запосленом може престати радни однос.

Из објасњења:

Одредбом чл. 15. Уговора о регулисању међусобних права и обавеза на пословима прикупљања и коришћења података о клијентима банака, прописано је да се уговорне стране обавезују да своје запослене задужене за доставу, обраду, чување, коришћење или размену података, упознају са одредбама овог уговора и оперативним правилима које се односе на обавезу чувања, као пословне тајне, свих података и информација из домена њиховог рада под претњом санкција утврђених законом и правилима рада кредитног бироа, уколико радник достави нетачне податке или их достави неовлашћеном кориснику, а знао је или је морао знати да су нетачни, односно да је у питању неовлашћено лице. Чл. 9. Уговора прописано је да податке у оквиру инфраструктуре кредитног бироа, кредитни биро може употребити за формирање извештаја тек по добијању сагласности клијента банке, приликом његовог првог подношења захтева за коришћење услуге код било које банке.

У складу са напред наведеним уговором тужиља је дана 21.07.2007. године потписала изјаву која је дата у циљу заштите од неовлашћеног коришћења података и информација до којих долази у току рада са кредитним бироом, чиме јој је указано на значај поверљивости података и релевантност у заштити података и личности на које се ти подаци односе, као и немогућност да свако има приступ тим подацима.

Предајом и пријемом "Смарт картице" са дигиталним сертификатом која гласи на њено име, радна обавеза у поступању и начину коришћења кар-

тице је јасно дефинисна, дакле преузета је обавеза да ће наведену картицу користити у раду са кредитним бироом у складу са Законом о заштити података о личности, на начин предвиђен чл. 15. напред наведеног уговора, а у вези прикупљања и коришћења података о физичким и правним лицима клијенти-ма банака и других корисника услуга кредитног бироа.

У поступку пред првостепеним судом утврђено је да је тужила без сагласности клијента код кредитног бироа, затражила податке о њеним примањима користећи "Смарт картицу" и неовлашћено користила те податке, на тај начин што их је учинила доступним трећем лицу, чиме је несумњиво учинила повреде радне обавезе које су јој стављене на терет. Наиме, "смарт картицу" тужила је могла да користи искључиво за обављање послова за које има закључен уговор о раду и исто тако искључиво уз сагласност клијената, а значај неовлашћеног коришћења података и информација до којих постоји могућност да се дође у току рада са кредитним бироом, управо јој је стављено у изглед стриктном обавезом да у складу са Законом о заштити података о личности, користи картицу у обављању својих радних задатака.

Многи аспекти примене информатичке технологије представљају потенцијално или стварно угрожавање приватности. С тим у вези појединац има право на приватност и тајност података који се на њега односе, како предвиђа и Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података од 28.1.1991 године ("Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 1/92) и Устав Републике Србије у одредби чл. 42, јер лица о којима се прикупљају и обрађују подаци морају бити обавештени о којим се подацима ради, ко их обрађује, у које сврхе и по ком основу, као и ко су корисници тих података. Наведена правила садржана су у Закону о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 24/98...97/08), који је био у примени у спорном периоду и у Закону о заштити података о личности - "Сл. гласник РС", бр. 97/08 од 27.10.2008. године, као и чл. 46. Закона о банкама, услед чега је тужила и потписала изјаву од 21.7.2007. године и преузела обавезу као радну обавезу, што је све релевантно у оцени законитости одлуке о престанку радног односа.

Из изнетих разлога овај суд налази да је на утврђено чињенично стање правилно примењено материјално право и да нису основани наводи жалбе којима се указује на то да А.А. није активни клијент банке, већ ранији клијент, те да није користила личне податке клијента, нити обаве-

штавала о њеном кредитном статусу неовлашћено лице, обзиром да је првостепени суд на основу извештаја кредитног бироа и оценом доказа изведених у поступку, несумњиво утврдио чињенични основ за правилну примену материјалног права, на основу кога овај суд налази да је правилан закључак првостепеног суда да није основан тужбени захтев тужиоца.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1. 872/10 од 23.06.2010. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

(Чл. 220. и 223. ЗПП)

Терет доказивања чињеница да запослени није остварио пуно радно време и стандардни учинак, услед чега се оспорава право на исплату зараде по предвиђеним мерилима и критеријумима сходно уговору о раду и општим актима, је на послодавцу који располаже доказима који се тичу пословања, радно правног статуса и других података и евиденција од којих зависи право и обавезе запосленог у складу са законом и општим актом туженог.

Из објасњења:

Одредбом чл. 111. Закона о раду прописано је да запослени има право на минимални зараду за стандардни учинак и пуно радно време.

Тужени је у одговору на тужбу оспорио тужбени захтев истичући да тужилац није доставио доказе о стандардном учинку и пуном радом времену.

Дискреционо је право туженика да ли ће активно учествовати у парници и до окончања главне расправе доставити доказе у прилог својих навода.

Међутим, терет чињеничних тврдњи и доказа да се нису стекли услови за исплату траженог новчаног потраживања је на туженом као титулару обавезе, јер је на њему дужност испуњења, а не на запосленом као

повериоцу. Дакле, терет доказивања чињеница да запослени није остварио пуно радно време и стандардни учинак, услед чега се оспорава право на исплату зараде по предвиђеним мерилима и критеријумима сходно уговору о раду и општим актима је на послодавцу који располаже писменим доказима који се тичу пословања, радно-правног статуса и других података и евиденција од којих зависи право и обавезе запосленог у складу са законом и општим актом туженог.

У смислу чл. 220. и 223. ст. 1. и 3. ЗПП тужени до окончања главне расправе није доставио ниједан доказ у прилог својих навода датих у одговору на тужбу у погледу околности да је тужилац одсуствовао са рада, те да није остварио пуно радно време и стандардни учинак, нити је доставио доказе да је то евентуално резултат акта недисциплине или неиспуњења и неизвршавања радних обавеза за које би био одговоран тужилац.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Гж1.2011/11 од 14.10.2011. године)

Аутор сентенце: Ивана Рађеновић,
судија Апелационог суда у Нишу

НЕМОГУЋНОСТ ВИШЕСТРУКОГ УКИДАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ (Члан 373. став 3. ЗПП)

У ситуацији када је првостепени суд међупресудом одбио тужбени захтев у погледу основа за накнаду штете и одлучио да ће застати са расправљањем о висини тужбеног захтева до правоснажности те одлуке, другостепени суд не може укинути побијану међупресуду и предмет вратити првостепеном суду на поновно одлучивање уколико је првостепена пресуда била једном укинута, већ мора укинути међупресуду и истовремено одлучити о захтевима странака у смислу чл. 369. ст. 3. ЗПП.

Из објасњења:

Побијаном међупресудом утврђено је да тужена општина Витина није у обавези да тужиоцима накнади штету на име срушених пословних

простора од два локала укупне површине 112м², у КО Витина, на делу Кп.бр. 3098 и на име изузимања земљишта из приватне својине ради проширења главне улице у Витини које чини 112/332 дела катастарске парцеле 3098 на месту званом "Село Обор" КО Витина, величине 03.32 ара. Ставом другим изреке, застаје се са расправљање о висини тужбеног захтева до правоснажности побијане пресуде. Ставом три изреке, утврђено је да ће се о трошковима поступка одлучити накнадно.

Одлучујући о жалби тужиоца против наведене међупресуде Апелациони суд је укинуо међупресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење, налазећи да се међупресудом може одлучити о основаности тужбеног захтева само ако суд налази да правни основ за тужбени захтев постоји. То значи да међупресуда увек има карактер утврђујуће пресуде, а у конкретном случају је побијаном међупресудом утврђено да не постоји правни основ за накнаду штете.

Врховни Касациони суд је одлучујући о сукобу стварне надлежности који је изазвао Основни суд у Врању утврдио да је за поступање у овом предмету надлежан Апелациони суд у Нишу обзиром да је одредбом чл. 373. ст. 3. ЗПП прописано да у случају да је првостепена пресуда већ једанпут била укинута, другостепени суд не може укинути пресуду и упутити предмет првостепеном суду на поновно суђење. Пошто је побијана међупресуда по жалби већ укинута, Апелациони суд је након одржане расправе у смислу чл. 369. ст. 3. ЗПП пресудом одлучио о основаности тужбеног захтева тужилаца у целисти.

(Међупресуда Општинског суда у Витини П. 6/08 од 14.07.2009. године, решење Апелационог суда у Нишу Гж. 2663/10 од 03.06.2010. године, решење Врховног Касационог суда Р. 8/11 од 13.01.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 6Гж. 218/11 од 11.03.2011. године).

Приредила: судија Данијела Николић

КРИВИЧНО ПРАВО

**КРИВИЧНО ДЕЛО НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА
И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОПОЈНИХ ДРОГА
ИЗ ЧЛАНА 246. СТАВ 1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА
(Члан 246 став 1. КЗ, у вези члана 355. тачка 1. ЗКП)**

Уколико су таблете које су проглашене опојном дрогом прописане као терапија у лечењу оптуженог, држање таквих супстанци не представља радњу кривичног дела јер није противправно нити скривљено.

Из образложења:

У допуни свога вештачења вештак неуропсихијатар Др М.В. остаје у свему при свом писаном налазу у коме је утврдио да оптужени болује од болести зависности од наркотика, да је склон злоупотреби таблета и да је дело извршио услед зависности од опојних дрога а што се тиче врсте и својства таблета које су пронађене код њега објашњава да се ради о истим лековима који су и одређивани као терапија оптуженом, али са другим називима лека. Ове околности из налаза и мишљења вештака неуропсихијатра доводе у сумњу закључке првостепеног суда да је оптужени таблете држао ради продаје тим пре што те закључке првостепени суд заснива на различитим врстама таблета које је оптужени држао код себе и на њиховој већој количини.

Првостепени суд не цени извештаје доктора специјалиста који су приложени и то извештај доктора специјалисте од 03.03.2011. године, извештај о лечењу Клиничког центра Др В.Р. од 16.03.2011. године и извештаје затворских лекара неуропсихијатра о преписивању терапије оптуженом, посебно у вези одбране оптуженог као и у вези са налазом и мишљењем вештака неуропсихијатра о својствима лекова који су преписани терапијом и лекова које је оптужени држао код себе. Вештак Др М.В. је објаснио да се терапија оптуженог састојала од метадонске терапије и терапија таблетама бенсендина, флорамидала, золофта и ламихтала да је уствари идентична са лековима које је оптужени држао код себе и то таблетама мидазолама (флормидал) и таблетама дијазепама (бенсендин). Првостепени суд је пропустио да изврши оцену дела одбране у којој оптужени објашњава да је употребљавао једну таблету бенсендина ујутру и једну увече, а да је увече узимао и таблету флормидала и није извршио оцену те количине у односу на укупну количину таблета које су пронађене

не код њега а дати разлози да се ради о већој количини су уопштени и не ослањају се на резултате изведених доказа тако да је и чињенично стање у том делу остало непотпуно и неправилно утврђено.

(Пресуда Вишег суда у Лесковцу К.бр. 120/10 од 10.05.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр. 1887/11 од 06.09.2011. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

НЕДОЗВОЉЕНИ ПРЕЛАЗ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ И КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУДИ

(Члан 350. став 3. у вези става 2. КЗ)

Прибављање какве користи учиниоца је битно обележје кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из чл. 350. ст. 3. у вези ст. 2. КЗ, тако да изрека пресуде мора да садржи опис те користи и у чему се она огледа, а образложење пресуде разлоге о одлучним чињеницама за утврђивање врсте и висине те користи.

Из образложења:

Првостепени суд у разлозима пресуде даје формалне закључке да је оптужени дело извршио са директним умишљајем јер је био свестан да омогућава недозвољен транзит кроз Републику Србију и то 4 страна држављана које је покупио у близини границе Републике Македоније и да је то све хтео ради прибављања новчане користи, али не даје разлоге о оцени доказа на основу којих је утврдио постојање намере као вишег степена директног умишљаја. Из изведених доказа произилази да је опт. Р.Б. као радник предузећа и возач таксија за извршену вожњу добио надокнаду у виду плате, па су с тога разлози пресуде о намери оптуженог да изврши кривично дело ради прибављања новчане користи неразумљиви и не потврђени изведеним доказима. Наведене недостатке садржи изрека пресуде јер се у њој при опису дела говори о намери оптуженог да себи прибави какву корист без ознаке и опредељења о каквој се користи ради да ли је она новчане или друге природе и без ознаке саме користи коју је прибавио оптужени извршењем дела или коју је намеравао да прибави тако да је у том делу изрека противречна а пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног

поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП. У овом правцу првостепени суд није ни ценио доказе пре свега одбрану оптуженог који објашњава колику накнаду добија за наведено путовање и не цени наводе путника који су говорили да су по њиховом уласку у возило од оптуженог чули да ће о трошковима превоза накнадно да се договоре. Првостепени суд није расправио сва спорна питања и није правилно извршио оцену свих доказа у циљу утврђивања одлучних чињеница за постојање елемената кривичног дела, тако да је и чињенично стање у том делу постојања намере или прибављања имовинске користи оптуженог остало непотпуно утврђено.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр. 3104/10 од 23.09.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр. 887/11 од 01.09.2011. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

НЕДОЗВОЉЕНЕ ПОЛНЕ РАДЊЕ

(Чл. 182. ст. 1. у вези чл. 178. ст. 1. Кривичног законика)

Кривично дело недозвољене полне радње може да се изврши једино задовољавањем полног нагона учиниоца дела деловањем на тело другог лица.

Из образложења:

Одредбом чл. 351. ст. 2. ЗКП предвиђено је да суд није везан за предлог тужиоца у погледу правне оцене дела, то је првостепени суд био у обавези да на основу потпуно и правилно утврђеног чињеничног стања утврди да ли у радњама окривљеног постоје елементи кривичног дела за које је оптужен, имајући у виду опис радње која му се ставља на терет а не правну квалификацију тужиоца која је изнета у оптужном акту. У побијаној пресуди првостепени суд након детаљне оцене изведених доказа на страни 19 став 2. образложења пресуде даје правну оцену утврђеног чињеничног стања и налази да се у радњама окривљеног стичу сва законска обележја кривичног дела недозвољене полне радње из чл. 182. ст. 1. у вези чл. 178. ст. 1. КЗ. Дајући разлоге за овакву правну оцену, првостепени суд понавља обележја наведеног кривичног дела и налази да је утврђе-

но постојање дела јер је окривљени декоративним самурајским мачем претио да ће напасти на живот или тело оштећеног и истог принудио да га сексуално задовољи тако што ће маструбирати његов полни орган, што је овај и учинио ухвативши га руком за полни орган и два пута га повукао. Такође, суд налази да је ова радња окривљеног била усмерена на задовољење његовог полног нагона а да је истовремено тешко вређала морална осећања оштећеног. Изнети правни разлози првостепеног суда не могу бити прихваћени јер је битно обележје кривичног дела недозвољене полне радње из чл. 182. ст. 1. у вези чл. 178. ст. 1. КЗ да се те радње предузимају у циљу задовољења полног нагона и да се њима грубо вређају осећања људи у погледу полног односа, што је у овом случају пресудом утврђено али као трећи обавезан услов и обележје овог дела је да се задовољење полног нагона остварује деловањем на тело другог лица. У конкретном случају, по наводима из изреке побијане пресуде, окривљени је принудио оштећеног да предузима одређене радње на телу окривљеног а не на тело оштећеног као пасивног субјекта. То значи да је оштећени као жртва био принуђен да предузима радњу која служи задовољењу сексуалног нагона окривљеног и то радњу коју је предузео на телу окривљеног. У овој ситуацији окривљени као извршилац, изузев принуде, не предузима никакву другу радњу која се подразумева у ситуацијама из кривичног дела из чл. 178. до 181. КЗ, односно да недозвољену полну радњу предузима извршилац према другом лицу. Кривично дело недозвољене полне радње из чл. 182. ст. 1. КЗ у конкретном случају може да се изврши једино под условима из чл. 178. ст. 1. КЗ, што значи да полну радњу предузима окривљени као извршилац и то на телу другог лица као пасивног субјекта. Побијаном пресудом је утврђено да је полна радња вршена од стране другог на телу окривљеног, што по одредбама кривичног законика није предвиђено као кривично дело, па су дати разлози за правну квалификацију првостепеног суда неприхватљиви.

(Пресуда Основног суда у Нишу 7К.бр. 1762/10 од 22.11.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж.1. 1154/11 од 23.08.2011. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

**КРИВИЧНО ДЕЛО РАЗБОЈНИШТВО ИЗ ЧЛАНА 206. СТАВ 1.
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА ИЗВРШЕНО У САУЧЕСНИШТВУ
(Чл. 33. и 35. Кривичног законика)**

За постојање саучесништва у извршењу кривичног дела неопходна је субјективна веза која се огледа у постојању свести учиниоца о учешћу саучесника у заједничком деловању.

Из образложења:

Првостепени суд даје оцену свих изведених доказа кроз оцену одбране оптужених коју сматра супротном изведеним доказима из којих разлога их није прихватио. У погледу умишљаја оптужених даје се само формална дефиниција умишљаја и делимична анализа одбране оптуженог В.А. понављањем одбране о радњама и поступцима оптуженог В.А. у вези са управљањем возилом и разлозима непријављивања догађаја полицији, суд утврђује да је поступао са умишљајем да помогне оптуженом Д.М. у извршењу кривичног дела, али изузев наведеног дела образложења, пресуда не садржи разлоге о саучесништву односно саизвршилаштву у смислу члана 33. КЗ и помагању у смислу чл. 35. КЗ.

Саучесништво у кривичном делу постоји када је у извршењу дела учествовало више лица која су свесна заједничког деловања што подразумева да постоји објективна веза између њих а која се састоји у томе да сваки саучесник мора да одређеним својим радњама допринесе извршењу кривичног дела и наступелих последица, што значи да је радња сваког од саучесника део исте целине, усмерена ка проузроковању исте последице. За постојање саучесништва је неопходна и субјективна веза која се огледа у постојању свести о постојању саучесника у заједничком деловању, што значи да учиниоци знају један за другог и да знају ко је извршилац а при томе лично познанство није неопходно. У смислу Кривичног законика, саучесништво има четири облика и то саизвршилаштво, подстрекавање, помагање и организовање злочиначког удружења.

По наведеним одредбама Кривичног законика саизвршилаштво постоји ако више лица непосредно учествује у радњи извршења што значи да између њих постоји објективне веза која се односи на делимичну или у целини предузету радњу извршења која је дата у опису кривичног дела и субјективна веза, тј. да лица која учествују буду свесна заједничког деловања. По правилу али није неопходно постоји претходни договор о

заједничком извршењу дела, могуће и прећутни пристанак на извршење дела или накнадно укључење одређеног лица што зависи од конкретног случаја. Помагање је умишљено доприношење другом лицу да изврши кривично дело што значи да помагач својим радњама које су изван радње извршења, непосредно или посредно олакшава извршење дела. Помагање може бити различито и то као претходно, пре започете радње извршења кривичног дела или накнадно, психичко (нпр. давање савета и подршке извршиоцу) или материјално, (нпр. омогућавање смештаја пре извршења дела) и друго. Побијана пресуда и не садржи разлоге о наведеним облицима саучесништва а дати разлози су неразумљиви тако да је због наведених битних повреда кривичног поступка и непотпуно утврђеног чињеничног стања пресуда морала бити укинута.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 5К.бр. 191/11 од 21.04.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр. 1954/11 од 09.08.2011. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

ЕВЕНТУАЛНИ УМИШЉАЈ

(Члан 25. Кривичног законика)

Окривљени је био свестан да ударањем песницом оштећеног у пределу главе, може да нанесе тешке телесне повреде али посредан начин настанка тешке телесне повреде у виду прелома кључне кости услед пада на тврду подлогу указује на поступање окривљеног са евентуалним умишљајем.

Из образложења:

У односу на субјективна обележја кривичног дела првостепени суд је на основу оцене изведених доказа извео погрешан закључак да је окривљени наведене радње извршења кривичног дела учинио са директним умишљајем. Разлози побијане пресуде о овим околностима се заснивају на утврђеном чињеничном стању али су нејасни, с обзиром да је окривљени А.Ш. песницом ударио оштећеног у главу, након чега је оштећени пао и да је услед пада дошло до наношења тешке телесне повреде у

виду прелома кључне кости што је утврђено обављеним медицинским вештачењем. Из описаног начина извршења дела произилази да је окривљени био свестан да на наведени начин може да учини кривично дело, али с обзиром на посредан начин наношења тешке телесне повреде не произилази закључак првостепеног суда да је окривљени хтео наступање кривичног дела тешка телесна повреда и самим тим и наношење тешке телесне повреде оштећеном, већ у погледу вољног елемента као саставног дела умишљаја произилази да је на наступање наведене последице окривљени пристао, што значи да је поступао са евентуалним умишљајем као блажим обликом виности.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу 2К.бр. 2945/10 од 24.01.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр. 1305/11 од 03.06.2011. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

**КРИВИЧНО ДЕЛО НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА
И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОПОЈНИХ ДРОГА
И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД КАЗНЕ**

(Члан 246. став 5. Кривичног законика)

Оптужени може бити ослобођен од казне уколико открије од кога набавља опојну дрогу а не и због потпуног признања извршеног кривичног дела и указивањем на саизвршиоце у извршењу дела.

Из образложења:

Пресудом Вишег суда у Нишу 1К.бр. 5/11 од 30.03.2011. године под тачком А, оптужени Н.М. оглашен је кривим због кривичног дела неовлашћено стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 1. Кривичног законика и осуђен је на казну затвора у трајању од 3 године.

Правилност и законитост побијане пресуде није доведена у питање наводима из жалбе бранилаца да је у конкретном случају било места примени чл. 246. ст. 5. Кривичног законика јер је оптужени Н.М. још приликом интервенције полиције на аутобуској станици открио од ког лица је добио дрогу, добровољно је предао тај један пакетић са опојном дрогом и

детаљно је објаснио своју улогу и да је Г.В. управо на основу тога касније и ухапшен, што све укупно према наводима из жалбе говори да је оптужени требао бити ослобођен од казне. Наиме, по оцени овог суда у конкретном случају нема места примени ослобађања од казне јер је из исказа овлашћеног службеног лица А.К. утврђено да је на основу оперативних сазнања вршена оперативна тактичка мера и радња заседе где живе Г.В. и Н.М. за које су имали сумњу да се баве препродајом опојне дроге хероин, да је око 12,00 часова оптужени Н.М. пришао неком лицу на аутобуском стајалишту, поздравио се са њим и задржао на кратко након чега се упутио према кући а да су они кренули за тим лицем које им је побегло и одбацило предмет за који се утврдило да се ради о опојној дроги, да је око 13,30 часова уочио оптуженог Д.С. који је паркирао возило испред куће Г.В. где се задржао око пет минута и кога су колеге овог сведока зауставиле и у возилу пронашле пакетић опојне дроге Д.Ц. је признао да је опојну дрогу набавио од Г.В. за сопствене потребе, а да је истог дана око 15,00 часова видео оптуженог Н.М. како Г.В. предаје неки новац, којом приликом су им овлашћена службена лица пришла и привела а да је касније оптужени Н.М. приликом претреса предао пакетић хероина његовом колеги. Како је чл. 246. ст. 5. Кривичног законика прописано да учинилац дела из ст. 1. до 4. овог члана који открије од кога набавља дрогу може се ослободити од казне, по оцени овог суда признање оптуженог који је ухваћен на делу и кога је полиција по оперативним сазнањима посматрала у току целог дана нема карактер откривања лица од кога је опојна дрога набављена већ само признања извршења кривичног дела, а како овај члан закона даје могућност а не представља обавезу да се учинилац ослободи од казне, одлучено је као у изреци пресуде.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 1.К.бр. 5/11 од 30.03.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4 Кж.1.бр. 1369/11 од 18.10.2011. године)

Приредили: судија Братислав Крстић
и судијски помоћник Марија Димитријевић

**НЕОВЛАШЋЕНА ПРОИЗВОДЊА
И СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ ОПОЈНИХ ДРОГА**
(Члан 246. став 3. у вези става 1. КЗ)

Уговорни однос оптужених као продаваца и купаца опојне дроге искључује постојање групе у смислу чл. 112. ст. 22. КЗ као квалификаторне околности, обзиром да због засебних интереса не могу бити повезани у циљу трајног или повременог вршења кривичног дела које за предмет има опојну дрогу.

Из образложења:

Пресудом Вишег суда у Нишу 2 К.бр.406//10 од 19.11.2010 год. оптужени В.Ј., С.О. и Н.Н., оглашени су кривим због крив. дела неовлашћено стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 3. у вези ст. 1. Кривичног законика.

Првостепена пресуда је уважавањем жалби бранилаца оптужених преиначена у делу правне оцене дела на тај начин што Апелациони суд радње оптужених В.Ј. и О.С. за које су оглашени кривим правно квалификује као кривично дело стављање у промет опојних дрога у саизвршилаштву из чл. 246. ст. 1. КЗ у вези чл. 33. истог законика а радње опт. Н.И. садржане у ст. 1. изреке првостепене пресуде, за које је оглашен кривим, као кривично дело неовлашћено стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 1. КЗ.

Означење купопродајне цене опојне дроге у износу од 6.500 евра у чињеничном опису дела као и да је оптужени Н.И. платио оптуженима В.Ј. и С.О. део уговорене цене, тачније 2.100 евра уз обавезу да остатак новца плати у наредном периоду свакако упућује на закључак да је између оптужених постојао једнократни однос продавца и купца који сам по себи искључује постојање групе јер купац због свог засебног интереса не може бити члан групе, па самим тим оптужени В.Ј. и С.О. као два лица, могу бити само саизвршиоци у смислу чл. 33. Кривичног законика.

И под претпоставком да је испуњен формални услов из чл. 112. ст. 22. КЗ у смислу повезаности најмање три лица, формирана група у циљу извршења једног кривичног дела из чл. 246. ст. 1. КЗ није квалификаторна околност. У прилог напред наведеног је утврђено чињенично стање које суд првог степена погрешно правно цени и изводи закључак о постојању

групе као квалификаторне околности само на основу чињенице да су противправне радње које за предмет имају опојну дрогу предузете од стране три лица која су у том периоду била у непосредном или посредном контакту, сретали се или разговарали телефоном.

Правном оценом утврђеног чињеничног стања садржаног у побивљеној пресуди, Апелациони суд је закључио да оптужени изнетим противправним поступањем остварили субјективна и објективна обележја кривичног дела неовлашћено стављање у промет опојних дрога из чл. 246. ст. 1. Кривичног законика и то оптужени Н.И., неовлашћеном куповином опојне дроге хероин у количини од 493,90 грама нето масе ради продаје а оптужени В.Ј. и опт. С.О. као саизвршиоци, неовлашћеном продајом исте. Виност оптужених тј. њихов психички однос према предузетим радњама и последици манифестује се код сваког понаособ у директном умишљају као највећем интензитету свести и воље као међусобно условљених компоненти и био је ограничен на извршење једног недозвољеног промета опојних дрога обзиром да из утврђеног чињеничног стања не произилази договор да у континуитету, трајно или повремено врше крив. дела која за предмет имају опојну дрогу.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 2К.бр.406/10 од 19.11.2010 године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4 Кж.1 бр.809/11 од 18.05.2011 године)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

**МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ И ЧУВАЊЕ
У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
(Члан 81. Кривичног законика)**

Уколико је током поступка примене мере безбедности (чл. 505. ст. 1. ЗКП) утврђено да учинилац болује од трајног душевног обољења које у потпуности искључује његову способност схватања значаја дела и могућност управљања поступцима, противправне радње које је у таквом стању предузео могу се квалификовати само као противправна дела која су законом прописана као кривична дела а не и као кривична дела која је окривљени учинио у неурачунљивом стању.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Нишу 13 К.бр.5668/10 од 24.06.2010. године окр. М.С, на основу чл. 80. и чл. 81. КЗ изречена је мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи због кривичног дела угрожавања сигурности из чл. 138 ст. 3. у вези ст. 1. КЗ и кривичног дела ометање правде из чл. 336-б ст. 2. КЗ.

Основано се у жалби браниоца указује и аргументовано образлаже да је првостепено решење засновано на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП обзиром да је изрека нејасна и противречна сама себи а изостали су разлози о одлучним чињеницама а и они који су дати непотпуни су, неразумљиви и противречни сами себи.

Наиме, током поступка за примену мере безбедности у смислу чл. 505. ст. 1. ЗКП утврђено је да М.С. болује од трајног душевног обољења које у потпуности искључује његову способност схватања значаја дела и могућност управљања поступцима а противправне радње које је у таквом стању предузео могу се квалификовати само као *противправна* дела која су законом прописана као крив.дела а не као крив.дела које је окривљени учинио у неурачунљивом стању, како то првостепени суд погрешно наводи и на тај начин изреку побијаног решења учинио нејасном и противречном.

Према чл. 14. КЗ кривица је субјективно обележје кривичног дела а њени конститутивни елементи су свест о забрањености и урачунљивости који се претпостављају и виност, тј. психички однос извршиоца кривичног дела према свом делу и последици. Према чл. 23. ст. 1. КЗ није кривично дело оно дело учинено у стању неурачунљивости. Неурачунљивост сама за себе представља основ који искључује постојање кривичног дела, па је непотребно да изрека решења о изрицању мере безбедности у смислу чл. 81. Кривичног законика, садржи чињенични опис дела сасвим обележјима предметног кривичног дела.

(Пресуда Основног суда у Нишу 13К.бр.5668/10 од 24.06.2010.године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.3689/10 од 15.12.2010.године)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

ЗАСТАРЕЛОСТ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ

(Члан 107. став 6. у вези става 1. КЗ)

Застарелост извршења казне почиње од дана када је пресуда којом је казна изречена постала правноснажна а настаје у сваком случају када протекне двоструко време које се по закону тражи за застарелост извршења казне по чл. 107. ст. 6. КЗ.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Прокупљу Кв.бр.141/11 од 17.06.2011. године одбијен је као неоснован захтев осуђеног М.З. за одлучивање о апсолутној застарелости извршења казне затвора у трајању од 6 месеци по правноснажној пресуди Општинског суда у Прокупљу К.бр. 430/11 од 27.12.2006. године.

Уважавањем жалбе осуђеног првостепено решење је укинато јер је засновано на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП. Наведена повреда кривичне процедуре огледа се у томе што су у побијаном решењу дати нејасни и противречни разлози о неиспуњењу услова да се утврди да је наступила застарелост извршења казне у смислу чл. 107. ст. 6. ЗКП.

Ако се има у виду императивни карактер одредбе чл. 107. ст. 6. ЗКП, апсолутно су нејасни и за сада неприхватљиви разлози првостепеног суда да није наступила застарелост извршења казне јер се осуђени налази на издржавању казне затвора по некој другој правноснажној пресуди и да је према плану Казнено поправног завода, издржавање казне затвора од 6 месеци по пресуди К.бр.430/11 од 27.12.2006. године, планирано почев од 17.01.2014. године.

(Решење Основног суда у Прокупљу Кв.бр.141/11 од 17.06.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 11Кж.2.бр.715/11 од 08.08.2011. године)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

**КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛАНА 149. СТАВ 2. ЗАКОНА
О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ**

Када се окривљеном ставља на терет да је у својству инвеститора започео грађевинске радове на претварању таванског простора у стамбени простор, потребно је најпре утврдити да ли радови на адаптацији таванског простора представљају објекат, према Закону о изградњи објеката.

Из образложења:

Из наведеног произилази да је првостепени суд окривљеног огласио кривим за кривично дело из чл. 149. ст. 2. Закона о планирању и изградњи, који у време пресуђења више није важио. Међутим, у Закону о изменама и допунама Кривичног законика ("Службени гласник РС", бр. 72/2009), као ново кривично дело, прописано је одредбом чл. 219а, кривично дело грађење без грађевинске дозволе, којим се у ставу 2. кажњава лице које је инвеститор или одговорно лице у правном лицу, које је инвеститор објекта, који се гради без грађевинске дозволе.

С обзиром на наведена битна обележја кривичног дела грађење без грађевинске дозволе из чл. 219а ст. 2. Кривичног законика, било је потребно да првостепени суд утврди да ли су обележја овог кривичног дела идентична са обележјима кривичног дела из чл. 149. ст. 2. Закона о планирању и изградњи, које се окривљеном ставља на терет, те да оцени да ли има места примени одредбе чл. 219а Кривичног законика. Ово из разлога што је одредбом чл. 149. ст. 2. Закона о планирању и изградњи, која се окривљеном ставља на терет, прописано да ће се казнити физичко лице, које је инвеститор или одговорно лице у правном лицу, које је инвеститор објекта, који се гради без одобрења за изградњу и главног пројекта. Дакле, било је потребно утврдити да ли су наведеним законским одредбама прописани исти елементи, који треба да постоје у радњама окривљеног, да би се закључило да се ради о нелегалној изградњи.

Осим тога, требало је имати у виду и опис кривичног дела, како је дат у оптужном предлогу, из кога произилази да се окривљеном ставља на терет да је у својству инвеститора објекта започео грађевинске радове на претварању таванског простора у стамбени простор у циљу формирања нове стамбене јединице, без главног пројекта и одобрења за изградњу надлежног државног органа. Дакле, требало је на поуздан начин утврдити да ли радови

на адаптацији таванског простора представљају објекат, како је то одређено одредбом чл.2. тач.11. Закона о изградњи објеката, те, сходно томе, да ли дело описано у оптужном предлогу садржи елементе кривичног дела.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К.бр.867/08 од 02.11.2009.године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.2214/10 од 19.04.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

БИТНА ОБЕЛЕЖЈА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ЗЛОСТАВЉАЊЕ И МУЧЕЊЕ ИЗ ЧЛАНА 137. СТАВ 1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Кривично дело злостављање и мучење може се извршити не само наношењем физичких или психичких патњи, већ и сваким другим поступањем којим се вређа људско достојанство, што треба ценити у субјективном и објективном смислу.

Из образложења:

Нејасни су и разлози првостепеног суда за ослобађање окривљеног од оптужбе, јер као основ ослобађања примењује одредбу чл. 355. тач. 1. ЗКП, при чему наводи да у радњама окривљеног нема елемената бића кривичног дела злостављање и мучење из чл. 137. ст. 1. КЗ, при чему се позива на преглед оштећеног од стране др Снежане Владејић, која је утврдила да није било никаквих телесних или психичких последица по његово здравље. Стога се не може поуздано утврдити да ли је првостепени суд закључио да у конкретном случају дело које се окривљеном ставља на терет по закону није кривично дело или нису доказани битни елементи овог кривичног дела, у ком случају је требало применити одредбу чл. 355. тач. 2. ЗКП. Ово утолико пре, што се наведено кривично дело може извршити не само наношењем физичких или психичких патњи, већ и сваким другим поступањем, којим се вређа људско достојанство. У конкретном случају, првостепени суд се није упуштао у оцену да ли је поступањем окривљеног, како је оно описано у оптужном акту, повређено људско достојанство оштећеног, и то како у субјективном смислу, тако и у објективном, имају-

ћи у виду вредновање конкретног понашања са аспекта обичаја и схватања средине, док се последице овог кривичног дела посебно не утврђују.

(Пресуда Основног суда у Нишу 15К. бр. 210/10 од 25.05.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1. бр. 2952/10 од 24.05.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

УКИДАЊЕ ОБАВЕЗЕ ИЗРЕЧЕНЕ УЗ УСЛОВНУ ОСУДУ

Када постоји правноснажна и извршна парнична пресуда, којом је окривљени већ обавезан на исплату штете оштећеном, сувишна је обавеза плаћања причињене штете оштећеном одређена уз условну осуду.

Из образложења:

Основано се жалбом окривљене истиче да првостепени суд није узео у обзир да постоји правноснажна и извршна пресуда П. бр. 7200/06 од 30.08.2007. године, којом је окривљена већ обавезана да оштећеној исплати штету у износу од 19.693,77 евра, са наведеном каматом, те да је сувишна обавеза одређена побијаном пресудом.

Стога је Апелациони суд укинуо обавезу изречену окривљеној уз условну осуду, да оштећеној у року од шест месеци по правноснажности пресуде плати причињену штету у наведеном износу, у ком смислу је побијана пресуда преиначена. Ово из разлога што је током првостепеног поступка несумњиво утврђено да постоји правноснажна и извршна пресуда у парничном поступку, којом је окривљена већ обавезана на плаћање причињене штете у истом износу и са истом каматом, па се наметање ове обавезе окривљеној показује непотребним, јер се на тај начин превазилази сврха изрицања условне осуде у конкретном случају.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К. бр. 1600/09 од 20.10.2009. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1. бр. 1448/10 од 24.02.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

**КРИВИЧНО ДЕЛО УНИШТЕЊЕ И ОШТЕЋЕЊЕ
ЈАВНИХ УРЕЂАЈА ИЗ ЧЛАНА 279. СТАВ 2. У ВЕЗИ СТАВА 1.
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА**

Поремећај проузрокован у животу грађана је битно обележје кривичног дела уништење и оштећење јавних уређаја из чл. 279. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ.

Из образложења:

Првостепени суд је у доказном поступку саслушао окривљеног и сведоке, али при томе није саслушао представника оштећеног, који је иначе био присутан на сваком главном претресу, тако да се не може утврдити каква је штета причињена оштећеном предузећу, нити какав је поремећај проузрокован у животу грађана, јер о томе нема никаквих доказа у списима предмета, нити разлога у образложењу пресуде. Ово је било потребно утврдити зато што се оптужним предлогом окривљеном ставља на терет да је услед његовог понашања изазван прекид у телефонском саобраћају за два корисника до 02.10.2008. године, а што стоји и у изреци побијане пресуде.

Пресуда Основног суда у Прокупљу ЗК. бр. 373/10 од 10.05.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1. бр. 3002/10 од 26.10.2010. године)

Приредила: судија Горана Митић

**МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ
ОБАВЕЗНОГ ЛЕЧЕЊА АЛКОХОЛИЧАРА**

Може се изрећи мера безбедности обавезног лечења алкохоличара из чл. 84. ст. 1. Кривичног законика, уколико постоји озбиљна опасност да ће окривљени услед зависности од алкохола и даље вршити кривична дела и ако је кривично дело извршено услед зависности од алкохола.

Из образложења:

У односу на изречену меру безбедности, првостепени суд није дао одговарајуће разлоге за своју одлуку, већ се само позвао на одредбу чл. 84. Кривичног законика. Ова законска одредба односи се на обавезно лечење алкохоличара, али под условом да је кривично дело учињено услед зависности од употребе алкохола и ако код окривљеног постоји озбиљна опасност да ће услед ове зависности и даље да врши кривична дела.

У конкретном случају, првостепени суд је ову меру донео на основу налаза и мишљења судског вештака, који је предложио обавезно лечење окривљеног у специјализованој болници, али се при томе није децидирано изјаснио да ли постоји озбиљна опасност да ће он услед зависности од алкохола и даље вршити кривична дела, а првостепени суд, образлажући своју одлуку, није утврдио да ли је окривљени дело извршио услед зависности од алкохола, што је био дужан да учини пре изрицања ове мере.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 4К.бр.565/10 од 26.04.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.3587/10 од 09.11.2010. године)

Приредила: судија Горана Митић

**УМИШЉАЈ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА САМОВЛАШЋЕ
ИЗ ЧЛАНА 330. СТАВ 1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА**

Власник локала издатог у закуп има државину, па је не може самовласно прибављати.

Из образложења:

На правилно и потпуно утврђено чињенично стање, првостепени суд је правилно применио кривични закон, када је окривљеног ослободио од оптужбе, јер током поступка није доказано постојање умишљаја окривљеног да самовласно прибави себи право државине, за које је сматрао да му припада. Напротив, утврђено је да је окривљени критичном приликом, као власник овог локала, поступао у намери да заштити локал од могуће

штете, с обзиром да приватна тужилђа није исти користила дуже време и није долазила на његове позиве. При томе, треба имати у виду да окривљени, као власник, односно закуподавац локала, није изгубио државину над локалом тиме што га је издао у закуп, па стога није ни могао да на овај начин себи прибавља право државине.

(Пресуда Основног суда у Нишу 3К.бр.6003/10 од 04.02.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.2114/11 од 02.08.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

ТЕШКА КРАЂА

(Чл. 204. ст. 1. тач. 3. КЗ)

Извршилац врши тешку крађу на нарочито дрзак начин када приђе оштећеној са леђа и истргне јој торбицу коју носи у руци.

Из образложења:

Доказима изведеним током поступка чињенично стање је потпуно и правилно утврђено, пре свега имајући у виду саму одбрану малолетника који је детаљно описао да је критичном приликом, наводећи време и место извршења кривичног дела, оштећеној која се кретала са још једном девојком испред њега, пришао одпозади, одузео јој ташну коју је држала у руци и побегао одатле односећи исту са собом, као и да је ташну затим отворио и мобилни телефон који је био у њој дао свом другу, који је затим од њега и одузет.

Правилно је првостепени суд утврдио да је малолетник критичном приликом поступио на нарочито дрзак начин будући да је оштећеној пришао с леђа и истргао јој торбицу коју је носила у руци, са намером да из исте одузме новац и све вредније ствари које буде нашао у торбици те да на тај начин прибави за себе противправну имовинску корист, јер оштећеној није враћена торбица, новац, кључеви и лична документација коју је малолетник од ње одузео. За такво утврђење је првостепени суд дао довољно јасних и разумљивих разлога које у целости прихвата и овај суд, те

да су у његовим радњама садржана сва битна обележја кривичног дела те-шке крађе из чл. 204. ст. 1. тач. 3. КЗ.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кжм.2.бр.6/2010 од 6.4.2010. и решење Вишег суда у Нишу IКм.бр.23/10 од 09.02.2010. године)

Аутор: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

НЕДОЗВОЉЕНА ТРГОВИНА

(Члан 243. став 1. КЗ)

У изреци пресуде мора бити јасно опредељено да ли се окривљени неовлашћено и у већем обиму бавио трговином или је немајући овлашћење за трговину набавио робу у већој вредности у сврху даље продаје

Из образложења:

Кривично дело недозвољена трговина из чл. 243. ст. 1. КЗ може бити извршено на више начина, а облици извршења кривичног дела су набављање робе или других предмета у већој вредности у сврху продаје без овлашћења за трговину, неовлашћено и у већем обиму бављење трговином, посредовање у трговини или бављење заступањем у унутрашњем или спољнотрговинском промету робе и услуга.

Из изреке првостепене пресуде произилази да се је окривљени неовлашћено и у већем обиму бавио трговином са навођењем конкретне радње извршења из које, пак, не произилази бављење трговином у већем обиму нити о овој одлучној чињеници пресуда садржи разлоге.

Изрека пресуде је неразумљива јер се из исте не може утврдити да ли је окривљени оглашен кривим јер се неовлашћено и у већем обиму бавио трговином или је немајући овлашћење за трговину набавио робу у већој вредности у сврху даље продаје јер у разложима пресуде нису дати разлози о томе шта представља већу вредност, односно већи обим бављења трговином.

У погледу ових одлучних чињеница пресуда уопште не садржи разлоге иако је био у могућности да правилно оцени да ли се ради о већој вредности, да ли наведена роба представља робу веће вредности имајући у виду да је обављено вештачење вредности робе.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр.1200/10 од 20.05.2010 и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.3890/10 од 09.08.2011. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ФОТОКОПИЈА ИСПРАВЕ (Чл. 112. КЗ)

Неоверена фотокопија писмене исправе нема карактер исправе у смислу одредаба Кривичног законика и не може бити предмет кривичног дела фалсификовање исправе нити фалсификовања службене исправе.

Из образложења:

Пресуда не садржи разлоге у погледу постојања фалсификоване исправе нити се из исте може утврдити на који начин је првостепени суд закључио да се ради о фалсификованим исправама јер овакво закључивање, по ставу овог суда, нема основа у изведеним доказима.

Ово из разлога што неоверена фотокопија писмене исправе нема карактер исправе у смислу чл. 112. Кривичног законика и не може бити предмет кривичног дела фалсификовање исправе из чл. 355. КЗ нити фалсификовања службене исправе из чл. 357. КЗ.

Оригинална је она исправа која је издата од лица које је у њој означено као издавалац. Препис је репродуковање изјаве и нема доказну вредност те не представља исправу у правом смислу и то може постати само када је препис оверен од стране надлежног органа, када се на њему стави изјава да је у свему веран оригиналу, а то важи и за фотокопију.

Имајући ово у виду, нејасни су разлози првостепеног суда да наведене исправе у кривично правном смислу представљају фалсификоване

исправе, а самим тим и да је окривљени сачинио фалсификоване исправе, односно исте употребио, на шта се основано указује жалбом браниоца окривљеног, истицањем недостатка оригиналних примерака ових исправа.

(Пресуда Основног суда у Нишу 13К.бр.1228/10 од 21.04.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.4020/10 од 11.08.2011)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА У СТИЦАЈУ (Чл. 60. КЗ)

Изрицање јединствене казне једнаке збиру појединачно утврђених казни затвора је прекорачење овлашћења које суд има по закону и представља повреду закона на штету окривљеног.

Из образложења:

Неразумљива је одлука о утврђивању казне затвора и примени одредбе чл. 60. Кривичног законика, на шта и Основни јавни тужилац у жалби указује, јер првостепени суд утврђује за два кривична дела казне затвора у трајању од по три месеца и изриче условну осуду којом утврђује јединствену казну затвора у трајању од шест месеци, а обзиром да је одредбом чл. 60. ст. 2. тач. 2. Кривичног законика предвиђено да у таквој ситуацији, при одмеравању казне за дело у стицају јединствена казна не сме достићи збир утврђених казни, па је на описани начин првостепени суд прекорачио овлашћења која има по закону и повредио закон на штету окривљеног у смислу чл. 369. ст. 4. КЗ.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 4.К.бр. 1029/10 од 19.04.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.3005/10 од 27.01.2011. године)

Приредила: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

**УСЛОВИ ЗА ПОСТОЈАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
ОШТЕЋЕЊЕ ТУЋИХ ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 220. СТАВ 2. КЗ**

Продаја неке од ствари пописаних у поступку принудног извршења, не значи аутоматски постојање овог кривичног дела, уколико се поверилац може намирити из остале пописане имовине дужника.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. Законика о кривичном поступку, на коју другостепени суд поводом изјављене жалбе увек пази по службеној дужности, јер првостепена пресуда нема разлоге о појединим одлучним чињеницама.

Наиме, првостепени суд је чињенично стање у овој кривичној ствари утврдио оценом писаних доказа и исказа представника оштећеног, те оценом одбране окривљеног и утврдио да су окривљеном Г.Ц., као дужнику, у поступку принудног извршења, који се против њега води пред Општинским судом у Нишу у предмету Ив.2320/07, по предлогу повериоца - наведене банке дана 14.02.2008. године, због неизмиреност дуга повериоцу, пописане следеће ствари: возило марке "Рено 4", произведено 1989. године и фреза ИМТ 506, произведена 1998. године, којом приликом су возила остављена на чување дужнику, без права да их отуђи, а што су странке својим потписима потврдиле. Записником сачињеним дана 09.03.2009. године извршни радник Суда је констатовао да је путничко возило продато, а по изјави супруге дужника, што у поступку ни сам окривљени као дужник није оспорио. Након што је првостепени суд утврдио да је окривљени као дужник наставио са измирењем својих обавеза, али да обавезе није у потпуности измирио, а продао је путничко возило - ствар пописану у току принудног извршења, те како је поступао са директним умишљајем, то је закључио да је окривљени учинио кривично дело за које га је огласио кривим.

Овако дати разлози првостепеног суда су за сада недовољни, јер је за постојање кривичног дела оштећење туђих права из чл. 220. ст. 2. КЗ, неопходно било утврдити да ли је оваквим поступањем окривљеног као дужника проузроковано оштећење повериоца или се поверилац могао намирити из вредности осталог дела имовине дужника, конкретно продајом Фрезе ИМТ 506, производње 1998. године, која је такође пописана у по-

ступку принудног извршења. Ово кривично дело је свршено само у случају када је поверилац оштећен, односно када се није могао намирити из осталог дела имовине дужника, без обзира што је учинилац у намери осуђења његовог намирења отуђивао своју имовину.

Како побијана пресуда о утврђењу ове одлучне чињенице нема разлоге, нити је ради њеног утврђења изведен било који доказ, то је првостепена пресуда морала бити укинута.

(Пресуда Основног суда у Нишу 12 К.бр.4707/10 од 23.09.2010. године и Решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.4023/10 од 16.03.2011. године)

Приредила: судија Снежана Милошевић

ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ

О постојању кривичног дела насиље у породици из чл. 194. КЗ и његовим облицима, можемо говорити тек након ступања на снагу Кривичног законика, јер раније кривично законодавство није познавало ово кривично дело.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. Законика о кривичном поступку, на коју повреду другостепени суд поводом изјављене жалбе увек пази по службеној дужности, јер је изрека пресуде неразумљива, противуречна разлозима пресуде, а образложење пресуде не садржи јасне и довољне разлоге о свим одлучним чињеницама и примени закона.

Пре свега изрека пресуде је неразумљива у погледу времена извршења кривичног дела, јер је окривљени оглашен кривим да је у периоду од 09.12.2004. године до 09.06.2009. године на описани начин дрским и безобзирним понашањем угрозио спокојство и душевно стање свог пасторка, мал. оштећеног Д. М, ако се има у виду чињеница да до 01.01.2006. године, као дана ступања на снагу Кривичног законика ("Службени гласник РС",

број 85 од 06.10.2005. године), раније кривично законодавство није познавало ово кривично дело, те је у том смислу нејасна и правна квалификација кривичног дела за које је окривљени оглашен кривим.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр.2300/10 од 17.05.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.4283/10 од 03.06.2011. године)

Приредила: судија Снежана Милошевић

**НАМЕРА КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА КРШЕЊЕ ЗАКОНА
ОД СТРАНЕ СУДИЈЕ, ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
И ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА ИЗ ЧЛАНА 360. КЗ**

За постојање кривичног дела кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из чл. 360. Кривичног законика, поред објективних елемената, неопходно је и постојање намере да се другом прибави каква корист или нанесе каква штета, која чињеница се мора посебно утврђивати.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. Законика о кривичном поступку, на коју се основано указује жалбом окривљеног, јер у пресуди нису дати јасни разлози о свим одлучним чињеницама.

Наиме, побијаном пресудом окривљени М.Т. је оглашен кривим за кривично дело кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из чл. 360. Кривичног законика, јер у оптуженом периоду, као судија наведеног суда, у судском поступку К.бр.31/96, у намери да М.Б. прибави корист, а И.Д. нанесе штету, прекршио закон, тако што више од седам година ни једном није заказао предмет, нити предузео било коју другу службену радњу, како би поступак благовремено окончао, што је довело до апсолутне застарелости кривичног гоњења окривљеног М.Б.

У разлозима пресуде првостепени суд је након оцене изведених доказа утврдио чињенично стање, а потом нашао да је окривљени незаконитим

поступањем, конкретно пропуштањем да у разумном року одлучи о предлогу оштећеног као тужиоца за повраћај у пређашње стање, о чему је одлучио тек након више од седам година, применио закон супротно његовим опредељењима и интенцијама, што је, у коначном, довело до обуставе поступка против окривљеног М.Б. због застарелости кривичног гоњења, на који начин је наведеном окривљеном прибавио корист, а оштећеном као тужиоцу И.Д. нанео штету, онемогућивши му да у законом прописаном поступку оствари своја права, при том поступајући са директним умишљајем.

Овако дати разлози првостепеног суда о утврђеном чињеничном стању и примени закона су за сада неприхватљиви, јер побијана пресуда не садржи јасне разлоге о одлучној чињеници која се односи на постојање намере окривљеног да описаним поступањем другом прибави какву корист или да му нанесе какву штету, што представља битан елемент кривичног дела за које је окривљени оглашен кривим. Првостепени суд је постојање намере на страни окривљеног утврдио једино из чињенице да окривљени дужи временски период, конкретно седам година, није одлучио о предлогу оштећеног као тужиоца за повраћај у пређашње стање, што је касније довело до доношења решења о обустави кривичног поступка због застарелости кривичног гоњења. Дакле, првостепени суд је постојање намере, која није саставни део умишљаја, већ посебно субјективно обележје дела које постоји уз умишљај, утврдио само на основу чињенице да је окривљени прекршио закон непоступањем у наведеном кривичном предмету у разумном року, услед чега је оштећени онемогућен у остваривању својих права.

За постојање кривичног дела кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог заменика из чл. 360. Кривичног законика, поред објективних елемената, неопходно је и постојање намере да се другом прибави каква корист или нанесе каква штета, која чињеница се мора посебно утврђивати. Намера подразумева субјективан феномен који утиче на предузимање одређене делатности ради постизања одређеног циља, те се говори о тзв. квалификованом умишљају, који мора постојати код учиниоца у време извршења кривичног дела.

(Пресуда Вишег суда у Врању К.бр.199/10 од 10.03.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 8 Кж.1.бр.1266/11 од 06.05.2011. године)

Приредила: судија Снежана Милошевић

ПОМАГАЊЕ ИЗ ЧЛАНА 35. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

Кривица помагача условљена је осудом извршиоца за одређено кривично дело.

Из образложења:

Наиме, првостепени суд је оптуженог А.С. огласио кривим за кривично дело изазивање опште опасности помагањем из чл. 278. ст. 1. у вези чл. 35. КЗ, али није имао у виду да је услов постојања овог облика саучесништва, осуда извршиоца. Саме по себи радње помагања не представљају кривично дело, јер њихова посебна обележја нису прописана у посебном делу кривичног закона, услед чега су оне релевантне само ако доприносе извршењу одређеног кривичног дела од стране конкретног извршиоца.

У случају да се одвојено суди помагачу, у изреци пресуде којом се помагач оглашава кривим мора се утврдити кривично дело које је извршио учинилац, а првостепени суд иако утврђује да се пред Општинским судом у Нишу под бројем Ки.бр.2188/08 води кривични поступак против А.Д. за кривично дело изазивање опште опасности извршено дана 23.12.2006. године у ул. П. у Нишу, у изреци побијане пресуде утврђује да је оптужени А.С. са умишљајем помогао А.Д. у извршењу кривичног дела за које се води одвојени кривични поступак. Дакле, предуслов за кривицу помагача је осуда извршиоца за одређено кривично дело, уз оцену постојања и квалитета доприноса помагача извршењу кривичног дела. Из односа извршеног кривичног дела и радњи помагања произилази да је кривичнонеправна релевантност радњи помагања акцесорне природе, што даље значи да се прво мора утврдити кривично дело које је извршио одређени учинилац, да би се потом могло утврдити да ли су радње помагања допринеле извршењу одређеног кривичног дела.

(Пресуда Окружног суда у Нишу К.бр.248/08 од 09.03.2009. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.67/10 од 31.03.2010. године)

Приредила: судија Снежана Милошевић

**ОБЛИК ВИНОСТИ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА
НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ ИЗ ЧЛАНА 344. СТАВ 2. КЗ**

За постојање овог квалификованог облика кривичног дела насилничко понашање из чл. 344. ст. 2. КЗ, неопходно је, да је лака телесна повреда нанета нехатно, јер се у супротном ради о стицају кривичних дела.

Из образложења:

Наиме, побијаном пресудом су окривљени А.Ђ. и З.Ђ. оглашени кривима за по једно кривично дело насилничко понашање из чл. 344. ст. 2. КЗ, учињено са директним умишљајем, како у односу на радњу извршења, тако и у односу на наступелу последицу која се огледа у лаком телесном повређивању оштећеног. Основано се жалбом јавног тужиоца указује да је за постојање овог квалификованог облика кривичног дела насилничко понашање из чл. 344. ст. 2. КЗ, неопходно да је лака телесна повреда нанета нехатно, јер се у супротном ради о стицају кривичних дела.

Произилази да чињенични опис овог кривичног дела не одговара датој правној квалификацији, што пресуду чини неразумљивом и противуречном самој себи, због чега је побијана пресуда у осуђујућем делу морала бити укинута.

У поновљеном поступку првостепени суд ће отклонити недостатке на које је указано овим решењем, те ће након што потпуно утврди чињенично стање, у пресуди изнети разлоге о утврђењу одлучних чињеница, потом оцену доказа, разлоге којима се руководио при решавању правних питања, а нарочито при утврђивању да ли постоји кривично дело, како је прописано одредбом чл. 361. ст. 7. ЗКП. Овом приликом се посебно указује суду на значај утврђивања облика виности, дакле психичког односа који обухвата свест и вољу окривљених према делу и његовој забрањености, а који закључак треба да се заснива на целокупној оцени личности учиниоца и околностима извршеног дела. Поред осталог, од правилног утврђења ових чињеница зависи и правилност примене закона.

(Пресуда Општинског суда у Бабушници К.бр.26/08 од 19.10.2009. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.922/10 од 15.12.2010. године)

Приредила: судија Снежана Милошевић

ОПОЗИВ УСЛОВНЕ ОСУДЕ

Доношење одлуке о опозиву условне осуде претпоставља да је осуђени био у могућности да у остављеном или продуженом року испуни изречене му обавезе, а да то ипак није учинио из разлога који се не могу сматрати оправданим.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, на које другостепени суд увек пази по службеној дужности, а на које се основано указује изјављеном жалбом, јер пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама.

Наиме, побијана пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама, јер првостепени суд није утврдио да ли је осуђени био у могућности да испуни обавезе које су му изречене уз условну осуду, која се побијаном пресудом опозива. Доношење одлуке о опозиву условне осуде претпоставља да је осуђени био у могућности да у остављеном или продуженом року испуни изречене му обавезе, а да то ипак није учинио из разлога који се не могу сматрати оправданим. Ову околност првостепени суд мора утврдити пре него што донесе одлуку о опозиву условне осуде, а у супротном чини битну повреду одредаба кривичног поступка.

Због учињених битних повреда одредаба кривичног поступка, побијана пресуда је морала бити укинута.

У поновљеном поступку првостепени суд ће отклонити недостатке на које је указано овим решењем, те ће пре свега поуздано утврдити околности које су од значаја за доношење одлуке о опозиву условне осуде, а тек тада ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

(Пресуда Основног суда Нишу Кв.бр.46/10 од 17.02.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.1765/10 од 01.12.2010. године)

Приредила: судија Снежана Милошевић

ПОРЕСКА УТАЈА

(Члан 229. КЗ)

Нема умишљаја код окривљеног, као пореског обвезника уколико је обрачунавао ПДВ за промет робе и услуга по мањој стопи, од оне која је прописана.

Из образложења:

Окривљенима је између осталог, стављено на терет извршење кривичног дела пореска утаја из чл. 229. ст. 1. КЗ да је износ ПДВ-а за промет роба и услуга по посебној стопи обрачунаван и књижен у висини од 8% уместо по стопи од 18% и то првоокривљеном као власнику самосталне угоститељске радње а другоокривљеном као власнику Агенције за рачуноводство са којим је првоокривљени закључио уговор о пружању рачуноводствених услуга. За наведено кривично дело окривљени су ослобођени од оптужбе јер није доказано постојање субјективног елемента као битног елемента кривичног дела.

Првостепени суд је утврдио да касу фискализује службено лице пореске управе или овлашћени сервисер те да су стопе за обрачун пореза тако и унете да се каса потом након извршене фискализације пломбира, из чега се закључује да порески обвезник нема овлашћења да мења фискалне стопе и да сам уноси исте будући да се то ради искључиво од стране службеног лица пореске управе или овлашћеног сервисера.

Једина чињеница на којој се заснива оптужба је да је порез на додату вредност обрачунат по стопи од 8% уместо по стопи од 18%. Стопа је законски одређена па је порески обвезник, односно књиговођа не могу приказати неистинито, већ само погрешно, што је порески орган био дужан да уочи и отклони, а не да свој пропуст преваљује на окривљене. Стога су основани разлози за уверење првостепеног суда да није било доказа о постојању умишљаја за извршење кривичног дела пореска утаја из чл. 229. ст. 1. КЗ

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1 707/10 од 20.05.2010. г. и пресуда Општинског суда у Владичином Хану К.бр.75/08 од 26.01.2009. г.)

Приредила: судија Љиљана Миљковић

УРАЧУНАВАЊЕ ПРИТВОРА У НОВЧАНУ КАЗНУ

(Члан 63. Кривични законик)

Неурачунавањем притвора у изречену новчану казну повређен је кривични закон на штету окривљеног.

Из образложења:

Основани су наводи жалбе да је погрешно примењен кривични закон, јер окривљеном није урачунато у новчану казну у износу од 70.000,00 (седамдесетхиљададинара) време проведено у притвору од 20.09.2010. године до 30.09.2010. године.

Како су испуњени услови за примену одредбе чл.63.Кривичног законика о урачунавању времена проведеног у притвору у новчану казну, то је Апелациони суд преиначио пресуду у делу одлуке о казни, тако што је окривљеног, због кривичног дела насиље у породици из чл. 194. ст. 1. Кривичног законика, за које је првостепеном пресудом оглашен кривим осудио на новчану казну у износу од седамдесет хиљада динара, коју је дужан да плати у року од два месеца, што ако не учини у остављеном року суд ће исту заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити један дан казне затвора, а у коју новчану казну му се урачунава време проведено у притвору од 20.09.2010. године до 30.09.2010. године, тако што се један дан проведен у притвору рачуна као хиљаду динара новчане казне

(Пресуда Основног суда у Нишу 9К.бр.3939/10, а пресуда Апелационог суда у Нишу 6Кж.1.бр.2554/11).

Приредила: судија Драгана Живадиновић

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

ТРЕНУТНО КРИВИЧНО ДЕЛО

(Чл. 205. ст. 1. КЗ РС у вези чл. 354. ст. 3. ЗКП)

Кривично дело лажно пријављивање је тренутно кривично дело код кога последица настаје одмах по остварењу радње извршења дела, тако да је радњом лажног пријављивања дело свршено.

Из образложења:

Побијана пресуда у односу на окривљеног З.Ђ. за продужено кривично дело лажно пријављивање из чл. 205. ст. 1. КЗ РС, за које је оглашен кривим је донета уз повреду кривичног закона на штету окривљеног, на шта се основано указује жалбом окривљеног З.Ђ. Кривично дело из чл. 205. ст. 1. КЗ РС извршено 25.01.2005. године за ово кривично дело је Кривичним законом Републике Србије ("Сл. гласник СРС", 26/77 и 39/2003), као и Кривичним закоником ("Сл. гласник РС", бр. 85/05 и 72/09) предвиђена казна затвора у трајању од три месеца до три године. Одредбом чл. 95. ст. 1. тач. 5, и 96. ст. 6. Основног Кривичног закона ("Сл. гласник РС", бр. 39/03), које су истоветне са одредбама чл. 103. и 104. Кривичног законика, одређено је да за кривично дело за које се по закону може изрећи казна затвора преко једне године, застарелост кривичног гоњења наступа протеком три године а одредбом чл. 96. ст. 6. застарелост настаје у сваком случају када протекне два пута онолико времена колико се по закону тражи за застарелост кривичног гоњења, што значи да застарелост кривичног гоњења за ово кривично дело наступа протеком шест година од извршења дела, што даље значи да је застарелост кривичног гоњења наступила 25.01.2011. године.

На основу члана 391. ст. 1. Апелациони суд је уважавајући жалбу у овом делу преиначио првостепену пресуду за наведено кривично дело налазећи да се правилном применом закона има донети другачија пресуда и на основу чл. 354. тач. 3. ЗКП оптужбу за продужено кривично дело лажно пријављивање из чл. 205. ст. 1. КЗ РС, одбио услед застарелости кривичног гоњења.

На правилност одлуке о одбијању оптужбе нема утицаја квалификација овог кривичног дела као продуженог кривичног дела, с обзиром да је кривично дело лажно пријављивање по оптужном акту извршено 25.01.2005. године, а касније поновљена радња пријављивања истог дела 11.11.2005. године, подношењем пријаве овлашћеном тужиоцу за исти догађај, нема утицаја на означено време извршења прве радње кривичног дела, јер је кривично дело лажно пријављивање из чл. 205. ст. 1. КЗ РС тренутно кривично дело код кога последица настаје одмах по остваривању радње извршења дела, тако да је самим пријављивањем оштећене од стране окривљеног З.Ђ. дело свршено.

(Пресуда Основног суда у Нишу 11К.бр. 5951/10 од 29.12.2010. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр. 1046/11 од 27.09.2011. године)

Приредио: судија Братислав Крстић.

**ИЗМЕНА МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОБАВЕЗНОГ
ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ЛЕЧЕЊА И ЧУВАЊА
У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
(Чл. 510. ст. 1. и ст. 4. ЗКП)**

Одлука о измени мере безбедности обавезног психијатријског лечења доноси се у седници већа уз обавештавање странака и по са слушању учиниоца.

Из образложења:

Увидом у списе предмета се утврђује да не постоји записник са седнице већа на којој је одлучивано о измени мере безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи у меру лечења на слободи. Одредбом чл. 510. ст. 4. Законика о кривичном поступку прописано да се одлуке доносе у седници већа о којој се обавештавају јавни тужилац и бранилац а да ће се пре доношења одлуке саслушати учинилац ако је то потребно и могуће. Како је првостепени суд одлучивао о предлогу за преиначење изречене мере безбедности у седници већа о којој није

обавестио напред наведена лица, тиме је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. Законика о кривичном поступку.

(Решење Вишег суда у Врању Кв. бр. 30/11 од 02.09.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж.2.бр. 910/11 од 26.09.2011. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

ОЦЕНА ОДБРАНЕ ДАТЕ ЋУТАЊЕМ ОПТУЖЕНОГ

(Чл. 89. ст. 2. ЗКП)

Ћутање оптуженог може да се оцени једино као порицање извршења кривичног дела.

Из образложења:

Неприхватљив је закључак првостепеног суда на страни шест, у петом ставу образложења пресуде, у коме утврђује да је оптужени таблете држао ради продаје, тако што при оцени и провери одбране оптуженог налази да се у поступку истраге оптужени бранио ћутањем и да је то околност која указује да није имао шта да каже у своју одбрану. На тај начин првостепени суд резултат оцене одбране окривљеног који није желео да одговара на постављена питања нити да износи одбрану у поступку истраге, сврстава у разлоге за утврђење веће количине психоактивних супстанци и њихову намену даље продаје. Одредбом чл. 89. ст. 2. Законика о кривичном поступку одређена је садржина поука коју суд упућује окривљеном при његовом саслушању, између осталог да није дужан да износи своју одбрану нити да одговара на постављена питања, а одредбом чл. 320. ст. 2. и 3. ЗКП којим је регулисан ток главног претреса, поновљена су права оптуженог и то да није дужан да се изјасни о одбрани нити да износи своју одбрану а уколико одбије да одговори на питања да ли је учинио кривично дело за које је оптужен и да ли жели да се изјасни о оптужби и да изнесе своју одбрану, то одбијање сматраће се порицањем. Разлози првостепеног суда о оцени одбијања оптуженог да да одбрану су неприхватљиви јер одбрана дата на наведени начин може само једино да се тумачи као порицање извршења кривичног дела, тим пре што је на главном претресу оптужени дао исцрпну и детаљну одбрану коју је првостепени суд био дужан да у потпуности провери а да затим изврши њену оцену. Правилима Законика о кривичном поступку прописана су права која припада-

ју оптуженом на главном претресу а као најважније да изнесе своју одбрану, што подразумева и да се брани ћутањем.

(Пресуда Вишег суда у Лесковцу К.бр. 120/10 од 10.05.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр. 1887/11 од 06.09.2011. године).

Приредио: судија Братислав Крстић.

МЕСНА НАДЛЕЖНОСТ

(Чл. 27. ст. 2. Законика о кривичном поступку)

Месно надлежан суд за поступање за кривична дела против части и угледа која су извршена на подручју више судова, установљава се, уколико поступак није започет по суду коме је прво поднет захтев за покретање поступка.

Из образложења:

По оцени Апелационог суда у Нишу, основано се у жалби пуномоћника приватних тужилаца указује да је првостепени суд погрешно утврдио чињенично стање када је донео побијано решење, што је условило и погрешну примену закона. Наиме, чл. 27. ст. 1. Законика о кривичном поступку прописано је да је месно надлежан по правилу суд на чијем подручју је кривично дело извршено или покушано, а у ставу 2. истог члана прописано да ако је дело извршено или покушано на подручјима разних судова или на граници тих подручја или је неизвесно на ком је подручју извршено или покушано, надлежан је онај од тих судова који је по захтеву овлашћеног тужиоца први започео поступак, а ако поступак још није започет – суд коме је прво поднесен захтев за покретање поступка, док је чл. 17. ст. 1. Кривичног законика прописано да је кривично дело извршено како у месту где је извршилац радио или био дужан да ради, тако и у месту где је у целини или делимично наступила последица дела.

На основу свега изнетог, за кривична дела против части и угледа која су извршена на подручју разних судова, на основу чл. 27. ст. 2. Законика о кривичном поступку, месно је надлежан суд коме је прво поднета кривична тужба, а то је у овом случају Основни суд у Нишу. Наиме, Основни суд у Нишу је месно надлежан за поступање у кривичном предмету против окривљеног В.М. јер су приватни тужиоци пресуду примили

у А. тако да је и евентуална последица извршених кривичних дела која му се стављају на терет наступила у А. а како је приватна тужба прво поднета Основном суду у Нишу јер се окривљеном ставља на терет да је кривично дело учинио писаним путем, у конкретном случају место где је последица наступила јесте место у коме је увредљива изјава сазната од онога коме је упућена или од неког трећег лица.

(Решење Основног суда у Нишу 12К. 2018/11 од 19.07.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж.2.бр. 838/11 од 02.09.2011. године)

Приредили: судија Братислав Крстић
и судијски помоћник Марија Димитријевић

СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА

(Члан 7. ст. 1. Законика о кривичном поступку)

У Републици Србији у кривичном поступку је у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо. Други језици и писма службено се употребљавају у складу са законом.

Из образложења:

Апелациони суд указује да је првостепени суд дужан да приликом писмене израде пресуде правилно примењује одредбу чл. 10. Устава Републике Србије и чл. 7. ст. 1. Законика о кривичном поступку којима је прописано да је у Републици Србији, односно у кривичном поступку у службеној употреби српски језик и ћирилично писмо а да се други језици и писма службено употребљавају у складу са законом. Како је Законом о службеној употреби језика и писма прописан начин службене употребе латиничног писма, то је потребно да првостепени суд испита да ли су у конкретном случају испуњени законски услови да се кривични поступак и писмена израда пресуде израђују латиничним писмом.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр. 789/10 од 23.03.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу 4Кж.1.бр. 1351/11 од 29.08.2011. године)

Приредили: судија Братислав Крстић
и судијски помоћник Марија Димитријевић

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 9. И У ВЕЗИ ЧЛАНА 382.
ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
(Члан 368. ст. 1. тач. 9. ЗКП)**

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 9. у вези чл. 382. Законика о кривичном поступку, јер је на штету оптуженог, након укидања претходне пресуде само по жалби браниоца оптуженог, првостепени суд по одржаном главном претресу на основу утврђеног чињеничног стања, прихватио прецизирање оптужнице ВЈТ и у изреци пресуде додао радњу извршења кривичног дела која није обухваћена оптужницом.

Из образложења:

Побијана пресуда је захваћена наведеном битном повредом одредаба кривичног поступка и забраном преиначења на штету оптуженог М.С. у погледу утврђивања чињеничног стања које се ставља на терет оптуженом. До укидања раније пресуде дошло је само по жалбама бранилаца оптужених, након чега је овлашћени тужилац дана 14.05.2010. г. прецизирао оптужницу према оптуженом М.С. тако што је на основу утврђеног чињеничног стања са главног претреса и обављеног вештачења физичко хемијског састава пронађене опојне дроге у возилу оптуженог М.С. усагласио диспозитив оптужнице према оптуженом М.С. тако што је овом оптуженом ставио на терет радњу извршења држањем ради продаје три куглице хероина пронађених испод седишта сувозач, односно делом радње из оптужнице према оптуженом М.С. за који је оптужени М.С. изреком побијане пресуде оглашен кривим. Додати нови део чињеничног описа радњи извршења кривичног дела на штету оптуженог М.С. не представља проширење оптужнице на ново кривично дело с обзиром да се ради о чињеничном тврђењу и опису радње из првобитне оптужнице овлашћеног тужиоца, па је стога у том делу побијана пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 9. у вези чл. 382. ЗКП.

У смислу одредбе чл. 394. ст. 4. ЗКП, забрана из чл. 382. ЗКП, вреди и ако се на новом главном претресу утврди другачије чињенично стање које је, као у овом случају на штету оптуженог. Ова забрана важи за суд, а не за тужиоца, тако да је побијаном пресудом првостепени суд начинио битну повреду поступка, јер је утврдио другачије чињенично стање и на

штету оптуженог у односу на првобитну оптужницу Вишег јавног тужиоца. Због тога је Апелациони суд оптуженог М.С. огласио кривим по првобитној оптужници и на тај начин отклонио наведену битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 9. ЗКП. Апелациони суд налази да на овај начин утврђено чињенично стање по измењеној оптужници не може бити узето у обзир као основу за нову пресуду без обзира што докази изведени на главном претресу указују да то чињенично стање стоји и да је утврђено.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 2К.бр. 127/10 од 03.06.2010. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.І.бр. 3439/10 од 20.05.2010. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 9. И У ВЕЗИ ЧЛАНА 382.
ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
(Члан 368. ст. 1. тач. 9. ЗКП)**

Пресуда првостепеног суда није донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 9. у вези чл. 382. ЗКП и поступак није захваћен забраном преиначења на штету оптуженог у погледу изрицања кривичне санкције уколико је претходна пресуда укинута по жалби браниоца оптуженог а о жалби тужиоца на одлуку о изреченој казни другостепени суд није одлучивао.

Из образложења:

Оцењујући побијану пресуду у делу који се односи на оптуженог М.С. Апелациони суд налази да се неосновано жалбом браниоца оптуженог указује да је пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 9. у вези чл. 382. Законика о кривичном поступку, односно да је поступак захваћен забраном преиначења на штету оптуженог, јер је решењем Врховног суда Србије у Београду Кж.І.бр. 16/09 од 05. фебруара 2009. године уважавањем жалби браниоца оптуженог М.С. и браниоца оптуженог М.С. укинута пресуда Окружног суда у Нишу К.бр. 206/07 од 04.04.2008. године и предмет враћен на поновно суђење а да је

против исте пресуде изјављена и жалба Окружног јавног тужиоца само због кривичне санкције која није разматрана у другостепеном поступку.

Из наведених околности укидања раније првостепене пресуде, по оцени Апелационог суда погрешан је закључак жалбе да је постојала само жалба у корист оптуженог и да је на тај начин поступак био захваћен забраном преиначења на штету оптужених тако да првостепени суд није могао да после изрицања казне затвора оптуженом М.С. у трајању од 2-две године и 3-три месеца побијаном пресудом изрекне овом оптуженом казну затвора у трајању од 3-три године која је строжа с обзиром на дужину трајања.

Одредбом чл. 382. ЗКП прописано је да ако је жалба изјављена само у корист оптуженог да пресуда не сме да се измени на његову штету у погледу правне квалификације и кривичне санкције. У овом случају је тачно да је по жалби у корист оптуженог укинута ранија првостепена пресуда, али постојала је жалба овлашћеног тужиоца против раније пресуде која није могла бити разматрана с обзиром на утврђене битне повреде поступка и укидање првостепене пресуде. Чињеница да жалба овлашћеног тужиоца против првостепене пресуде није разматрана и првостепена пресуда по њој није укинута не значи да жалба није постојала, што не стоје наводи жалбе браниоца оптуженог да је побијана пресуда захваћена забраном из чл. 382. ЗКП.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 2К.бр. 127/10 од 03.06.2010. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр. 3439/10 од 20.05.2010. године)

Приредио: судија Братислав Крстић

ОШТЕЋЕНИ КАО ТУЖИЛАЦ (Чл. 60. ЗКП)

Неодазивање оштећеног као тужиоца на уредан позив истражног судије не повлачи обуставу поступка, каква се одлука доноси само уколико оштећени као тужилац пропусти да дође на главни претрес.

Из образложења:

Решењем истражног судије Општинског суда у С. обустављена је истрага против осумњиченог Г.М. за кривично дело тешка телесна повре-

да из чл. 53. ст. 1. КЗ РС, по захтеву за спровођење истраге оштећеног као тужиоца РД, на основу чл. 253. ЗКП у вези чл. 63. ст. 1. и 64. ст. 1. ЗКП.

Оштећени као тужилац је благовремено поднео предлог за повраћај у пређашње стање за случај да исти не буде усвојен има се сматрати жалбом.

Решавајући о предлогу оштећеног као тужиоца, Веће првостепеног суда из чл. 24. ст. 6. ЗКП одбацило је предлог оштећеног за повраћај у пређашње стање као недопуштен и истовремено се огласило стварно ненадлежним за одлучивање о жалби оштећеног.

У жалби оштећеног као тужиоца основано се истиче да је решење истражног судије незаконито и да је повређена одредба чл. 63. ст. 1. ЗКП.

Наиме, наведена одредба санкционише одређено понашање оштећеног као тужиоца уколико пропусти да дође на главни претрес, иако је уредно позван или му се позив за главни претрес није могао уручити због непријављивања суду промене адресе или боравишта.

Из наведене формулације одредбе чл. 63. ст. 1. ЗКП, јасно произилази да се претпоставка одустанка од гоњења оштећеног као тужиоца односи само на главни претрес а не на претходну фазу кривичног поступка.

Према томе, по ставу овог суда истражни судија није имао законско овлашћење да због изостанка оштећеног као тужиоца да присуствује саслушању осумњиченог обустави истрагу против осумњиченог па и под претпоставком да је оштећени уредно позван, због чега је побијано решење укинута.

(Решење истражног судије Општинског суда у Сурдулици Ки.бр. 25/08 од 1.05.2009. године, решење истог суда Кв.бр. 50/09 од 31.08.2009. године, решење Апелационог суда у Нишу Кж2.бр. 72/10 од 12.02.2010. године)

Приредио: судија Слободан Стојилковић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Пресуда која се своди на констатацију да је "чињенично стање утврђено као у изреци" је пресуда без образложења, јер је изрека пресуде само супстрат утврђеног чињеничног стања.

Из образложења:

Првостепена пресуда донета је уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, јер је чињенично стање сведено на изреку (став први на страни 3 образложења), констатацијом да је "чињенично стање утврђено као у изреци" је пресуда без образложења. Изрека пресуде је само супстрат утврђеног чињеничног стања а чињенично стање је једна шира целина која се мора утврдити.

У побијаној пресуди недостаје оцена чињеничног стања, при чему првостепени суд није изнео које чињенице и из којих разлога узима као доказане или не па у образложењу пресуде најпре наводи одбране окривљених а онда исказе саслушаних сведока и писмене доказе из којих је "сазнао", ближе наведене чињенице. Само "сазнање" неких чињеница из проведених доказа не значи да су оне и утврђене. Из одређених доказа могу се "сазнати", исказати, "објаснити" одређене чињенице, што не значи да су оне и утврђене, да би као такве биле прихваћене.

Одредбе чл. 361. ст. 6. и 7. ЗКП, односе се на образложење пресуде и у њима је јасно наведено шта образложење мора да садржи. У том смислу, након презентирања одбране окривљеног и навођења доказа који су изведени на главном претресу, врши се њихова оцена и то сваког доказа појединачно и свих изведених доказа заједно, на који начин се образлаже чињенични основ пресуде а потом се чињенични закључци подводе под одговарајућу правну норму и износе правни разлози пресуде.

Само на овај начин и код овако израђене првостепене пресуде Апелациони суд, у поступку по жалби је у могућности да провери правилност и законитост пресуде, што овде није у могућности, па је пресуда првостепеног суда укинута.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 2К.бр.2360/10 од 26.04.2010. године Решење Апелационог суда у Нишу Кж1. бр.3271/10 од 02.02.2011. године).

Приредио: судија Слободан Стојилковић

**ПРЕКОРАЧЕЊЕ ОПТУЖБЕ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА
ТЕШКО ДЕЛО ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ
ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА**

Учињена је битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 8. ЗКП када првостепени суд код кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 3. у вези чл. 289. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ у чињенични опис радње не унесе повреду чл. 45. ст. 1. ЗООБС-а за коју је окривљени оптужен и окривљеном стави на терет повреду чл. 30. ст. 1. ЗООБС-а.

Из образложења:

Испитујући побијану пресуду у смислу чл. 380. ст. 1. тач. 1. ЗКП Апелациони суд је нашао да је иста захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 8. ЗКП.

Наиме, одредбом чл. 351. ст. 1. ЗКП прописано је да се пресуда може односити само на дело које је предмет оптужбе у поднесеној, односно измењеној или проширеној оптужници. У конкретном случају првостепени суд је окривљену К.С. огласио кривом због кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 3. у вези чл. 289. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ зато што је критичном приликом поступила супротно чл. 30. ст. 1. и чл. 68. ст. 1. тач. 2. ЗООБС-а.

Како је окривљеној оптужним предлогом јавног тужиоца стављено на терет да је критичном приликом поступила противно одредби чл. 45. ст. 1. и чл. 68. ст. 1. тач. 2. ЗООБС-а, првостепени суд је прекорачио оптужбу јер је окривљену огласио кривом и за повреду прописа за коју није оптужена, због чега је укидање пресуде било нужно.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 1К.бр.110/10 од 14.07.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.3592/10 од 30.08.2011. године)

Приредила: виши судијски помоћник Ивана Лазовић

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 9. ЗКП**

Првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368. ст. 1. тач. 9. ЗКП, о којој Апелациони суд води рачуна по службеној дужности, када је након укидања првостепене пресуде којом је окривљена оглашена кривом због кривичног дела клевете из члана 171. ст. 1. КЗ и осудио је на новчану казну у износу од 10.000,00 динара, где је жалба изјављена само у корист окривљене, донео нову пресуду којом је окривљену поново огласио кривом због кривичног дела клевете из члана 171. ст. 1. КЗ и осудио је на новчану казну у износу од 100.000,00 динара.

Из образложења:

У конкретном случају првостепени суд је окривљену С.В., пресудом К.бр.257/07 од 23.2.2009. године, огласио кривом за кривично дело клевете из чл. 171. ст. 1. КЗ и осудио на новчану казну у износу до 10.000,00 динара. Против те пресуде жалбе су изјавили само окривљена и њен бранилац, па је Окружни суд у Врању, као другостепени, уважавањем изјављених жалби укинуо наведену пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење. Доношењем нове пресуде К.бр.2425/10 од 18.06.2010. године којом је окривљена С.В. оглашена кривом за кривично дело клевете из чл. 171. ст. 1. КЗ, и осуђена на новчану казну од 100.000,00 динара, првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 9. ЗКП јер је пресуду изменио на штету окривљене Стојковић Верице у погледу висине изречене кривичне санкције поступајући противном одредби чл. 382. ЗКП. Стога је Апелациони суд на основу чл. 391. ст. 1. ЗКП преиначио првостепену пресуду у погледу одлуке о казни и окривљену С.В. осудио на новчану казну у износу од 10.000,00 динара, на коју је била осуђена и пресудом К.бр.257/07 од 23.02.2009. године и тиме отклонио учињену битну повреду одредаба кривичног поступка.

(Из пресуде Основног суда у Врању К.2425/10 од 18.6.2010. г. и Апелационог суда у Нишу 12Кж1. 1183/11 од 15.4.2011. године)

Приредио: судија Зоран Поповић

БИТНА ПОВРЕДА ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 10. ЗКП

Нема битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, када је првостепени суд без сагласности странака прочитао исказ сведока Х.П. обзиром да су за то испуњени услови из члана 337. ст. 1. тач. 1. ЗКП.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Нишу 6К.бр.2706/10 од 03.6.2011. године, окривљени К.Н. је у тачки првој изреке пресуде оглашен кривим због кривичног дела изазивање опште опасности из чл. 278. ст. 1. КЗ.

Неосновано се жалбом браниоца окривљеног К.Н. указује да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП тиме што је супротно одредби чл. 309 ЗКП прочитао исказ сведока Х.П. из Ниша иако није имао сагласност окривљеног и браниоца сходно чл. 331. ст. 1. ЗКП и зато што нису били испуњени законски услови обзиром да је сведок могао да се пронађе преко полицијске управе у Нишу. Ово због тога што одредба чл. 337. ст. 1. тач. 1. ЗКП предвиђа да записници о исказима сведока се могу по одлуци већа прочитати у случају да се саслушана лица не могу пронаћи. За читање таквих исказа није неопходна сагласност странака а у конкретном случају су били испуњени сви законски услови да се поступи по одредби чл. 337. ст. 1. тач. 1. ЗКП обзиром да се сведок Х.П. није могао пронаћи упркос бројним покушајима првостепеног суда који је издавао и наредбе за његово довођење по којим није поступљено, са извештајем да је одсељен са дате адресе на непознату адресу. По налажењу Апелационог суда није неопходно да полицијска управа утврди да се сведок налази у иностранству, како погрешно закључује бранилац окривљеног К. Н. већ је довољно да се он не може пронаћи како је то изричито прописано у одредби чл. 337. ст. 1. тач. 1. ЗКП.

(Из пресуде Основног суда у Нишу 6К.бр.2706/10 од 03.6.2011. године и Апелационог суда у Нишу 12Кж1. 2479/11 од 05.10.2011. године)

Приредио: судија Зоран Поповић

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 11. ЗКП**

Изрека пресуде је неразумљива јер је првостепени суд оптужене огласио кривим за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ, а да при томе, осим навода да су оптужени поступали као група, нема чињеничног описа из кога би произишло да су оптужени заиста поступали у групи.

Из образложења:

Пресудом Вишег суда у Врању К.бр.191/10 од 17.11.2010. године, оптужени Х.Р., М.Ј. и Д.Д. оглашени су кривим због продуженог кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. ст. 3. у вези ст. 1. у вези члана 33. Кривичног законика и осуђени на казне затвора у трајању од по осам година у коју им се урачунава време проведено у притвору почев од 21.5.2010. године. Апелациони суд је уважавањем жалби бранилаца оптужених укинуо побијану пресуду због постојања битних повреда одредаба кривичног поступка из члана 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП.

Неразумљивост изреке првостепене пресуде се по налажењу Апелационог суда састоји у томе што, осим навода да су оптужени поступали у групи, нема чињеничног описа из кога би произишло да су оптужени у конкретном случају заиста поступали у групи. Апелациони суд сматра да није довољно да се у изреци пресуде наведе да су оптужени поступали у групи да би се огласили кривим за квалификован облик предметног кривичног дела из члана 246. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ. Ово због тога што из описа радњи извршења предметног кривичног дела мора да произилази да су се оптужени повезали ради трајног или повременог вршења кривичних дела, те да из описа произилази међусобна условљеност и повезаност радњи сваког од чланова групе.

(Пресуда Виши суд у Прокупљу К.бр.197/10 од 17.11.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу 12Кж1. 1654/11 од 19.8.2011. године.)

Приредио: судија Зоран Поповић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Нејасна је изрека пресуде уколико је радња извршења крив. дела у чињеничном опису опредељена као напад на службена лица у вршењу послова јавне безбедности у смислу инкриминације из чл. 323. КЗ а опис предузетих радњи од стране окривљених упућује на радњу спречавања службеног лица у вршењу службене радње у смислу инкриминације из чл. 322. КЗ.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Нишу 6 К.бр.156/10 од 22.03.2010. године окр. М.М и окр. М.С, оглашени су кривим за по једно кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из чл. 323. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ.

Поводом жалбе Основног јавног тужиоца у Нишу и заједничке жалбе окривљених и њиховог браниоца, првостепена пресуда је укинута по службеној дужности јер је заснована на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП која се огледа у томе што је изрека пресуде нејасна и противречна сама себи.

Наиме, у чињеничном опису дела у изреци побијане пресуде, радња извршења опредељена је као напад на службена лица у вршењу послова јавне безбедности у смислу инкриминације из чл. 323. КЗ али опис предузетих радњи упућује на радњу спречавања службених лица у вршењу службене радње у смислу инкриминације из чл. 322. КЗ. Конкретно, полицијски службеници су према чињеничном опису дела интервенисали по пријави ремећења јавног реда и мира и захтевали од окривљених да не вичу и предају им своје личне карте ради идентификације, што су они одбили и физички насрнули на оштећена службена лица. Дакле, окривљени су свако за себе употребом физичке силе онемогућили службена лица да предузму конкретну службену радњу.

У контексту наведеног ваља указати да напад на службена лица у вршењу службене дужности није у функцији спречавања конкретне службене радње, већ су сила или претња као средство напада управљена према службеним лицима у време када не спроводе службену радњу и не вр-

ше службену дужност при чему је без значаја да ли се и како напад одрази она вршење службе.

(Пресуда Основног суда у Нишу 6 К.бр.156/10 од 22.03.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1 бр.3382/10 од 13.05.2011. године)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

НЕДОЗВОЉЕНА ЖАЛБА

(Чл. 387. ЗКП)

Недозвољена је жалба против решења којим се одбија захтев за издвајање записника и обавештења из списка предмета.

Из образложења:

Решењем Основног суда у Нишу 10 К.бр.7519/10 од 08.04.2011. године одбијен је предлог браниоца окривљеног П.Н да се из списка предмета издвоје кривична пријава ПУ Ниш бр. 2108/10 од 13.09.2010. године и пет записника о препознавању лица ПУ Ниш бр. 2108/10 од 16.09.2010. године.

Жалба браниоца окривљеног је недозвољена и поред тога што је у првостепеном решењу наведено упутство о правном леку. Наиме, одредбом чл. 337. ст. 3. ЗКП прописано је да су против решења о издвајању записника и обавештења дозвољена посебна решења. Како је у конкретном случају одбијен предлог браниоца окривљеног за издвајање из списка предмета кривичне пријаве и пет записника о препознавању лица а наведеном одредбом није прописана могућност подношења посебне жалбе против таквог решења, Апелациони суд налази да је жалба по закону недозвољена. Поред тога, побијано решење је донето на главном претресу ради припремања пресуде па се исто може побијати само жалбом на пресуду у смислу одредбе чл. 398. ст. 3. ЗКП. Одлуком овог суда нису повређена права окривљеног обзиром да у случају осуђујуће пресуде, исту може побијати по основу из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП.

(Решење Основног суда у Нишу 10 К.бр.7519/10 од 08.04.2011 и решење Апелационог суда у Нишу 11 Кж.2 бр.639/11)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА
КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
(Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)**

Уколико је окривљени ослобођен од оптужбе на основу чл. 355. тач. 2. ЗКП јер није доказано да је учинио кривично дело а у образложењу пресуде су изнети разлози да дело које је предмет оптужбе није кривично дело, по чл. 355. тач. 1. ЗКП, првостепена пресуда је заснована на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, обзиром да је изрека пресуде противречна изнетим разлозима у погледу основа ослобођења од оптужбе.

Из образложења:

Пресудом Општинског суда у Сурдулици К.бр.284 /08 од 20.11.2009. године, окривљени Р.К на основу чл. 355. тач. 2. ЗКП ослобођен је оптужбе да је учинио кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила из чл. 213. ст. 1. КЗ.

Уважавањем жалбе Општинског јавног тужиоца, првостепена пресуда је укинута јер је заснована на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП. Наведена повреда кривичне процедуре огледа се у томе што је изрека у супротности са датим разлозима у погледу основа за ослобођење од оптужбе. Наиме у изреци побијане пресуде првостепени суд се позива на одредбу чл. 355. тач. 2. ЗКП, тј. да није доказано да је окривљени извршио кривично дело неовлашћено коришћење туђег возила из чл. 213. ст. 1. КЗ а у образложењу износи разлоге за ослобођење од оптужбе по основу из чл. 355. тач. 1. ЗКП у смислу да дело које је предмет оптужбе није кривично дело, цитат "...у описаним радњама нису садржана обележја бића кривичног дела из чл. 213. КЗ које му се ставља на терет...".

У контексту наведеног потребно је указати да извршилац по наведеном основу може бити ослобођен од оптужбе уколико чињенични опис дела не садржи неко од законских обележја кривичног дела или нема кривичног дела због постојања околности које искључују противправност дела или кривицу иако чињенични опис садржи сва обележја која опредељују биће предметног кривичног дела (чл. 18. – чл. 21, чл. 22, 28. и 29. Кривичног законика) у ком случају ће чињенични опис бити

уподобљен утврђеним околностима које упућују на непостојање кривичног дела – чл. 14. ст. 2. КЗ.

(Пресуда Општинског суда у Сурдулици К.бр.284/08 од 20.11.2009 године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1 бр. 3094/10 од 23.03.2011 године)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

**ИМОВИНСКО ПРАВНИ ЗАХТЕВ
КАО ОСНОВ ПОБИЈАЊА ПРЕСУДЕ
(Чл. 367. тач. 4. ЗКП)**

Јавни тужилац није овлашћен да првостепену пресуду побија због одлуке о имовинско правном захтеву, осим у случају ако је досуђен на штету мере одузимања имовинске користи.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Прокупљу 4 К.бр.626/10 од 18.10.2010. године окривљени Ђ.Љ. оглашен је кривим због кривичног дела из чл. 159. ст. 2. Закона о енергетици, осуђен на казну затвора од 30 дана и обавезан да оштећеном привредном друштву ЕД Прокупље плати на име штете 56.000 динара.

Жалбу је изјавио Основни јавни тужилац, на штету окривљеног због одлуке о казни а у његову корист због досуђеног имовинско правног захтева.

У корист окривљеног јавни тужилац може жалбу изјавити само на одлуке кривичноправног карактера обзиром да нема законског овлашћења да заступа имовински интерес окривљеног на главном претресу и у жалбеном поступку, осим у случају досуде имовинско правног захтева на штету мере одузимања имовинске користи.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 4 К.бр.626/10 од 18.10.2010 године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж 1 бр. 4227/10 од 18.03.2011 године)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП у вези чл. 56. и 57. КЗ)

Нејасна је изрека пресуде уколико је окривљени оглашен кривим због кривичног дела увреде из чл. 170. ст. 1. КЗ и осуђен на новчану казну у износу од 30.000 динара а није наведен основ ублажавања прописане новчане казне по чл. 56. КЗ, ни границе ублажавања зависно од назначења најмање мере за предметно кривично дело по чл. 57. ст. 1. тач. 7. КЗ.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Лесковцу Кж.бр.987/10 од 14.12.2010. године окривљена Б.С. оглашена је кривом због крив. дела увреде из чл. 170. ст. 1. Кривичног законика и осуђена на новчану казну у износу од 30.000 динара, са означањем рока плаћања исте и начина извршења у смислу чл. 51. ст. 2. КЗ.

Уважавањем жалбе браниоца окривљене првостепена пресуда је укинута обзиром да је заснована на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП. Наведена повреда кривичне процедуре због које се законитост и правилност пресуде не може испитати огледа у томе што је изрека првостепене пресуде нејасна а изостали су разлози о одлучним чињеницама.

Наиме, првостепени суд је окривљену Б.С. осудио на новчану казну у износу од 30.000 динара, ублажавањем по мери прописане новчане казне у распону од 40.000 динара до 200.000 динара. Међутим, првостепени суд у правној основици пресуде уопште не означава основ ублажавања прописане казне из чл. 56 Кривичног законика, да ли по тач. 1. када закон предвиђа такву могућност, по тач. 2. када закон предвиђа да се учинилац може ослободити од казне а суд то не учини или по тач. 3. кад се утврди да постоје нарочито олакшавајуће околности које оправдавају сврху кажњавања и ублаженом казном. Такође, у правној основици првостепени суд не одређује границе ублажавања казне у смислу чл. 57. ст. 1. тач. 7. Кривичног законика, зависно од назначења најмање мере, у конкретном случају 40.000 динара за предметно кривично дело. У контексту наведеног је изостанак разлога о одмеравању казне окривљеној као одлучној чињеници, обзиром да првостепени суд на стр. 4 само набраја олакшавајуће и отежавајуће околности које су од значаја за одмеравање казне у смислу

чл. 54. КЗ али не износи разлоге да минимални износ прописане новчане казне од 40.000 динара ублажи по мери осудом окривљене на новчану казну од 30.000 динара. Шта више, првостепени суд уопште у образложењу не помиње да је прописану новчану казну ублажио по мери, зашто и у којим законом одређеним границама.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу К.бр.987/10 од 14.12.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу 11 Кж.1 бр.1096/11 од 03.10.2011. године)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 2. ЗКП)

Уколико мишљење комисије вештака указује да је оптужени у време извршења кривичног дела боловао од психоорганске разградње личности - сенилности и да је болест прогресивног тока, првостепени суд је у обавези да пре почетка главног претреса утврди да ли је оптужени способан да износи одбрану, прати ток главног претреса и на сваки други начин заступа своје интересе и остварује своја права загарантована одредбом чл. 318. у вези чл. 4. ст. 2. тач. 2. у вези ст. 1. ЗКП.

Из образложења:

Пресудом Вишег суда у Пироту К.бр.39/10 од 03.12.2010 године оптужени Ж.М. оглашен је кривим због кривичног дела убиства из чл. 113. КЗ.

Уважавањем жалбе браниоца оптуженог првостепена пресуда је укинута јер је заснована на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 2. ЗКП обзиром да је оптуженом на главном претресу повређено право на одбрану што је у битном утицало на законитост и правилност првостепене пресуде.

У ситуацији када се сада оптужени од почетка претходног поступка налази на посматрању и лечењу у специјализованој установи и када мишљење комисије вештака прибављено пре оптужења недвосмислено указује да је у време извршења кривичног дела боловао од психоорганске

разградње личности (сенилност) и да је прогресивног тока, првостепени суд је био у обавези да пре почетка главног претреса путем психијатријског вештачења, утврди да ли је оптужени способан да износи одбрану, прати ток главног претреса и остварује своја права загарантована одредбом чл. 318. у вези чл. 4. ст. 2. тач. 2. у вези ст. 1. ЗКП, тим пре што из записника о главном претресу произилази да је председавајући судија тешко успостављала комуникацију са оптуженим због његове дезоријентисаности и душевног стања.

(Пресуда Вишег суда у Пироту К.бр.39/10 од 03.12.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу 4 Кж 1 бр. 62/11 од 23.03.2011. године)

Приредила: судија Мирјана Ђорђевић

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА СА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ЗЛОУПОТРЕБА СЛУЖБЕНОГ ПОЛОЖАЈА НА КРИВИЧНО ДЕЛО ПОСЛУГА

Уколико се врши измена правне квалификације са кривичног дела злоупотреба службеног положаја на кривично дело послуга, неопходно је утврдити да ли је код окривљеног постојала намера враћања или намера присвајања средстава.

Из образложења:

Наиме, првостепени суд је окривљену огласио кривом због продуженог кривичног дела послуга из чл. 252. КЗ РС, не прихватајући правну квалификацију из оптужнице и сматрајући да су се у њеним радњама стекли сви елементи овог кривичног дела, јер се она у својству ликвидатора у Комерцијалној банци АД Београд – Филијала Лесковац, послужила новцем оштећених, који је подизала са њихових текућих рачуна и пребацивала на текуће рачуне других лица и без одобрења оштећених подигла 300 чекова, које је попуњавала на максимални износ и ставила у промет, а новац користила за своје потребе. При томе је прихватио признање окривљене да је без одобрења оштећених са њихових текућих рачуна подигла новац који је користила за своје потребе, а који је касније враћала оштећенима готовинским уплатама, да је узети новац такође враћала преношењем са других текућих рачуна депонената као и да је попуњавала чекове

оштећених и ставила у промет. Првостепени суд је утврдио да је окривљена ово учинила самоиницијативно, јер јој оштећени за то нису дали овлашћење. Такође је првостепени суд на основу налаза и мишљења вештака финансијске струке, који је прихватио, утврдио да је окривљена подизала готов новац и преносила са једног текућег рачуна на други, да је подизала чекове оштећених, који су у већем делу реализовани, што је закључено и на основу исказа оштећених.

Међутим, овакви разлози првостепеног суда су нејасни и противречни, јер из одбране окривљене произилази да је она у наведеном периоду радила као ликвидатор у Комерцијалној банци, те да је долазила у контакт са новцем само када је мењала неког од благајника. Стога се основано жалбом Општинског јавног тужиоца истиче да окривљеној нису били поверени у раду новац и чекови, јер није радила као благајник и није располагала новцем, као и да је сама попуњавала чекове оштећених и исте уновчавала, без знања оштећених, због чега се доводи у сумњу закључак првостепеног суда, при чему није дато образложење за одлуку суда у погледу измене правне квалификације.

На овај начин, у конкретном случају, првостепени суд није утврдио све чињенице, које су битне за одлуку у овом кривичном предмету, а које се односе на то да ли у радњама окривљене стоје обележја кривичног дела послуга за које је оглашена кривом. Наиме, код овог кривичног дела ствар се само привремено узима, са намером враћања, дакле, код овог кривичног дела нема присвајања, нити намере да се себи или другоме прибави противправна имовинска корист. Из побијане пресуде не може се поуздано утврдити да ли је код окривљене постојала намера враћања или намера присвајања наведених средстава, с обзиром да је, према наводима оптужнице, сачињавала исправе са неистинитом садржином како би дошла до новца оштећених, што првостепени суд није ценио приликом доношења одлуке. Како се изреком побијане пресуде окривљена оглашава кривом да се неовлашћено послужила овим средствима, то је и изрека побијане пресуде неразумљива, због чега је првостепена пресуда морала бити укинута.

(Пресуда Општинског суда у Лесковцу К.бр.363/06 од 16.10.2008. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.767/10 од 25.01.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

**ИЗРЕКА ПРЕСУДЕ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО
ОМЕТАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА
У ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ
ИЛИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ РЕДА
И МИРА ИЗ ЧЛАНА 23. СТАВ 2.
ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ**

У изреци пресуде за кривично дело из чл. 23. Закона о јавном реду и миру, мора стајати о којим службеним радњама се ради, а које је из оквира послова безбедности или одржавања јавног реда и мира предузимао оштећени приликом интервенције.

Из образложења:

Изрека пресуде је неразумљива и из разлога што у опису радње извршења кривичног дела стоји да је окривљени на наведени начин ометао овлашћено службено лице у обављању послова безбедности, док је оглашен кривим за кривично дело ометање службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јавног реда и мира из чл. 23. ст. 2. у вези ст. 1. Закона о јавном реду и миру. На овај начин изрека пресуде је неразумљива, јер се не може утврдити о којим службеним радњама се ради, јер нису наведене конкретне службене радње које је из оквира послова безбедности или одржавања јавног реда и мира предузимао оштећени приликом интервенције. Ово се не може утврдити ни из образложења пресуде, где стоји да су службена лица ометана у обављању послова безбедности, без навођења о којим пословима се ради, а што је неопходно, јер се ради о кривичном делу са бланкетном нормом.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити недостатке на које је указано овим решењем, тако што ће најпре изреку пресуде учинити разумљивом, наводећи у потпуности све речи, које је окривљени критичном приликом упутио оштећеном и на одговарајући начин утврдити које радње се конкретно стављају на терет окривљеном. Такође ће навести које конкретне послове су критичном приликом предузимала овлашћена службена лица и по ком законском пропису су исти обављани. Затим ће извести све доказе за које сматра да су потребни, како би на поуздан начин утврдио да ли се у радњама окривљеног, како су описане у оптужном акту, стичу законска обележја кривичног дела ометање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или одржавања јав-

ног реда и мира из чл. 23. ст. 2. Закона о јавном реду и миру и које конкретне радње се односе на ово кривично дело.

(Пресуда Основног суда у Прокупљу 2К.бр.304/10 од 29.06.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.3041/10 од 24.03.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

ПРИМЕНА ЗАКОНА О МЕЂУНАРОДНОЈ ПРАВНОЈ ПОМОЋИ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА

Код трансфера осуђеног лица, потребно је утврдити да ли се кривично дело за које је осуђен у другој држави може правно квалификовати као кривично дело прописано домаћим законодавством.

Из образложења:

Применом одредбе чл. 534. ст. 2. у вези чл. 530. ст. 1. ЗКП, који се у овом случају примењује, према одредби чл. 103. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима, с обзиром да је молба за пружање међународне правне помоћи поднета пре ступања на снагу овог закона, првостепени суд је утврдио да се кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога извршено увозом у државу знатне количине опојне дроге, за које је оптужени осуђен у Мађарској, може правно квалификовати као кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 245. ст. 1. ОКЗ, за које је оптуженом изречена казна затвора у трајању од 5-пет година. Такође је утврђено да се кривично дело службено подмићивање службеног лица навођењем да учини прекршај у обављању својих службених дужности, може правно квалификовати као кривично дело давање мита из чл. 255. ст. 1. КЗ РС, за које му је изречена казна затвора у трајању од 3-три године и 1-један месец, након чега је применом чл. 48. ОКЗ осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 8-осам година, у коју му се урачунава време проведено у притвору, односно затвору почев од 19.02.2005. године па надаље.

Неосновано се жалбом оптуженог истиче да првостепени суд није применио најблажи закон, јер је одредбом чл. 246. ст. 1. Кривичног законика прописана казна затвора у трајању од 2-две до 12-дванаест година, док је од-

редбом чл. 245. ст. 1. ОКЗ прописана казна затвора у трајању од 1-једне до 10-десет година, што значи да је примењен закон који је блажи за оптуженог.

За кривично дело давање мита из чл. 255. ст. 1. КЗ РС, прописана је казна затвора у трајању од 6-шест месеци до 5-пет година, колика казна је прописана и одредбом чл. 368. ст. 1. КЗ, што значи да је првостепени суд и у овом случају правилно применио кривични закон, тако што је применио онај закон, који је важио у време извршења кривичног дела.

(Пресуда Вишег суда у Пироту Кв.бр.145/10 од 22.12.2010. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 2Кж.1.бр.286/11 од 14.04.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

ПРОДУЖЕЊЕ ПРИТВОРА И ПРИМЕНА ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 5. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА

Обезбеђена је примена начела расправности приликом одлучивања о притвору, када је пре одлучивања затражено писмено изјашњење окривљеног и његовог браниоца по предлогу истражног судије за продужење притвора.

Из образложења:

Побијано решење о продужењу притвора према окривљеном Саши Ђорђевићу је правилно и заснива се на правилној примени одредбе чл. 142. ст. 1. тач. 1. и 5. Законика о кривичном поступку, при чему је, у смислу одребе чл. 142а став 1. до 4. ЗКП, пре одлучивања о притвору, затражено изјашњење окривљеног и браниоца о предлогу истражног судије Вишег суда у Врању за продужење притвора, па је окривљени у свом поднеску навео да не жели да се изјашњава о овом предлогу, док се његов бранилац противио предлогу, наводећи да не стоје законски разлози за продужење притвора. На овај начин је обезбеђена примена начела расправности приликом одлучивања о притвору, што је у складу и са одредбом чл. 5. Европске конвенције о људским правима.

(Решење Апелационог суда у Нишу 2Кр.бр.26/11 од 02.06.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу 7Кж.2.бр.561/11 од 14.06.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

ОДБАЦИВАЊЕ ОПТУЖНИЦЕ

Уколико је наступила околност која привремено спречава кривично гоњење, оптужница се одбацује применом одредбе чл. 349. ст. 1. тач. 3. ЗКП.

Из образложења:

Основано се жалбом вишег јавног тужиоца у Нишу првостепена пресуда побија, наводима да првостепени суд није требало да донесе одбијајућу пресуду, већ да евентуално донесе решење о одбацивању оптужнице, у смислу чл. 349. тач. 3. ЗКП.

По оцени овог суда, првостепени суд је правилно утврдио на основу налаза и мишљења комисије лекара Специјалне болнице за психијатријске болести у Горњој Топоници, да оптужена болује од прогредијентног неуродегенеративног обољења мултипле склерозе и да се код ње развио психијатријски поремећај - трајна промена личности. Према мишљењу комисије вештака, у време извршења кривичног дела које јој се ставља на терет, код оптужене нису постојали знаци и симптоми било код телесног или психичког обољења, те је стога била у стању да схвати значај дела које јој се ставља на терет и да управља својим поступцима. Оптужена је и актуелно у стању да схвати значај дела које јој се ставља на терет, као и евентуалне правне последице и значај судског поступка. Закључак је да је оптужена приликом појављивања на главним претресима у стању да прати ток главног претреса, али да није способна да валидно изнесе своју одбрану.

На основу оваквог налаза и мишљења комисије вештака, првостепени суд је закључио да су у конкретном случају наступиле околности које трајно искључују кривично гоњење оптужене, због чега је према њој оптужбу одбио на основу одредбе чл. 354. ст. 3. ЗКП.

Међутим, по оцени овог суда, из налаза и мишљења комисије вештака не произилази да код оптужене постоје околности које трајно искључују кривично гоњење, већ да се ради о околностима које привремено спречавају гоњење оптужене. Ово из разлога што се из налаза и мишљења комисије вештака закључује да је код оптужене дошло до обољења које је настало после извршења кривичног дела које јој се ставља на терет, те да се ради о отклоњивим разлозима, који представљају околности, које привремено спречавају гоњење оптужене, с обзиром да је вештачењем утвр-

ђено да није способна да валидно износи своју одбрану, али да је у стању да прати ток главног претреса.

С обзиром на наведено, Апелациони суд је нашао да је у конкретном случају наступила околност која привремено спречава гоњење оптужене, па је према њој одбачена оптужница, применом одредбе чл. 349. ст. 1. тач. 3. Законика о кривичном поступку. Уколико престану сметње које привремено спречавају гоњење оптужене, поступак ће моћи да се настави на предлог овлашћеног тужиоца.

(Пресуда Вишег суда у Нишу 3К.бр.246/10 од 25.01.2011. године и пресуда Апелационог суда у Нишу 7Кж.1.бр.1079/11 од 19.04.2011. године)

Приредила: судија Горана Митић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Изрека првостепеног решења поред васпитне мере која се изриче малолетнику не сме да садржи чињенични опис и правну квалификацију кривичног дела.

Из образложења:

Првостепено решење је засновано на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, јер је изрека решења нејасна и неразумљива, не садржи законске одредбе на основу којих се доноси одлука о изрицању васпитне мере у конкретном случају, нити образложење решења садржи ваљане разлоге о одлучним чињеницама.

По ставу овог суда битна повреда одредаба кривичног поступка састоји се у томе што је у изреци побијаног решења, поред васпитне мере која се изриче малолетном лицу наведен и опис дела и правна квалификација кривичног дела, супротно одредби чл. 78. ст. 3. ЗМ. Такође, супротно овој одредби, веће за малолетнике првостепеног суда у образложењу решења не наводи чињенични опис дела које је малолетнику стављено на терет већ се само позива на проведене доказе, при чему је у побијаном решењу изостало и навођење садржине изведених доказа и оцена истих, па

и навод и оцена околности из којих произилази да су изрицање и примена одређене васпитне мере оправдани.

Будући да се ради о апсолутно битним повредама кривичног поступка на које је основано указано жалбом, а на које овај суд као другостепени увек пази по службеној дужности, првостепено решење је морало бити укинато.

(Решење Вишег суда у Нишу IКм. бр. 21/10 и решење Апелационог суда у Нишу Кжм.1.бр.4/2010 од 16.3.2010.)

Аутор: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Када се доноси решење о одређивању притвора у изреци се мора јасно навести основ за одређивање притвора, а у образложењу морају бити прецизно наведене околности које оправдавају основ за одређивање притвора.

Из образложења:

Побијано решење захваћено је битном повредом одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, обзиром да је изрека решења неразумљива, противречна сама себи и разлозима решења, а решење нема разлога о одлучним чињеницама.

Наиме, у образложењу побијаног решења, првостепени суд утврђује се да су испуњени услови предвиђени одредбом чл. 142а ст. 1. ЗКП, јер је мал. А.Р. саслушан у својству окривљеног на главном претресу 1.3.2010. године, а да се из списка предмета утврђује постојање околности које указују на опасност од бекства окривљеног, чиме су испуњени услови предвиђени одредбом чл. 142. ст. 1. тач. 1. ЗКП.

Изрека побијаног решења је неразумљива јер се из исте не може утврдити основ за одређивање притвора према малолетнику, а такође образложење побијаног решења не садржи разлоге о одлучним чињеница-

ма, будући да се из образложења не може утврдити које су то околности које указују на опасност од бекства малолетника.

Иако је у образложењу решења наведено да су испуњени услови предвиђени одредбом чл. 142. ст. 1. тач. 1, чак без навођења закона који се примењује, осим навођења да постоји опасност од бекства малолетника у образложењу нису наведени разлози, којима се првостепени суд руководио при доношењу овакве одлуке односно из којих се околности утврђује да постоји опасност од бекства мал. А.Р.

Будући да наведени недостаци побијано решење чине мањкавим до те мере да се исто не може испитати, то је Апелациони суд предметно решење, уважавањем жалбе браниоца малолетника и по службеној дужности укинуо.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кжм.1.бр.8/2010 од 2.8.2010. године и решење Вишег суда у Прокупљу Км.бр.1/10 од 17.03.2010. године)

Аутор: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА (Чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП)

Одлука суда се не може заснивати на сведочењу полицајаца о сазнањима до којих су дошли у разговору са малолетником према коме се води поступак.

Из образложења:

Првостепено решење је засновано на битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, имајући у виду да је одлука заснована на доказима на којима се по одредбама овог законика не може заснивати. Наиме, првостепени суд је одлуку засновао на исказима сведока С.Н. и Н.В. са навођењем садржине исказа ових сведока који су се изјашњавали на околности шта им је малолетни, сада пунолетни С.З. рекао, уз образложење да иако су исти поступали као полицајци, суд за-

снива своју одлуку на њиховим исказима из разлога што исти нису предузимали службене радње.

Из списка произилази да је сведок С.Н. управо подносилац пријаве за прекршај у вези са конкретним догађајем и да је он обезбеђивао лице места након критичног догађаја, а да је сведок Н.В. по овлашћењу истражног судије извршио увиђај ове саобраћајне незгоде и сачинио записник о увиђају, чији је и потписник, што се утврђује из записника о увиђају саобраћајне незгоде. Из напред наведеног произилази да се ради о службеним лицима – полицајцима, који су предузимали службене радње и да се на њиховим исказима, имајући у виду да су се изјашњавали на околности шта су сазнали од малолетног, сада пунолетног С.З., одлука суда не може заснивати, а изјављеном жалбом основано се указује на постојање ове битне повреде одредаба кривичног поступка.

Због наведене битне повреде која неизоставно доводи до укидања одлуке за сада ни чињенично правна утврђења ни правилност примене закона не могу бити испитани.

(Решење Вишег суда у Прокупљу Км.бр.1/10 од 17.03.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кжм.1.бр.8/2010 од 02.08.2010. године)

Аутор: Весна Стевановић,
судија апелационог суда у Нишу

ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ И ТРОШКОВИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

(Чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП)

Образложење одлуке о висини трошкова кривичног поступка мора да буде јасно, засновано на подацима у погледу броја одржаних рочишта у току припремног поступка и главних претреса.

Из образложења:

Основано се жалбом браниоца указује да чињенично стање у погледу одржаних припремних поступака и главног претреса није у потпуности и правилно утврђено и да је због тога одлука првостепеног суда о висини трошкова кривичног поступка нејасна.

По налажењу Апелационог суда првостепено решење не садржи разлоге у погледу броја одржаних и одложених рочишта, односно дати разлози су противречни броју заказаних рочишта, како то произилази из списка, а не садржи ни разлоге у погледу примене адвокатске тарифе и утврђивања појединачних и укупних износа трошкова кривичног поступка, због чега се одлука о трошковима не може испитати и прихватити као правилна.

У поновљеном поступку првостепени суд ће утврдити све одлучне чињенице за доношење правилне и законите одлуке о трошковима кривичног поступка. При томе, ће имати у виду број одржаних и одложених главних претреса и висину награде браниоца по адвокатској тарифи као и остале наводе жалбе и тек тада ће моћи да донесе правилну и закониту одлуку.

(Решење Апелационог суда у Нишу Кжм.2.бр.8/2010 од 25.3.2010. године и решење Вишег суда у Нишу IКм.бр.9/10 од 01.02.2010. године)

Аутор: Весна Стевановић,
судија Апелационог суда у Нишу

(Члан 394. ст. 4. Законика о кривичном поступку)

Оглашавањем оптуженог кривим за свршено дело тешке крађе из чл. 204. ст. 1. тач. 1. и 2. Кривичног законика, иако је претходном пресудом оглашен кривим за исто кривично дело у покушају, начињена је битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 9. ЗКП.

Из образложења:

Основано се жалбом браниоца оптуженог првостепена пресуда побија у погледу правне квалификације.

Наиме, пресудом К.бр.495/08 оптужени је оглашен кривим због кривичног дела тешка крађа у покушају из чл. 204. ст. 1. тач. 1. у вези чл. 203. ст. 1. у вези чл. 30. и 33. КЗ на коју је државни тужилац изјавио жалбу на штету оптуженог због одлуке о кривичној санкцији, и наведена пре-

суда је укинута решењем Кж.бр.118/09, због битних повреда одредаба кривичног поступка.

Како је побијаном новом пресудом оптужени оглашен кривим за свршено кривично дело тешка крађа из чл. 204. ст. 1. тач. 1. и 2. КЗ у вези чл. 203. ст. 1. у вези чл. 33. КЗ, то је учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 9. ЗКП.

(Пресуда Општинског суда у Пироту К.бр.296/09, а пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.1029/10).

Приредила: судија Драгана Живадиновић

ОДБИЈАЊЕ ОПТУЖБЕ

(Члан 354. ст. 1. Законика о кривичном поступку)

Услед недоласка приватног тужиоца на главни претрес оптужба се не одбија, већ се обуставља кривични поступак.

Из образложења:

Основано се жалбом приватног тужиоца, указује на то да је првостепени суд погрешно применио одредбе чл. 354. ЗКП, када је донео одбијајућу пресуду, јер приватни тужилац није одустао од оптужбе на главном претресу.

Наиме, чланом 354. Законика о кривичном поступку предвиђено је да ће суд изрећи пресуду којом се оптужба одбија, ако је тужилац од започињања до завршетка главног претреса одустао од оптужбе или је оштећени одустао од предлога за гоњење; ако је оптужени за исто дело већ правноснажно осуђен, ослобођен оптужбе или је оптужба против њега правноснажно одбијена или је поступак против њега решењем правноснажно обустављен; ако је оптужени актом амнестије или помиловања ослобођен од гоњења или се кривично гоњење не може предузети због застарелости или неке друге околности која трајно искључује кривично гоњење.

Из списка се утврђује да приватни тужилац није приступио на главни претрес, те је првостепени суд био дужан да утврди да ли је уредно позван и

ако јесте у смислу члана 59. Законика о кривичном поступку да сматра да је одустао од приватне тужбе, те да решењем обустави кривични поступак.

Првостепени суд није поступио у смислу наведених одредаба Законика, већ је погрешно применио одредбу чл. 354. ЗКП и одбио оптужбу, што је било од утицаја на законито и правилно доношење одлуке, па је на тај начин првостепени суд начинио битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. Законика о кривичном поступку.

(Пресуда Основног суда у Врању К.бр.1318/10, а решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.3891/10).

Приредила: судија Драгана Живадиновић

ОДБИЈАЊЕ ОПТУЖНОГ ПРЕДЛОГА У СМISЛУ ЧЛ. 441. СТ. 1. ЗКП

При испитивању оптужног предлога, суд није овлашћен да цени да ли чињенице и околности на којима се оптужни предлог заснива пружају поуздан доказ да су окривљени учинили кривично дело, нити да ли су испуњени услови да буду оглашени кривим.

Из образложења:

Првостепено решење је донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, на коју се основано указује жалбом јавног тужиоца, јер су наведени разлози којима се првостепени суд руководио кад је закључио да нема довољно доказа да су окривљени основано сумњиви за извршење кривичног дела које им се оптужним предлогом ставља на терет, нејасни.

Наиме, из списка предмета и побијаног решења произилази да се првостепени суд, приликом испитивања оптужног предлога, упустио у оцену доказа прикупљених у истрази – одбрана окривљених, исказа оштећеног и сведока, што у овој фази кривичног поступка није допуштено, те је закључио да нема довољно доказа да су окривљени основано сумњиви за кривично дело које им се оптужним предлогом ставља на терет и применом чл. 441. ст. 1. ЗКП у вези чл. 274. тач. 3. ЗКП је одбио оптужни предлог.

При испитивању оптужног предлога пре одређивања главног претреса и оцене довољности доказа, не цени се питање кривице, нити је суд овлашћен да се упушта у оцену противречних доказа и њихову анализу, већ то може учинити тек након контрадикторне расправе. У овој фази поступка суд само цени постојање основане сумње да су окривљени учинили кривично дело које им се оптужним актом ставља на терет. Дакле, при испитивању оптужног предлога, суд није овлашћен да цени да ли чињенице и околности на којима се оптужни предлог заснива пружају поуздан доказ да су окривљени учинили кривично дело, нити да ли су испуњени услови да буду оглашени кривим, а што се основано указује у жалби јавног тужиоца. Супротно разлозима првостепеног суда, у овој кривичној ствари је спроведена истрага по решењу о спровођењу истраге, што подразумева постојање основане сумње да су окривљени учинили кривично дело, па су став првостепеног суда и побијана одлука, погрешни.

Како из прикупљених доказа произилази основана сумња да су окривљени учинили кривично дело које им се оптужним предлогом ставља на терет, те како суд није био овлашћен да их у овој фази поступка цени, неопходно је да се ова кривична ствар расправи у контрадикторном поступку на главном претресу, након чега је могућа оцена одбрана окривљених и изведених доказа, када ће се утврдити чињенично стање, па и питање кривице окривљених.

(Пресуда Основног суда у Нишу 18 К.бр.9071/10 од 18.05.2011. године и Решење Апелационог суда у Нишу 8 Кж.2.бр.621/11 од 08.07.2011. године)

Обрадила судија Снежана Милошевић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 10. ЗКП

Одлука првостепеног суда се не може заснивати на исказима сведока - службених лица органа унутрашњих послова о ономе што им је окривљени као грађанин рекао.

Из образложења:

Првостепено решење је донето уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, на коју обе жалбе основано

указују, јер се решење заснива исказима сведока М.Р. и М.С., на којима се по одредбама овог Законика не може заснивати, те су разлози првостепеног суда за супротан став, неприхватљиви.

Наиме, побијано решење се, поред осталих доказа, заснива и на исказима сведока М.Р. и М.С., иначе овлашћених радника органа унутрашњих послова ПУ Врање, о обавештењима која им је дао окривљени. Из списка предмета и побијаног решења произилази да су ови сведоци, као овлашћена службена лица ПУ Врање, због озбиљности случаја и искуства, ангажовани да учествују у поступку откривања учиниоца овог дела, те да су поред других инспектора, са С.С., који је био приведен у ПУ Врање, разговарали на околности нестанка и убиства малолетне К.С. Током тог вишечасовног разговора ова два сведока су му постављала прво питања која нису везана за критични догађај, а потом и конкретна питања у вези критичног догађаја, након чега им је С.С. испричао оно о чему су они сачинили службену белешку. Том разговору није био присутан бранилац окривљеног.

Исказ службеног лица органа унутрашњих послова као сведока о непосредним запажањима и сазнањима о одлучним чињеницама је доказ у кривичном поступку, осим дела исказа који се односи на обавештења која је дао окривљени. Како се одлука у конкретној кривичној ствари заснива и на исказима наведених сведока као службених лица органа унутрашњих послова о ономе што им је окривљени као грађанин рекао, учињена је апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 10. ЗКП, која нужно повлачи укидање побијане одлуке.

Обавештења органа унутрашњих послова су докази на којима се одлука суда по одредбама ЗКП не може заснивати, јер су ти докази у смислу чл. 178. ст. 1. и 3. ЗКП морали да буду издвојени, а службена лица се не могу испитивати као сведоци о садржини обавештења која су издвојена. Доказ у кривичном поступку су само записници органа унутрашњих послова о саслушању осумњиченог које је обављено под условима из чл. 226. ст. 9. ЗКП.

(Пресуда Вишег суда у Врању К.бр.62/10 од 04.10.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1 бр.3997/10 од 23.02.2011. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 1. ЗКП**

Судија који није суделовао на главном претресу не може учествовати у изрицању пресуде.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 1. ЗКП, на коју се основано указује жалбом браниоца окривљеног М.С., а на коју и овај суд поводом изјављене жалбе увек пази по службеној дужности.

Ова повреда се састоји у томе што је у изрицању побијане пресуде учествовао судија који није суделовао на главном претресу. Наиме, у уводу побијане пресуде, у саставу већа, као председник већа наведена је судија В.Р., док је пресуду као председник већа потписао судија Р.Б. Из списка предмета произилази да је као председник већа у овој кривичној ствари све до 27.11.2008. године поступао судија Р.Б., а да је потом дошло до измене председника већа, те је на главном претресу дана 27.11.2008. године председавала судија В.Р.

Имајући у виду наведено, очигледно је да је у изрицању пресуде учествовао судија који није суделовао на главном претресу, па је, по оцени Апелационог суда, због учињене битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 1. ЗКП, побијана пресуда морала бити укинута.

(Пресуда Општинског суда у Прокупљу К.бр.1226/07 од 27.11.2008. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.1405/10 од 28.01.2011. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

**БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
ИЗ ЧЛАНА 368. СТАВ 1. ТАЧКА 11. ЗКП
– ИЗРЕКА ПРОТИВРЕЧНА САМА СЕБИ**

Када првостепени суд у изреци пресуде утврди тачан износ прибављене противправне имовинске користи, а потом оштећеног упуту на парницу, учинио је изреку противречном самој себи, али и разлозима датим у образложењу.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. Законика о кривичном поступку, на коју другостепени суд поводом изјављене жалбе увек пази по службеној дужности, јер је изрека пресуде неразумљива и противуречна и сама себи и датим разлозима.

Наиме, изрека првостепене пресуде је неразумљива и противуречна сама себи, јер је оштећена дрогерија "Л" Ниш упућена на парницу ради остваривања имовинскоправног захтева, иако је првостепени суд у изреци пресуде тачно утврдио висину прибављене противправне имовинске користи. Ова противречност не само да изреку пресуде чини неразумљивом и противречном самој себи, већ и супротној разлозима, јер и у образложењу пресуде првостепени суд даје разлоге о утврђеној висини противправне имовинске користи, а потом оштећену упућује на парницу сходно чл. 206. ст. 2. ЗКП, уз образложење да подаци кривичног поступка не пружају поуздан основ ни за потпуно ни за делимично пресуђење имовинско правног захтева оштећеног.

(Пресуда Основног суда у Нишу 13 К.бр.3058/10 од 16.09.2010. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.46/11 од 05.10.2011. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

УТВРЂИВАЊЕ ВРСТЕ И ТЕЖИНЕ ПОВРЕДЕ КОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТА И ТЕЛА

Првостепени суд не може сам, без ангажовања вештака, цени-ти медицинску документацију о повредама оштећеног, јер о томе нема потребна стручна знања.

Из образложења:

Првостепена пресуда је донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. Законика о кривичном поступку, на коју се основано указује изјављеним жалбама, јер у пресуди нису наведени

јасни разлози о свим одлучним чињеницама, те је и сама изрека противречна тако датим разлозима пресуде, а због природе тог недостатка за сада се ни чињенично стање у побијаној пресуди не може прихватити као правилно и потпуно утврђено, ни испитати примена кривичног закона, те се у смислу чл. 389. ЗКП укидање првостепене пресуде показује обавезним.

Конкретно, првостепени суд је врсту и тежину повреде оштећеног и механизам њеног наношења утврдио из извештаја лекара специјалисте од 10.07.2008. године, иако се из извештаја не види какве су повреде по опису констатоване прегледом оштећеног, нити њихова квалификација и механизам настанка. Суд нема потребна стручна знања да на основу оваквог извештаја сам утврди ове одлучне чињенице, које у конкретном случају представљају битан елемент кривичног дела лака телесна повреда из чл. 122. ст. 1. КЗ, већ се у том случају одређује вештачење од стране лица које располаже потребним стручним знањем.

Првостепени суд ће у поновљеном поступку отклонити наведене битне повреде одредаба кривичног поступка тако што ће на поуздан начин утврдити врсту, тежину и механизам наношења повреда оштећеног и то тако што ће одредити вештачење од стране вештака медицинске струке.

(Пресуда Општинског суда у Нишу К.бр.947/09 од 08.12.2009. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж.1.бр.2563/10 од 09.03.2011. године)

Обрадила: судија Снежана Милошевић

ДОКАЗ НА КОМЕ СЕ НЕ МОЖЕ ЗАСНИВАТИ ПРЕСУДА

На информацијама које је Безбедоносно информативна агенција прикупила у обављању своје делатности и по правилима своје службе не може се заснивати пресуда.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд побијаним решењем одлучио да се из списка предмета издвоји информација Безбедоносно информативне агенције у Београду и да се иста не проводи као доказ.

Наиме, одредбама Законика о кривичном поступку прописано је да се одлука суда може заснивати само на доказима изведеним од судије, изузетно и Органа унутрашњих послова уколико поступају на начин прописан овим закоником. Како информација Безбедоносно информативне агенције не испуњава наведене услове, односно иста није прикупљена у складу са Закоником о кривичном поступку, већ у складу са посебним прописима који прописују начин поступања агенције, правилно је првостепени суд побијаним решењем исту издвојио из списка предмета, јер се на оваквој информацији не може заснивати пресуда.

(Решење Вишег суда у Врању К.бр.111/10 од 16.08.2011. године и решење Апелационог суда у Нишу ІКж.2.бр.869/11 од 13.09.2011. године)

Приредила: судија Вера Милошевић

**ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА
РАЗМАТРАЊА**

Слободан Стојилковић,
судија Апелационог суда у Нишу

МЕТОДОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА ИЗРАДЕ ПРВОСТЕПЕНЕ ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

За разлику од неких законодавстава у свету, у нашем кривично-процесном законодавству, писмено израђена пресуда, при чему посебно мислим на њен део који се односи на образложење (чл. 361. ст. 6. до 10. ЗКП), мора да садржи јасне, потпуне и разумљиве појмове и формулације а у образложењу потпуно и детаљно разлоге за све ставове у изреци пресуде уз коришћење термина из закона, избегавајући притом речи и термине који нису уопште усвојене у раду суда.

Овај реферат има за циљ пре свега да се побољша рад првостепених судова, с обзиром да је општи утисак аутора (без неког посебног истраживања и података) да се највећи број пресуда првостепених судова, укида због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП. Могућност да се у поступку по жалби пред другостепеним судом отвори претрес, постојала је у нашем кривичнопроцесном законодавству и пре измена Законика о кривичном поступку (које су ступиле на правну снагу 11.09.2009. године), што је у пракси била реткост. Међутим, одредбом чл. 385. ст. 2. сада важећег Законика о кривичном поступку (чији је циљ скраћивање трајања кривичног поступка), искључена је могућност да другостепени суд ако је првостепена пресуда у истом предмету већ једанпут укинута да побијану пресуду укине и предмет упуту првостепеном суду на поновно суђење, већ мора у седници већа или након одржаног претреса донети одлуку. У вези стим ако је пресуда у истом предмету већ укидана, а недостаци првостепене пресуде се не могу отклонити у седници већа пред другостепеним судом, мора се отворити претрес. Условно речено, не спорећи циљ наведене законске одредбе (убрзање и скраћивање кривичног поступка), може доћи до "претварања" другостепеног суда у првостепени, због чега је ова тема сада и актуелнија.

У досадашњем раду Апелационог суда у Нишу, по општем утиску аутора уочена је код нижестепених судова различита методологија, терминологија и систематика при изради пресуде, што намеће потребу да се укаже на неке од могућих приступа у том правцу без претензије да су најбољи и једино могући, са уверењем да ће бити од користи, посебно младим судијама.

Увод

Иако увод пресуде не би требало да представља већи проблем, али због не тако ретких непрецизности, а и преопширности са уношењем непотребних података, сматрам за потребним да се ваља осврнути укратко на овај део пресуде.

Одредбом чл. 361. ст. 2. ЗКП таксативно је наведено шта увод пресуде треба да садржи и ништа више осим тога.

Погрешно је навођење да се поступак води по оптужби "јавног тужилаштва", јер странка у поступку је тужилац, а не тужилаштво (чл. 221. тач. 7. ЗКП).

Главни претрес је увек усмен и контрадикторан, осим изузетака наведених у одредби чл. 337. ЗКП па је навођење да је главни претрес био усмен је непотребно и сувишно, иако се у пракси често наводи. Када је у питању време објављивања пресуде, оно није без значаја с обзиром на нека процесна права и овлашћења странака, јер се јавни тужилац може одрећи права на жалбу од часа објављивања пресуде у редовном поступку до истека рока за изјаву жалбе, а у скраћеном поступку странке се могу одрећи права на жалбу одмах по објављивања пресуде (чл. 446. ст. 7. ЗКП), због чега је обавезно да се у уводу пресуде назначи време објављивања пресуде, ово тим пре што се пресуда може објавити и у року од 3 дана од завршетка главног претреса.

Изрека

Најважнији део пресуде је свакако изрека која уствари представља заповест суда у погледу онога што је био предмет одлучивања. Она представља изворник и њоме се решавају сва питања која су оптужбом пред суд постављена, како процесна тако и чињенична и правна.

Садржина изреке пресуде у великој мери условљена је односно зависи од врсте донете пресуде, (пресуда којом се оптужени оглашава кривим - чл. 356, ослобађајућа - чл. 355, одбијајућа - чл. 354. ЗКП.). Изрека сваке пресуде мора да садржи податке о оптуженом у обиму који је одређен чл. 89. ст. 1. ЗКП, па је у вези с тим погрешна пракса неких председника већа - судија да у пресуду не уносе све податке из става 1 наведеног члана.

Када изрека пресуде садржи више врста пресуде, редослед одлуке мора бити у складу са одредбама чл. 361. ст. 3. ЗКП јер се најпре уноси одлука којом се оптужени оглашава кривим, одлука којом се окривљени ослобађа од оптужбе, а одлука којом се оптужба одбија уноси се увек последња. Исти редослед изрека пресуде мора имати и онда када се према различитим лицима доносе различите врсте пресуде.

Када је у питању продужено кривично дело у изреку пресуде не уноси се ослобађање за поједине радње које улазе у састав продуженог кривичног дела које су остале недоказане, већ се у образложењу наводи да су оне остале недоказане, а у изреци се оптужени оглашава кривим само за оне радње које су доказане. Најчешћа пресуда у пракси је она којом се оптужени оглашава кривим (чл. 356. ЗКП), због чега ћу се у реферату задржати на овој врсти пресуде. Изрека пресуде којом се оптужени оглашава кривим дефинисана је одредбом чл. 356. ЗКП па поред описа објективних елемената мора да садржи и опис субјективних елемената кривичних дела- да ли је кривично дело извршено са умишљајем (директан или евентуални) или из нехата. Најчешћи недостатак у опису кривичног дела у изреци пресуде чини непотпун опис субјективних елемената кривичних дела, односно чињенице и околности које указују да је оно учињено са умишљајем или из нехата. Констатација да је дело учињено свесно и урачунљиво не представља прихватљив опис дела нити довољно образложење.

Недостаци у опису облика виности у изреци пресуде, најчешће се појављују када су у питању кривична дела квалификована тежом последицом, јер се за њих облик виности мора описати посебно за основно кривично дело и посебно за тежу последицу. Супротно овом, у пракси је примећено и то не у малом броју одлука да се користи формулација, примера ради код кривичних дела из области угрожавања јавног саобраћаја "оптужени је био свестан да таквом возњом може угрозити безбедност јавног саобраћаја и довести у опасност живот људи и имовину већег обима, а околности под којима је дело учињено указују да је пристао на наступање забрањене по-

следице". У наведеном случају забраћену последицу представља како последица основног дела, тако и тежа последица па би се код овакве формулације морало узети да је и у односу на тежу последицу постојао умишљај. Овакве пресуде због нејасноти изреке, морале су бити укинуте.

Осим наведеног, у пракси се релативно често појављују и други недостаци када је у питању изрека пресуде па у вези с тим указујем на следеће:

Код кривичних дела са бланкетном диспозицијом, изостају навођења конкретних повреда норми бланкетне природе, као обележје ових кривичних дела.

- оптуженом се за дело за које је оглашен кривим изриче казна, уместо "осуђује на казну";

- приликом изрицања условне осуде оптужени се понекад прво осуђују за одређено кривично дело и на одређену казну, или се за кривична дела учињена у стицају осуде на одређене казне затвора, а затим се изрекне условна осуда; или утврди казна затвора или јединствена казна и одреди време проверавања или изрекне казна затвора у одређеном трајању и одреди време проверавања, уместо да се применом одредби чл. 64, 65. и 66. КЗ, оптуженом прво изрекне условна осуда, а потом утврди казна за одређено кривично дело или утврде појединачне казне за кривична дела у стицају, односно утврди јединствена казна и одреди време проверавања.

- Уколико је имовинско правни захтев постављен, изрека пресуде мора садржати и одлуку о њему.

Образложење пресуде

Свака пресуда мора имати образложење, а ако се ради о пресуди којом је оптужени оглашен кривим, онда за сваку тачку из чл. 356. ЗКП. Суд често образложење замењује навођењем односно препричавањем исказа странака, сведока и вештака (са сасвим погрешном оценом када је у питању налаз вештака, најчешће уз констатацију да "налаз прихвата јер је дат од стручног и компететног вештака", за одређену област), што је неприхватљиво, јер је потребно оценити валидност односно квалитет налаза вештака са одговарајућим разлозима зашто се он прихвата или не прихвата, јер је вештак одговарајуће струке коме је вештачење поверено, формално стручан за давање налаза и мишљења из одговарајуће области. Оваквом

површном оценом или без икакве оцене доказа пресуда практично остаје стварно без образложења.

Из образложења пресуде странке сазнају разлоге за донету пресуду, а Виши суд цени законитост и правилност донете одлуке, због чега изради образложења треба посветити пуну пажњу. У том смислу, указује се на одредбе чл. 361. ст. 6. до 10. ЗКП којима су решена основна питања систематике образложења и његов садржај, а методологију треба прилагодити конкретном случају, коју пре свих, изграђује судска пракса утврђујући нека правила која се свode на:

- Означавање тужиоца (не тужилаштва), врсту и ознаку оптужног акта.
- Означавање оптуженог, а ако има више оптужених утврђивање редоследа оптуженох пре свега према тежини кривичних дела итд.
- Предмет оптужбе, да ли је она мењана или евентуално вршено њено проширење и у ком правцу, ово због могућности оцене везано евентуално за прекорачење оптужбе и да ли је пресудом решен потпуно предмет оптужбе.
- Одбрану оптуженог, која треба да буде тако конципирана и то само у погледу одлучних чињеница, само у њеној коначној верзији, а не како се то релативно често чини изношењем садржине одбране у свим фазама поступка, односно њено готово доследно преписивање, што је непотребно, а и нецелисходно.
- Који су докази изведени морају бити јасно назначени, односно конкретизовани.
- Оцену доказа - фиксирање чињеница које из њих произилазе и утврђивање чињеничног стања, а не његово свођење на изреку пресуде, што се запажа у не тако малом броју одлука првострепених судова,
- Оцену одбране оптуженог и разлоге због чега нису уважени поједини предлози странака.
- Правне разлоге пресуде.

Образложење казне, условне осуде, мере безбедности и других одлука (о имовинскоправном захтеву, о урачунавању притвора или већ издржане казне, трошковима кривичног поступка, паушалу и др.).

Код сваке пресуде утврђује се чињенично стање, онолико колико је потребно за односну врсту пресуде, уз навођење разлога за такво утврђење.

Образложење чињеничног стања састоји се у излагању резултата доказног поступка, увек везано за одлучне чињенице које треба доказати и навођења због чега суд одређене чињенице узима као недоказана или доказане. Није довољно навести да су искази појединих сведока нејасни или непоуздани, већ се на одговарајући начин мора образложити зашто их суд тако оцењује. У супротном, ради се о битној повреди одредаба кривичног поступка из чл. 368. ст. 1. тач. 11. ЗКП, која води обавезно укидању пресуде.

Не тако мали број пресуда, своди се на препричавање тока доказног поступка и доказног материјала, у ком случају практично образложења нема. Разлози се морају свести на репродуковање у нај битнијем оних доказних резултата који се односе само на одлучне чињенице а не на репродуковање целокупног (и небитног) садржаја проведених доказа. Пресуда која се своди на изреку је пресуда без образложења, јер је изрека само супстрат утврђеног чињеничног стања, а чињенично стање ширира целина која се мора у сваком конкретном случају утврдити. Из образложења пресуде мора јасно да се види које су чињенице и на основу којих доказа и из којих разлога утврђене или неутврђене, што је последица обавезе суда да савесно оцени сваки доказ појединачно и у вези са осталим доказима и на основу такве оцено, изведе закључак да ли је нека чињеница доказана или не (чл. 352. ст. 2. ЗКП), а у вези с тим нужно је дати и оцену одбране оптуженог.

Образложење пресуде мора бити тако састављено да објасни не само чињеничну, логичну и садржајну већ и правну целину од значаја за постојање предметног кривичног дела, како у његовом основном тако и у квалификованом облику и за кривицу оптуженог (урачунљивост и виност). У разлозима пресуде укратко се морају навести и то сасвим јасно разлози којима се руководио суд при решавању правних питања, а нарочито при утврђивању да ли постоји кривично дело и кривица оптуженог, примени одређених одредаба кривичног закона на оптуженог и његово дело (у смислу чл. 361. ст. 7. ЗКП). За случај да је кривично дело кажњиво као умишљајно, мора се образложити постојање умишљаја, па је недопустива констатација да је кривично дело учињено свесно и урачунљиво, јер свест и урачунљивост постоје не само код умишљаја већ и код нехата.

Разлози који се у образложењу наводе у односу на изречену кривичну санкцију најчешће су штури и стереотипни иако су то одлучне чињенице, због чега се и оне морају утврдити са истим степеном извесности као и чињенично стање од кога зависи одлука о кривици и правној оцени дела.

Из одредбе чл. 361. ст. 8. ЗКП, произилази обавеза суда да наведе околности које је узео у обзир приликом одмеравања казне. У разлозима пресуде мора се одређено навести којим су доказима утврђене чињенице од којих зависи одлука о казни као и разлози на основу којих суд узима да оне постоје. Посебно код ублажавања казне, суд је обавезан да у смислу чл. 56. и 57. КЗ, посебно наведе разлоге на основу којих је нашао да су утврђене олакшавајуће околности и "нарочито олакшавајуће околности", због којих казну треба ублажити.

У смислу наведеног, указује се да се признање оптуженог не може узети као олакшавајућа околност ако је до њега дошло тек након утврђеног чињеничног стања, кривичног дела и учиниоца. Такође се не може као олакшавајућа, посебно не као нарочито олакшавајућа околност узети релативна "младост" или "старост" оптуженог нити "коректно држање" или "добро држање" оптуженог на главном претресу, које се састоји у његовом пристojном понашању с обзиром да је то нормална ситуација јер за случај да се оптужени не покова наредбама председника већа, има уследити одговарајућа санкција.

Чињенице и околности, које чине битна обележја кривичног дела и дају квалификовани вид кривичном делу, не могу се узети као отежавајуће околности али код неких кривичних дела једна иста околност може имати карактер квалификаторне околности и истовремено бити узета као отежавајућа околност приликом одмеравања казне, примера ради код кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 2. и 4. КЗ, где је квалификаторна последица "смрт једног или више лица", за постојање овог кривичног дела довољно је да је само једно лице у саобраћајној незгоди изгубило живот. Уколико се последица састоји у смрти више лица, ова околност се може узети као отежавајућа при одмеравању казне, али код оцене тежине извршеног кривичног дела.

На крају треба навести да пресуду потписују председник већа-судија и записничар, што чини обавезан саставни део пресуде. Но у пракси се појављују и случајеви мада не тако често да ови потписи недостају, због чега се списи предмета морају вратити првостепеном суду, да отклони тај недостатак.

И сасвим на крају, мишљења сам да израђену пресуду треба пажљиво прочитати, јер се тада евентуални недостаци могу најбоље уочити и отклонити, чиме ће се избећи укидање пресуде.

Слађана Стојановић,
судија Апелационог суда у Нишу

ПРАВИЧНА НАКНАДА ЗА РАД И ЗАШТИТА ТОГ ПРАВА У СУДСКОМ ПОСТУПКУ

A iustitia (quasi a quodam fonte) omnia iura emanent.
(Ulpianus – D. 1, 1, 1, 1).

Из правичности (као неког извора) проистичу сва права.

In omnibus quidem, maxime tamen in iure aequitas spectanda est.
(Ulpianus – D. 50. 17. 90)

У свему, а највише у праву, мора се водити рачуна о правичности.

Iustitia regnorum fundamentum.

Правичност је основ владавине.

Prima pars aequitatis – aequalitas.

Једнакост је најважнији део правичности.¹

Устав РС у чл. 60. ст. 4. прописује између осталог да свако има право на правичну накнаду за рад као и да се нико тог права не може одрећи. Чланом 36. Устава јемчи се једнака заштита права пред судовима, а чланом 32. право на правично суђење.

Међутим, свако прокламовање одређеног права, па и права на правичну накнаду за рад и немогућност одрицања од тог права, као и права на правично суђење и једнаку заштиту пред судовима истог, само по себи, не значи аутоматски остваривање тог права, на исти начин у судском поступку.

"Да би одлуке које судови доносе биле законите, правилне и правно предвидиве, нужно је и потребно да сви судови на територији РС доприно-

¹ Ризница правних изрека, Интермекс, Београд 2007., треће издање, страна 117. и 118.

се усвајању и поступају у складу са усвојеним правним схватањима, утврђеним ставовима, закључцима и сентенцама Врховног касационог суда² а судије у циљу афирмације владавина права и враћање поверења у правосудје, су "дужне да свим странкама обезбеде једнаку правичну и закониту заштиту. То се једино може остварити на тај начин што ће судови међусобно сарађивати и доприносити да се поштује изграђена судска пракса, усвојена правна схватања, утврђени правни ставови, закључци и сентенце Врховног Касационог суда, као највишег суда у Републици Србији".³

Недоследна и неуједначена судска пракса и доношење различитих одлука у идентичним чињеничним и правним ситуацијама представља повреду права на правично суђење које је зајемчено чланом 32. Устава РС и представља основни разлог због кога Уставни суд Србије усваја уставне жале и поништава судске одлуке. Осим тога, поступање на овакав начин доводи и до повреде права на правично суђење које је прокламовано и чланом 6. ст. 1. Европске конвенције о људским правима. Европски суд за људска права тако понашање санкционише обавезивањем државе на исплату штете на име правичног задовољења (Ракић против Србије, Винчић против Србије).

Када је у питању правична накнада за рад, за сада у појединим споровима не постоји идентично поступање судова и ставови, па и на нивоу самих Апелационих судова, на шта се жели указати у овом реферату у циљу проналажења пута и начина за што већом сарадњом између Апелационих судова, и заузимања ставова од стране Врховног Касационог суда о појединим питањима, а све ради уједначавања судске праксе у обезбеђивању једнаке, правичне и законите заштите овог права грађанима у судским поступцима, јер се ради о споровима који се у највећем броју случајева завршавају одлукама Апелационих судова. Осим тога, законом није прописан поступак усаглашавања мишљења и поступања Апелационих судова у идентичним споровима који се правноснажно окончавају на нивоу ових судова, у којима, по правилу није предвиђена могућност изјављивања ревизије. Стога, врло често, и саме судије које поступају у овим споровима немају сазнања да се у идентичним ситуацијама, на подручју

² Допис Врховног Касационог суда од 11. 11. 2010. године I су 589/10 упућен Апелационом суду у Нишу

³ Допис Врховног Касационог суда од 11. 11. 2010. године I су 589/10 упућен Апелационом суду у Нишу

других Апелационих судова другачије поступа и одлучује, те да се доношењем поједних одлука из ове области крши чл. 6. ст. 1. Европске конвенције за људска права као и чл. 32. Устава РС, на шта је већ указано.

Од каквог је значаја остваривање овог права говори сама чињеница да је основни мотив због кога људи раде остваривање новчане накнаде за рад, јер на тај начин обезбеђују материјалну и социјалну сигурност за себе и за своју породицу. И то је сасвим у реду, јер се новац узима као мера свих ствари.

Шта се подразумева под појмом правична накнада за рад?

Зарада представља правичну накнаду за рад.⁴ Да ли се може ставити знак једнакости између ова два појма?

Постоји уже и шире тумачење овог појма.

Уже тумачење, под појмом правичне накнаде за рад подразумева зараду која представља правичну накнаду за рад, било да се ради о минималној заради, која је прописана чл. 111. Закона о раду, или одговарајућој заради из чл. 104. и 105. Закона о раду.

Шире тумачење, под појмом правична накнада за рад, осим зараде подразумева и сва друга примања и накнаде по основу рада.

Предмет овог реферата јесте зарада, минимална зарада, увећана зарада и друга примања из радног односа која у смислу правила Закона о раду представљају саставни део зараде. Заштита повређеног права на правичну накнаду за рад - зараду запосленима се пружа у радном спору пред првостепеним судом - Основни суд. На те спорове примењују се правила Закона о парничном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004 и 111 од 29.12.2009. године), а права, обавезе и одговорности на основу рада утврђена су правилима Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05 и 61 од 18.07.2005. године), који је матични закон у области рада јер садржи опште норме. Посебна правила садржана су у другим законима, као што је Закон о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91 до 31/2002), односно Закон о државним службеницима ("Сл. гл. РС", бр. 79/2005-67/2007), који се примењује од 01.07.2006. године. Када се ради о зарадама односно платама државних службеника и намештени-

⁴ Одлука Уставног суда РС бр. Уж. 697/2009 од 17.02.2011. године

ка, односно у државним органима примењује се Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/01-61/05). Почев од 01.01.2007. године примењује се Закон о платама државних службеника и намештеника ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006-101/2007). На зараде, накнаде зараде и друга примања из радног односа запослених у јавним службама примењују се правила поменутог Закона о платама у државним органима и јавним службама, уредбе Владе донете на основу тог закона, Општи колективни уговор, те посебни колективни уговори за поједине јавне службе, уредбе и посебни колективни уговори који су донети нако ступања на снагу Закона о платама државних службеника и намештеника, када су у питању плате, накнаде и друга примања наведене категорије запослених. Према чл. 189. Закона о државним службеницима, одредбе Закона о радним односима у државним органима настављају да се сходно примењују на радне односе у органима аутономне покрајине и локалне самоуправе, до доношења посебног закона, почев од 01.07.2006. године. Дакле, одредбе Закона о раду примењују се супсидијарно од 01.07.2006. године на радне односе у државним органима као и у органима аутономне покрајине и локалне самоуправе. Ступањем на снагу Закона о државним службеницима и у јавним службама и установама важи општи режим матичног Закона о раду.

Право на зараду утврђено је у члану 104. Закона о раду који прописује, у ставу првом, да запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Ставом другим, истог члана, прописано је да се запосленима гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности које остварује код послодавца. Члан 105. истог Закона прописано је да се зарада састоји од зараде за обављени рад и време проведено на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и сл) и других примања по основу радног односа у складу са општим и уговором о раду. Ставом другим наведене одредбе прописано је да се по зарадом сматра зарада која садржи порезе и доприносе који се плаћају из зараде, а у ставу трећем је прописано да се под зарадом подразумевају сва примања из радног односа, осим накнаде трошкова запосленог у вези са радом из чл. 118. ст. 1. тач. 1. - 4. и других примања из чл. 119. и чл. 120. тач. 1. Закона, што подразумева да се под зарадом сматрају сва примања из радног односа, и то: накнада за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмо-

ра, теренски додатак, додатак за одвојен живот и давања запосленима у новцу или у роби поводом празника. Одредбе из тачке 5. и 6. наведеног члана 118, наведеног закона, примењују се почев од 01.01.2006. године (накнада за трошкове исхране у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора). Правилима из чл. 106. прописано је да се зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји од основне зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде, а да се уговором о раду може утврдити основна зарада у већем износу од основне зараде утврђене на основу елемената из општег акта. У смислу чл. 108. истог закона увећана зарада на коју запослени има право, а чија се висина утврђује општим актом и уговором о раду, представља зараду за рад на дан празника који је нерадан дан-110% од основице, за рад ноћу и рад у сменама, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде-најмање 26% од основице, за прековремени рад -најмање 26% од основице и део зараде по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу-0, 4% процената од основице. Истом одредбом прописано је да ако су се истовремено стекли услови по више наведених основа, проценат увећане зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања. Општим актом и уговором о раду могу да се утврде и други случајеви у којима запослени има право на увећану зараду. Основицу за обрачун увећане зараде чини основна зарада утврђена у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Право на минималну зараду утврђена је у чл. 111. Закона о раду, којим је прописано да запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и пуно радно време, односно радно време које се изједначава са пуним радним временом. Ако послодавац и запослени уговоре минималну зараду, послодавац је дужан да ту зараду исплати запосленом у висини која се утврђује на начин прописан чл. 112. Закона.

Имајући у виду наведене одредбе Закона о раду произилази да се зарада остварује радом и да без рада нема зараде, што подразумева да се накнаде зараде остварују без рада у случајевима одређеним законом, подзаконским актима, општим актима о раду и колективним уговором, као што су годишњи одмор, плаћено одсуство, привремена спреченост за рад, војна вежба, одазивање на позив државних органа, стручно усавршавање, привремено удаљење запосленог са рада. Друга примања такође не пред-

стављају зараду, осим примања у смислу чл. 118. Закона о раду, о којима је напред било речи.

Као предмет спора пред судовима, најчешће се појављују потраживања по основу неисплаћене зараде, неисплаћене минималне зараде, разлике између исплаћене и припадајуће минималне зараде, захтеви за исплату разлике између исплаћене и одговарајуће зараде, као и захтеви за исплату увећане зараде, захтеви за исплату накнаде по основу исхране у току рада, на име регреса за коришћење годишњег одмора или разлике између исплаћених износа и износа за које запослени сматрају да им припадају, те за уплату доприноса за обавезно социјално осигурање надлежним фондовима.

Велики број спорова се односи на **исплату пуне зараде или минималне зараде у условима када запослени нису радили без своје кривице због тога што послодавац није могао обезбедити предмет рада или накнаде зарада, а радни однос им није престао**. Међутим, за остваривање накнаде зараде у наведеним случајевима мора постојати основ. Чини се да о правном основу за признавање права на накнаду зараде када радници нису радили без своје кривице не постоји јасна судска пракса, односно уједначена судска пракса. Према пракси Апелационог суда у Нишу и Основних судова на подручју тога суда, може се формирати закључак да се у наведеној врсти спорова усвајају тужбени захтеви како су постављени, без обзира да ли се тражи накнада или зарада, будући да суд није везан за правни основ приликом одлучивања, при чему се судови не упуштају у основ одговорности послодавца. Најчешће се одлуке образлажу разлозима да запослени није могао остварити зараду без своје кривице, због тога што послодавац није обезбедио предмет рада, а њему није престао радни однос. При томе, судови се не упуштају у разлоге због којих није могао да се одвија процес рада код послодавца, објективне или субјективне. За судове је довољна околност о томе да послодавац није предузео све мере које прописује Закон о раду и овлашћења која су прописана другим законским прописима-прописи који се односе на стечај и ликвидацију, те који се односе на приватизацију привредних субјеката, у смислу смањења броја запослених-технолошки вишак, упућивања на плаћено одсуство уз исплату умањене зараде, упућивања на неплаћено одсуство, предузимања мера ради отварања стечајног поступка, односно поступка

реструктурирања или приватизације, односно у смислу исплате минималне зараде.

Да ли може бити без значаја правни основ за исплату накнаде зараде у наведеном случају, и то у случајевима када не постоји кривица послодавца за прекид процеса рада? Има ли места у тим случајевима умањењу накнаде зараде запосленима за време за које нису радили, за износ средстава остварених док су били ван процеса рада ако су остваривали приход за то време?

Код решавања спора за исплату минималне зараде и разлике између исплаћене и припадајуће минималне зараде, судови се придржавају постојећег става Врховног касационог суда, односно ранијег Врховног суда да се минимална зарада може исплаћивати само ако је уговорена између послодавца и запосленог, односно под условима који су прописани чланом 111. Закона о раду, односно општим актом о радним односима. Када се захтева исплата минималне зараде у случајевима прекида процеса рада који је наступио без кривице запосленог, односно накнада зараде до висине минималне зараде, чему се послодавци противе јер, минимална зарада није уговорена, судови су досуђивали запосленима накнаду до висине минималне зараде, иако иста није уговарана за период на који се односи тужбени захтев, из чега произилази да су и сами запослени имали у виду околност о томе да је послодавац доспео у стање платежне неспособности, због поремећаја у пословању, исказујући на тај начин разумевање и тежњу да се у извесној мери сачува предузеће, до отклањања поремећаја у пословању, обзиром да нису тражили исплату уговорене зараде која је била већа од минималне. Постоје и спорови у којима код претежног броја послодаваца и запослених није могао да се успостави прави економско-социјални дијалог и представници синдиката радника, као и радници, нису прихватили исплату минималних зарада, без обзира на стање пословања послодавца, због чега су запослени одбијали закључење уговора о раду под измењеним условима у смислу уговарања исплате минималне зараде, тужбама су тражили исплату уговорене зараде која је била већа од минималне зараде, тако да су послодавци, у тим случајевима, обавезивани на исплату пуне зараде.

Бројни су и спорови који се односе на исплату увећане зараде у смислу чл. 108. Закона о раду, јер се не врши исплата увећане зараде у обиму који је прописан наведеном одредбом, а предвиђена је исплата колектив-

ним уговорима или уговорима о раду, а ако је рад ноћу и у сменама вреднован при утврђивању основне зараде општим актом послодавца или уговором о раду, тада се не исказује јасно који проценат од основне зараде или део коефицијента су уговарачи (репрезентативни синдикати, представници организације послодаваца послодаваца и Владе) имали у виду приликом закључења колективних уговора. У тим споровима послодавци се позивају да је рад ноћу или у сменама вреднован при утврђивању основне зараде, али из наведеног разлога то не могу доказати. Велики број спорова се појављује и због одсуства разумног економско-социјалног дијалога између организације послодаваца, односно њихових представника и запослених, односно њихових синдикалних представника, због чега не долази до закључења колективних уговора, а послодавци не доносе или доносе одлуке о том виду зараде, као и дела зараде који представља регрес за коришћење годишњег одмора, односно накнаду у вези са исхраном у току рада (топли оброк) или преко својих пословодних органа, без претходно спроведеног поступка који је прописан правилима Закона о раду. У том случају судови примењују раније закључене колективне уговоре, појединачне или посебне, у складу са правилима Закона о раду, који је примењиван до ступања на снагу сада важећег Закона о раду, а у њиховом одсуству упуштају се и у утврђивању обима новчаних потраживања по наведеним основима. Примењиване су и одредбе Општег колективног уговора из 1997. године у делу који се односи на зараде, накнаде зарада и других примања из радних односа, ако одредбе тог акта нису у супротности са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 70/2001 са изменама и допунама).

У правном закључку Грађанског одељења Врховног суда Србије⁵ у погледу права државних службеника и намештеника на накнаду за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора наводи се "да закон о раду предвиђа право запосленог на накнаду трошкова за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора, али утврђивање услова, висине и начина исплате препушта аутономном регулисању путем закључења колективног уговора као општег акта и уговора о раду". У образложењу овог става се наводи да је услов за остварење права државних службеника и намештеника за накнаду трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора постојање

⁵ Билтен судске праксе број 1/08

колективног уговора којим се утврђује право, висина и начин исплате ових накнада. На тај начин очигледно је решена дилема у погледу права на исплату топлог obroка и регреса државних службеника и намештеника. Стога изненађује, када се и поред наведеног закључка Врховног суда, који је објављен 2008. године, појаве одлуке којима се усваја тужбени захтев када се ради о накнадама по наведеним основима.⁶

Међутим, у погледу права осталих запослених где се примењује **Закон о раду, у погледу права на исплату топлог obroка и регреса**, који су саставни део зараде према наведеном члану 105. Закона о раду, не постоји објављен и заузет став од стране Врховног Касационог суда, али постоји различита судска пракса. Наиме, према једном ставу, запосленима припада право на исплату топлог obroка и регреса, као дела зараде, само у случају ако је ово право предвиђено Општим актом или Уговором о раду. У тим случајевима судови се позивају на чл. 118. ст. 1. Закона о раду који говори да запослени има право на накнаду између осталог и за накнаду са исхрану у току рада и регреса али у складу са општим актом и уговором о раду. Уколико то право није предвиђено општим актом или уговором о раду, у том случају ради се о tzv. "голом праву", обзиром да закон није предвидео критеријуме за утврђивање износа регреса и топлог obroка, па се у тим случајевима овакви тужбени захтеви одбијају, уз образложење да није уговорена исплата топлог obroка и регреса како Општим актом тако и Уговором о раду. На подручјима судова где је и раније била оваква судска пракса врло ретко се појављују данас спорови у којима се тражи исплата регреса и топлог obroка уколико њихова исплата није предвиђена општим актом или уговором о раду. Према другом ставу, од 01.01.2006. године накнада на име регреса за коришћење годишњег одмора и на исплату топлог obroка представља законску обавезу послодавца и ови судови усвајају постављене захтеве и запосленима досуђују топли оброк и регрес, без обзира што исплата није предвиђена општим актом послодавца или уговором о раду. У тим случајевима судови полазе од правне природе и сврхе накнаде трошкова за коришћење годишњег одмора, уз образложење да ово право мора имати минималну економску вредност која би била довољна за покривање дела трошкова у вези коришћења годишњег одмора и запосленима се досуђује накнада за коришћење годишњег одмора у

⁶ Пресуда Основног суда у Нишу 1 П1. 4898/10 од 02.08.2010. године, која је преиначена пресудом Апелационог суда у Нишу Гж1. бр. 2744/10 од 26.11.2010. године

износима просечне зараде у привреди РС по званичним подацима објављеним од стране надлежног органа за статистику. Досуђује се и накнада на име топлог obroка, па и у случајевима када је послодавац организовао исхрану за запослене, и када је запослени користио ову услугу, ако не постоји његова изричита писмена сагласност за овакав вид топлог obroка. Износ топлог obroка утврђује се на месечном нивоу и укључује у зараду, с тим што уколико код послодавца постоји организована исхрана, коју је запослени користио али не постоји његова писмена сагласност за овакав вид исхране, запосленом се умањује ова накнада за вредност топлог obroка који конзумира у ресторану друштвене исхране.⁷

Исплата минималне зараде најчешће је присутна и уговара се у ситуацијама када због лоших пословних резултата послодавац није у могућности да обезбеди довољно финансијских средстава да исплати одговарајуће зараде запосленима. Дакле, исплата минималне зараде се уговора, а чл. 112. Закона о раду регулише начин утврђивања минималне зараде. Минимална зарада се утврђује по радном часу, за период од најмање шест месеци и утврђује се одлуком социјално – економског савета основаног за територију РС, а у случају да исти не донесе одлуку у року од 10 дана од почетка преговора, тада одлуку о висини минималне зараде доноси Влада Републике Србије. Минимална зарада не може бити нижа од минималне зараде која је на напред наведени начин утврђена за период који претходи периоду за који се утврђује минимална зарада.

Шта се дешава са правом на исплату топлог obroка и регреса уколико је уговорена исплата минималне зараде и уколико су наступили услови за исплату исте.

И овде постоје различита тумачења и поступања судова, што доводи до различитог одлучивања у истој правној ситуацији.

По једнима, минимална зарада је дефинисана у чл. 112. Закона о раду. Обзиром да се исплата исте уговора у тзв. ванредним ситуацијама, у којима се нашао послодавац, са циљем да се таква ситуација преброди на најбезболнији начин за послодавца и да би запослени задржали своја радна места, уговарање исплате минималне зараде аутоматски, само по себи,

⁷ Пресуда Основног суда у Нишу П. 1. бр. 199/10 од 25.06.2010. године која је потврђена одлуком Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 2717/10 од 19.11.2010. године.

значи губитак права на исплату топлог obroка и регреса, јер ова примања не чине саставни део минималне зараде. По другом становишту, уговарањем исплате минималне зараде не могу се уговорити мања права од оних која су предвиђена колективним уговором или другим појединачним актом код послодавца, па уколико је овим актима предвиђено право на исплату топлог obroка и регреса, то право запосленима припада и у случају када је уговорена исплата минималне зараде. Постоји и треће становиште по коме је право на исплату топлог obroка и регреса је од 01.01.2006. године законско право запослених, предвиђено и гарантовано законом, па самим тим представља законску обавезу послодавца, и запосленима стога припада право на исплату ових потраживања, без обзира да ли је исплата топлог obroка и регреса предвиђена појединачним колективним уговором или другим актом код послодавца, и у случају када је уговорена исплата минималне зараде судови усвајају захтев за исплату и топлог obroка и регреса и исте досуђују.

Према чл. 105. ст. 2. Закона о раду, под зарадом подразумева се **зарада која у себи садржи порезе и доприносе** који се исплаћују из зараде. И у том делу постоји различито поступање судова на нивоу појединих Апелационих судова.

Према правном схватању Грађанског одељења Врховног суда Србије, које је утврђено на седници 05.11.2001. године "суд у парничном поступку одлучује о захтевима запосленог да послодавац уплати доприносе за обавезно социјално осигурање одговарајућем фонду и да упише стаж осигурања у радну књижицу". Ово правно схватање измењено је Закључком Врховног Касационог суда који је донет на седници од 23. 03. 2010. године. Према том Закључку одлучивање о самосталном тужбеном захтеву који се односи на обавезивање послодавца на уплату доприноса из обавезно социјалног осигурања не спада у надлежност суда опште надлежности, јер се не ради о спору из чл. 1. Закона о парничном поступку.⁸

Након тога, Апелациони суд у Београду усвојио је на седници Грађанског одељења за радне спорове 23.12.2010. године и 26.01.2011. године правни став по коме у предметима у којима је тужба поднета пре 01.01.2010. године (а то важи и за пресуде донете пре овог датума), за одлучивање по захтеву за уплату доприноса (независно да ли се ради о до-

⁸ билтен Врховног Касационог суда бр. 1/2010

приносима или додатним доприносима), одлучује се у меритуму, а Закључак усвојен на седници грађанског одељења Врховног касационог суда од 23. 03. 2010. године примењује се на све случајеве где је тужба поднета после 01. 01. 2010. године. Супротно од овог става, Апелациони суд у Нишу по овом питању, кроз своје одлуке, не прави овакав пресек са 01.01.2010. године и према судској пракси овог суда, без обзира на то када је тужба поднета – пре 01.01.2010. године или након тога, судови нису надлежни да одлучују о оваквим захтевима.⁹

Судови различито поступају и у ситуацијама када су запослени потписали изјаву о одрицању од права на исплату неисплаћене зараде до дана престанка радног односа, као и код исплате зараде под условима када постоји споразуми између послодавца и запослених о времену и начину исплате, односно условима под којима ће се извршити исплата, протокола.

По једном ставу, поједини судови, сматрају да само потписивање изјаве од стране запосленог, којом се одриче од права на исплату неисплаћене зараде аутоматски значи немогућност примене чл. 186. Закона о раду. Наведено одрицање производи правно дејство и запослени, у тим ситуацијама, нема право на исплату потраживања којих се одрекао уколико оваква његова изјава, због мана воље није поништена у судском поступку.

Поједини судови су заузели становиште да уколико радник поднесе тужбу којом тражи исплату потраживања којих се одрекао у законском року у коме може да тражи поништај изјаве о одрицању, о захтеву за поништај изјаве о одрицању одлучивали су као о претходном питању. По другом становишту, запослени се не може одрећи самог права, али уколико су у оваквим изјавама наведени новчани износи, такво одрицање производи правно дејство и у тим случајевима се ради о тзв. опросту дуга, у смислу чл. 344 ЗОО. Постоји и треће становиште које полази од чл. 60. ст. 4. Устава Србије којим је предвиђено, између осталог, да свако има право на правичну накнаду за рад и да се нико тих права не може одрећи. Стога само одрицање од наведених потраживања, било да су наведени новчани износи или не, је апсолутно ништаво и не производи правно дејство, а запослени има право на исплату ових потраживања и иста му треба досудити¹⁰, без обзира да ли је вођен спор за пони-

⁹ Решење Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 553/10 од 07.05.2010. године

¹⁰ Решење Апелационог суда у Нишу Гж. 1. бр. 553/10 од 07.05.2010. године

штај одлуке којим се запослени одрекао овог потраживања или је утврђен мањи новчани износ одлуком послодавца по овом основу од износа који би запосленом припао, јер се ради о апсолутно ништавим актима која не могу производити правно дејство и нема потребе да се води поступак пред судом ради поништаја таквих аката.

У погледу начина обрачуна и досуђивања затезне камате на новчана потраживања из радног односа постоје такође различита поступања.

Наиме, према правном схватању Апелационог суда у Новом Саду, које је усвојено на заједничкој седници Грађанског одељења и Одељења за радне спорове од 12.04.2010. године, "усвајање захтева постављених тако да се потражује накнада материјалне штете у збирном износу, са обрачунатом и номиналном исказаном каматом, од доспелости до дана вештачења, па се сабирају износ главнице и износ обрачунате и номинално исказане камате и на овако добијени збир досуђује камата од дана вештачења до исплате, није противно забрани анатоцизма".

Међутим, постоји и другачије схватање и поступање судова по коме је законска затезна камата споредно потраживање према чл. 277. ЗОО, иста се не може приписивати главном дугу и на тако добијени износ потом досуђивати законска затезна камата, те да се у том случају ради и каматном анатоцизму који је забрањен по закону. Овакво становиште изражено је кроз одлуке Апелационог суда у Нишу, и у оваквим ситуацијама одлуке нижестепених судова се укидају и враћају на поновно одлучивање или преиначавају, поступак у овом случају пред судом дуже траје а повећавају се и трошкови самог поступка.

Постоји и дилема како да судови поступају и одлучују у случајевима када су запослени закључивали уговоре или споразуме о одлагању исплате зараде и др., потраживања из радног односа и од када треба досуђивати камату на ове износе. Наиме, у пракси врло често у овим уговорима тј. споразумима није јасно одређен рок када ће послодавац извршити исплату, нити је одредив. Обично се утврђује "исплата ће се извршити кад и другим или осталим радницима", или "када се стекну услови за исплату", а у пракси се обично деси да се уопште не може исплатити зарада, тако да остаје могућност да се та потраживања евентуално намирe у стечајном поступку.

По једном схватању, рок који је предвиђен чл. 110. Закона о раду не може се померати на штету радника, јер неповољнији рок не може бити предмет уговора и споразума, што само по себи произилази из наведене законске одредбе која каже: "зарада се исплаћује у роковима утврђеним општим актом и уговором о раду, најмање једанпут месечно, а најкасније до краја текућег месеца за претходни месец. " Уколико постоје такви уговори и споразуми исти су апсолутно ништави у том делу, тужбе којима се тражи исплата ових потраживања нису преурањене, захтеве треба усвајати, а камату досуђивати на сваки месечни износ неисплаћене зараде од првог у месецу за претходни месец у случају да општим актом или уговором о раду није предвиђен повољнији рок, који у том случају треба применити. Постојање наведених споразума и уговора треба третирати као признање дуга, које постоји и траје, што је од утицаја код оцене застарелости ових потраживања. Осим тога, камата је споредно потраживање и дели судбину главног потраживања, па како се применом чл. 60. Устава запослени не може одрећи овог потраживања, то се аутоматски не може одрећи ни камате на ова потраживања. По овом схватању код оваквих спорова без утицаја је да ли је запосленом престао радни однос након закључивања наведених споразума и уговора којима се одлаже исплата. По другом схватању уколико постоје наведени споразуми и договори исти се морају поштовати ако није затражен поништај истих због мане воље. Међутим, ако раднику престане радни однос након тога, ова потраживања доспевају аутоматски на тај дан применом чл. 186. Закона о раду, а камата на ова потраживања по једнима тече од дана престанка радног односа, по другима по протеклу 30 дана од дана престанка радног односа, а постоји и мишљење да камата на неисплаћене зараде запосленог почиње да тече од момента подношења тужбе.¹¹

Ради правилног расправљања и одлучивања о захтеву за исплату накнаде за исхрану у току рада и регреса за искоришћени годишњи одмор, није сувишно изнети **запажање о постојању различитих ставова и схватања и поступања од стране судова када је у питању накнада штете по основу изгубљене зараде због незаконитог престанка радног односа.**

¹¹ Одговор утврђен на седници Одељења за привредне спорове Вишег трговинског суда од 10.10.2003. године. судова.

Према једном схватању, запосленом припада право на исплату изгубљене зараде коју би остварио да је радио и ова накнада не обухвата исплату по основу регреса, топлог оброка и стимулације, јер право на њихову исплату и накнаду се везује искључиво за фактички рад. Истоветно се поступа и када су у питању накнаде по основу неисплаћеног регреса као и по питању накнаде која се исплаћује у случају постојања посебних, специјалних услова. Приликом одлучивања о захтевима за накнаду штете у виду изгубљене зараде због незаконите одлуке суда, ови судови цене и узимају у обзир околност да ли је тужилац тражио запослење и шта је предузео да штете не буде већа него што би иначе била. У тим случајевима, на предлог супротне стране, између осталог прибавља се извештај од Националне службе за запошљавање, па уколико се незапослено лице од дана престанка радног односа па надаље није пријавило код ове службе, ови судови закључују да у тим случајевима наведено лице није тражило запослење, те да стога постоји његов допринос у смислу чл. 192. ст. 1. ЗОО да штета буде већа него што би иначе била. Уколико постоји податак од Националне службе за запошљавање да је у периоду у коме то лице није радило исказана потреба за запошљавањем тог профила радника, а наведено лице се није пријавило код ове службе, захтев за накнаду штете ови судови одбијају. Према другом становишту, и у тим ситуацијама раднику припада право на накнаду штете у виду изгубљене зараде у чији састав улази и топли оброк, регрес, стимулација, изгубљена зарада по основу тзв. специјалних услова рада...¹² и по израженом схватању ових судова, сама чињеница да ли се запослени пријавио код Националне службе за запошљавање или не, од дана престанка радног односа до дана враћања на рад, без утицаја је не одлучивање у овој правној ствари. Ови судови приликом досуђивања накнаде штете због изгубљене зараде досуђују и накнаду по основу изгубљеног топлог оброка и регреса, уз образложење да би радник остварио ово право да је радио.¹³

У вези са заштитом права запослених на зараду у судским поступцима, потребно је осврнути се и на **трошкове поступка** јер се ради о споровима у којима се врло често на једној страни појављује већи број тужилаца или се у самој тужби постави прво један захтев, који се касније, то-

¹² Пресуда Окружног суда у Нишу, Гж. 1. бр. 863/08 од 27.10.2008. године.

¹³ Одлука Апелационог суда у Нишу, Гж. 1. бр. 1070/10

ком спора више пута прецизира поднесцима, обично након давања налаза и мишљења од стране вештака.

Приликом одлучивања о трошковима поступка у тим случајевима, судови различито поступају. Према становишту Апелационог суда у Новом Саду које је заузето на седници Грађанског и Одељења за радне спорове од 16.06.2010. године, "када један пуномоћник заступа више тужилаца – обичних супарничара, код обрачуна се врши увећање од 50% за другу и сваку наредну странку, а највише до троструког износа, али не на основицу коју чини збир досуђених износа, већ на основицу коју чини износ који се добија када се тај збир подели са бројем тужилаца". Према другом становишту, које се може уочити у неким одлукама, код обрачуна трошкова у овим ситуацијама као основица се узима укупан збир свих појединачних захтева, а према трећем становишту као основица се узима првостављени износ првостављеног тужбеног захтева или пак износ највећег тужбеног захтева – све зависи од случаја до случаја. У свим овим случајевима ради се о примени тарифног броја 7 важеће АТ, али овај тарифни број судови примењују на различитој основици.

Када се ради о прецизираном тужбеном захтеву поднеском, у току поступка, у појединим поступцима више пута странке поднеском прецизирају тужбени захтев. Приликом одлучивања о трошковима поступка, у тим ситуацијама поједини судови признају трошкове осим на име написе тужбе и за напис сваког поднеска којим је прецизиран тужбени захтев. Други судови пак признају трошкове за напис тужбе и за напис једног поднеска којим је прецизиран тужбени захтев након вештачења, а постоје и одлуке у којима судови у идентичним ситуацијама признају само трошкове на име написе тужбе јер по становишту ових судова нема основа за признавање трошкова за напис поднеска којим је прецизиран тужбени захтев, када је већ признат трошак за напис тужбе.

Најзад, ваља подсетити судове да приликом поступања у овим споровима имају у виду Закључак Врховног Касационог суда који је усвојен на седници Грађанског одељења 04.10.2010. године да спорове за накнаду штете због повреде на раду или у вези са радом, исплату зараде, накнаде зараде, других примања и потраживања из радног односа, као имовинско-правне спорове суди судија појединац – ако вредност предмета спора не прелази законом прописани лимит, као и на основу споразума странака у смислу чл. 37. Закона о парничном поступку, и да је рок за жалбу против

првостепене пресуде донет у спору из радног односа који је имовинско-правне природе, 15 дана. С тога, првостепени судови немају потребе за ангажовањем судија поротника приликом поступања у овим споровима. На ово се указује јер и поред објављеног Закључка Врховног Касационог суда у Билтену бр. 1/2010 у појединим нижестепеним судовима се и даље наставља са праксом да се ови спорови суде у већу, што повећава трошкове судског поступка.

Осим тога, обзиром на напред наведени закључак Врховног Касационог суда од 04.10.2010. године, сматрамо да постоји потреба за изменом и чл. 468. Закона о парничном поступку по коме се споровима мале вредности не сматрају спорови из радног односа. Наиме, ако изузмемо одредбе напред наведеног члана, не постоји ни један ваљан разлог због чега се у овим случајевима, у споровима који имају карактер спора из радног односа, а чија вредност не прелази законски лимит прописан чл. 467. Закона о парничном поступку, не би примењивале одредбе које се односе на спорове мале вредности. Овако, имајући у виду да је у већини случајева вредност предмета спора испод 5.000,00 динара, имамо привилегован рок за жалбу од 15 дана. Осим тога, када би се на ове спорове примењивале одредбе које се односе на спорове мале вредности, о жалбама на првостепене пресуде у овим споровима одлучивао би Виши суд, како је то прописано чл. 23. Закона о уређењу судова. На овај начин Апелациони судови би се растеретили, а грађани би остваривали ефикаснију правну заштиту.

Уместо закључка

Овај реферат нема за циљ да судовима и свима онима који се баве утврђивањем и заштитом права запослених наметне неки од изнетих ставова или неко од правних схватања, него је превасходно његова сврха да се подстакну сви субјекти који се баве наведеним послом да настоје да се у што краће време изграде истоветни ставови и схватања који би се примењивали у судским поступцима. У овом реферату није било могуће указати на све разлике које постоје, али ће он вероватно пробудити активност других судова и судија да уколико имају сазнања о томе да постоје различите одлуке у идентичним правним ситуацијама, на то укажу и иницирају заузимање правних ставова а све у циљу уједначавања судске праксе и истоветног поступања судова у идентичним ситуацијама, што све води

истом циљу, пружању једнаке, правичне и законите заштите свим грађанима.

Истовремено представља позив запосленима и њиховим послодавцима, односно свим учесницима у закључењу општег колективног уговора, посебних колективних уговора и колективних уговора, те уговоре о раду, да настоје да се ефикасно успостави социјално - економски дијалог, развије узајамно поверење и да се у најкраћем могућем року што прецизније утврде права, обавезе и одговорности запослених и послодаваца, уважавајући подједнако интересе свих нарочито у условима када нема кривице на страни запослених, а постоје објективни разлози на страни послодаваца због којих се често пута не може одвијати процес рада, односно због којих често долази до прекида тог процеса или до немогућности успостављања процеса рада у дужем временском периоду. Да при томе имају у виду стандарде међународних конвенција, и других прописа међународног права који се односе на потребе радника и њихових породица и на економске факторе у смислу подстицаја даљег економског развоја и подизања запослености на вишем нивоу. У том погледу јесте од значаја вођење статистике о раду послодаваца и сваке друге евиденције у вези са стањем пословања, односно са платежном способношћу и факторима који доводе до смањења обима посла или прекида процеса рада и упознавање запослених са том евиденцијом.

Слађана Ђуричковић,
судија Апелационог суда у Нишу

НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ И МЕРЕ ПОРОДИЧНОПРАВНЕ ЗАШТИТЕ Члан 197. и члан 198. ПЗ

Насиље у породици представља сваки облик кршења основних људских права члана породице, а право сваког човека подразумева право на живот без насиља у јавној и приватној сфери. Насиље оставља дуготрајне и тешко излечиве последице будући да се њима угрожава физички, психички и друштвени интегритет.

Доношењем Породичног закона од 01.07.2005. године, уз одговарајућу кривичноправну регулативу, заокружен је систем правне заштите од насиља у породици.

Према одредби чл. 197. ст. 1. наведеног закона, насиље у породици, у смислу овог закона, јесте понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице.

Насиље у породици може имати различите форме као што су физичко, психичко, економско и сексуално насиље. Такође је важно поменути пасивно, духовно и интелектуално злостављање. Између ових појавних облика тешко је повући јасну разлику јер се у већини случајева жртве насиља суочавају са вишеструким облицима насиља од стране насилника.

Физичко насиље подразумева насиље које за последицу има наношење лаких или тешких телесних повреда. Неки од примера да би препознали физичко насиље су: гурање, ударање, шамарање, ударање различитим предметима, чупање за косу, угризи, коришћење оружја, закључавање у просторији.

Психичко насиље подразумева различите облике застрашивања, коришћење погрдних имена, уцене и манипулације којима се жртва насиља држи у страху и самим тим у краткотрајној или дуготрајној потчињености и зависности.

Наиме, жртва осећа да се њено психичко па и опште здравствено стање мења али није у стању да препозна шта јој се дешава, чиме је то насилник злоставља.

Често жртве психичког насиља нису никада физички злостављане, али код њих је ипак присутно стално осећање страха и губитка идентитета као последица дуготрајног психичког малтретирања.

Примери психичког насиља могу бити: исмевање у различитим ситуацијама, исмевање или нападање најважнијих вредности, веровања, религије, расе, порекла, стално критиковање, називањем погрдним именима, викање, вређање фамилије, пријатеља, одбијање да се излази у друштво заједно са партнером (жртвом насиља) оптуживање партнера за превару за коју је насилник умислио да је партнер учинио или да је чини.

Економско насиље, као и други облици насиља, има своје форме које се одражавају у претњама или ускраћивању средстава за живот, или забрану рада од стране партнера. Оно се најчешће испољава као контролисање кућног буџета, контролисање жртвине плате, одређивање износа новца само за основне сврхе, присиљавање жртве да моли за новац, захтевање од жртве да прави детаљни опис потрошње новца, сакривање заједничке уштеђевине од жртве, продаја имовине или потрошња новца без жртвиног пристанка, продаја заједничке имовине, трошење новца на пороке (коцка, алкохол, дрога).

Сексуално насиље подразумева примену физичког облика насиља са циљем понижења или довођења у завистан положај жртве у њеном физичком, психичком и моралном погледу. Примери сексуалног насиља су силовање, разне врсте физичких напада сексуалне природе, принуда на сексуални однос.

Нема дилеме да је жена најчешћи објект насиља али никако и једини.

Насиље над децом је честа појава. Идилични надзори о породичној урођеној љубави и бризи родитеља према деци често су врло далеко од стварности и начела о посебној друштвеној заштити деце. Данас се све више срећемо са породицама у којима су односи поремећени и нескладни. Деца због своје рањиве доби постају најугроженији субјект. Због природе родитељског односа надређености и зависности деце од њих, када родитељи затаје, жртве су њихова деца. У пракси се срећемо са ситуацијама

да одрасли мушкарци и жене који злостављају одрасле злостављају и своју децу. Девојчице чији очеви злостављају њихове мајке су у већини случајева жртве својих очева. Деца могу бити физички злостављена па чак и убијена. Овакви примери су ретки али ипак постоје.

Један од основних мотива који наводи родитеље на овако стравичан чин је сукоб између родитеља, болести и неке аномалије детета, нежељена деца, било брачна или ванбрачна и психички поремећај једног од родитеља.

Сексуално злостављање деце може укључити полни однос, миловање, орални или анални секс или излагање деце порнографском материјалу.

Сексуално злостављање деце према истраживањима стручњака који се баве овом проблематиком почиње у узрасту деце од 4-8 година. Злостављач не користи увек силу већ наговарање, претње и поткупљивање. Истраживања су показала и то да се овакав облик насиља чешће појављује у породицама са маћехом и очухом и породицама са једним родитељем. То може указивати да се сексуално злостављање деце јавља у оним породицама где постоји неслагање, разводи или небиолошки родитељи. Међутим, не искључује се да се овај облик насиља над дететом јавља и у породицама са оба родитеља и у том случају битну улогу за заштиту детета има мајка.

Као посебан облик насиља над децом сматра се запостављање, напуштање деце и физичко кажњавање. Тешке последице остављају вербални конфликти и емоционални неспоразуми које мало дете још не разуме, али је због тих сукоба њему ускраћено оно битно за психички развој а то су родитељска љубав и пажња. Овакви примери су чести код родитеља који су заокупљени својим пословима и проблемима. Наведени примери насиља над децом су још увек најчешћи облици насиља поготову у породицама у којима је присутан алкохолизам и други пороци.

Међутим, и чињеница да дете иако само није изложено насиљу, али присуствује насилничком понашању према другим члановима своје породице за које је емотивно везано и због чега дете трпи трауматске последице, представља насиље у породици.

Значајна карактеристика насиља над женом и дететом је његова дуготрајност. Жртве, као да се мире са својом улогом јер слабо и нерадо комуницирају са спољним светом полицијом и другим органима друштвене контроле. Без обзира на насиље којим су изложене жене спремне су да и надаље

остану у таквој породици и то због безразложног осећања мање вредности, материјалне зависности, из уверења да ће се насилник променити, због економске зависности не само њене већ и заједничке деце од супружника. Жене жртве осећају безнадежност, беспомоћност, остављеност, депресију, тешку изолацију, одговорност, низак осећај самопоштовања, неспособност. Упркос насиљу и немогућној заједници многе жене сматрају да је детету потребан отац чак иако је насилан. На многе жене се врши притисак конзервативне породице и средине у којој се не прихвата развод ни под којим условима.

Осим жена и деце и старије и немоћне особе могу бити изложене насиљу у породици. На подручју Апелационог суда Ниш није занемарљива појава физичког насиља над родитељима, који су стари, болесни и изнемогли, а најчешћи облик је физичко насиље праћено повредама.

Старије и немоћне особе имају понешто заједничко, али категорије нису изједначене. Немоћна особа је она која нема могућности одбране у опасности, која нема могућности пуне заштите властитог интегритета, која услед неког хендикепа има потешкоћа при остваривању властите егзистенције, права, дужности и уопште свој социјални и индивидуални статус.

Старије особе могу бити објекти истих облика насиља као и деца односно жене. Међутим, уз то, они су веома често и објект финансијских манипулација особа које би се о њима требало да брину јер за разлику од осталих категорија често располажу одређеним материјалним средствима.¹

Насиље над немоћним лицима се манифестује у свим облицима насиља али најчешће као занемаривање (недавањем хране, воде, неодржавање хигијене), јер они који су дужни да се о таквим особама старају осећају те своје обавезе као терет.

Насиље над старијим особама углавном се манифестује у психичком насиљу у виду вербалних претњи и називању погрдним именима. Веома је присутно и економско насиље као што је злоупотреба поверења, крађа имовине, притисак да се имовина којом располаже жртва било којом правном радњом пренесе на насилника, фалсификовање тестаментa, занемаривање и запуштање, одузимање примљене пензије наводним потребама отплате рачуна.

¹ 1 Гж. бр. 2. бр. 268/10.

Старије особе доживљавају насиље из више разлога. Породица и њих сматра непотребним, теретом који више није у могућности економски да привређује.

Не може се пренебрећи и чињеница да су и одрасли мушкарци изложени насиљу у породици. Ређе је то физичко насиље које иначе предузимају одрасли чланови породичне заједнице (чешће синови), а чешће психолошко које се манифестује углавном у сталном пребацивању, неспособности жртве да породици омогући боље услове живота, недовољно стицање зараде, притисак да без обзира на његову немогућност побољшања економске ситуације, омогући породици бољи стандард, непрекидни притисак у вези давања новца кога нема довољно или га уопште нема игнорисање породице због тога пре свега супруге а затим и деце (која су по правилу одрасла) који га безразложно осуђују због тешког начина живота или сиромаштва, са њим не разговарају, непрекидно га нападају што доводи до великих конфликта унутар породице. Такав притисак код одраслог мушкарца-оца породице изазива осећај кривице али и друге психоматске последице. Осећа се непотребним и због тога осећа потребу да се удаљи из породице те постоји пример да се је жртва таквог породичног насиља обрати неком Центру да буде смештена у сигурну кућу. Иначе, у судској пракси, Апелационог суда у Нишу до сада се није појавио ни један овакав случај.

Не може се пренебрећи и чињеница да се жртве насиља ретко обраћају за помоћ било којој државној институцији, јавној служби или невладиној организацији, у томе из очигледно спречава патријархално васпитање, да све што се дешава у породици мора да остане у оквиру породице, затим, због предрасуда да је то што им се дешава велика срамота.

Деца, жртве насиља поготову, ретко пријављују да су злостављана. Разлог томе је да дете осећа да оно што му се дешава није у реду али то не уме да именује. Мисли да је у свом искуству усамљено и боји се реаговања средине у којој живи. Уплашено је јер не зна ком одраслом да верује. До овог сазнања дошла су стручна лица из области социологије, психологије, криминологије и правне науке.

У судској пракси најчешће се срећемо са физичким насиљем деце и жена али и немоћних и старих особа и такву врсту насиља је лако препознати и утврдити јер је оно видљиво. Тако се у пракси срећемо и са психичким насиљем, до сада најчешће над женама и децом али и над немоћним и старим

особама. Пример: у предмету тужиоца Центра за социјални рад против туженог Н.Н., инициран је поступак да се утврди да је тужени починио насиље у породици над мал. сином, који је након развода додељен оцу на самостално вршење родитељског права на тај начин што је мал. дете, које је, иначе, дете са посебним потребама, ударао песницама у главу и упућивао му изразе који указују на позив на сексуални однос. Истовремено је тражено и лишење родитељског права. Основни суд је пресудом усвојио захтев тужиоца, а Апелациони суд је одбио жалбу туженог и потврдио првостепену пресуду.² Пример психичког злостављања детета је тужба поднета од стране оца мал. детета над којим, након развода самостално родитељско право врши мајка, тражећи да се утврди да су тужена, као мајка и њен брат а ујак детета, са којим мал. дете и његова мајка живе у истом домаћинству, починили насиље у породици на тај начин што су мал. детету забрањивали да контактира са својим оцем и онемогућавали мал. детету јављање на телефонске позиве оца. Првостепени суд је усвојио захтев према мајци а одбио према ујаку налазећи да ујак није извршио насиље у породици. Апелациони суд је потврдио део пресуде према мајци а преиначио према ујаку тако што је усвојио захтев и у односу на њега налазећи да је и он сродник и насилник.³

У предмету по тужби тужиље Д. Ж. којом је тражено да се утврди да је тужени њен син извршио насиље у породици и угрозио спокојство и телесни интегритет тако што је почев од 1999. године физички и психички малтретирао и злостављао тужиљу, а затим тукао и чупао косу због чега је смештена у сигурну кућу где се и данас налази. Првостепеном пресудом усвојен је захтев и туженом изречена мера заштите од насиља забраном даљег узнемиравања и приближавања тужиљи на удаљености од 50 метара и иселење из породичне куће родитеља у селу за време од годину дана.

У судској пракси се срећемо и са појавом да је мајка насилник, да злоставља децу тако што их физички малтретира, туче ради дисциплиновања и кажњава на тај начин што им не даје храну, најчешће детету из претходне брачне⁴ или ванбрачне заједнице.⁵

² Гж2. бр. 225/11

³ Гж. 2. бр. 206/10

⁴ Гж. 2. бр. 266/10

⁵ Гж2. бр. 14/10

С тога сваки вид испољавања насиља представља ваљан правни основ за пружање породично правне заштите од насиља у породици.

У поступку за заштиту од насиља у породици суд је у обавези да испита и утврди да ли је и како насиље испољено. Без обзира о ком облику насиља се ради суд мора да утврди да ли је конкретно понашање лица за које се тврди да је извршилац насиља, које се састоји у извршењу одређених радњи или пропуштању (нечињењу), заиста испољено и да, затим, квалификује то понашање. Облици насиља као што су наношење или покушај наношења телесне повреде, изазивања страха претњом убиством или наношењем телесне повреде члану породице или њеном блиском лицу, присиљавање на сексуални однос, навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14-у годину живота или немоћним лицем, ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима (чл. 197. ст. 2. тачка 1, 2, 3, 4, 5) су видљиви и суд нема претешки задатак да их идентификује. Међутим, када су у питању дрско, безобзирно и злонамерно понашање (чл. 197. ст. 2. тачка 6. ПЗ) задатак суда је веома сложен јер треба пре свега да утврди да ли је конкретна радња заиста предузета и да оцени да ли се предузета радња односно испољено понашање може сматрати дрским, безобзирним и злонамерним понашањем, с обзиром на то у чему се радња односно понашање састоји, шта је циљ радње и какве је непосредне последице изазвала у односу на лице које тврди или за које се тврди да је жртва насиља. Затим је суд дужан да, користећи објективна мерила и узимајући у обзир све специфичне објективне и субјективне околности конкретног случаја, утврди да ли је конкретна радња односно понашање такво да се може сматрати дрским, безобзирним и злонамерним понашањем.

Ради правилног утврђења да ли се конкретно понашање може сматрати дрским, безобзирним и злонамерним понашањем суд мора имати у виду чињеницу да свако понашање које одступа од стандарда "нормалног" понашања у опхођењу и комуникацији са члановима породице може се квалификовати као насиље у породици.

Приликом квалификације одређивања понашања као насиља у породици треба имати у виду пре свега да је испољавање насиља према деци један од разлога за лишење родитељског права, као најтежа породична правна санкција, која се изриче родитељима ради заштите детета.

Према чл. 81. ПЗ родитељ ће бити лишен родитељског права ако злоупотребава права или грубо занемарује дужности из садржине родитељског права, што поред осталог укључује: физичко, сексуално или емоционалног злостављање детета. Одредбама Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања од 31.08.2005. године, који је усвојила Влада Републике Србије, дефинисани су разноврсни облици злостављања и занемаривања деце (злоупотреба или злостављање детета, физичко злостављање детета, сексуална злоупотреба детета, емоционална злоупотреба детета и др.) сагласно критеријумима Светске здравствене организације.

Покретање поступка за лишење родитељског права због испољеног насиља родитеља према детету не искључује могућност да због истог акта насиља према родитељу буде изречена и одговарајућа мера заштите детета од насиља. То значи да уз захтев за лишење родитељског права над дететом може бити истакнут и захтев за одређивање мере заштите детета од насиља у породици против тог родитеља ако је то потребно ради заштите детета. Уколико су испуњени законски услови, суд ће донети одлуку о лишењу родитељског права и одлуку којом одређује једну или више мера заштите детета од насиља у породици. Ове одлуке суд може донети и по службеној дужности кад се води поступак у појединим брачним парницама и парницама из односа родитеља и деце.

Према одредби чл. 197. ст. 3. ПЗ члановима породице у смислу ст. 1. овог Закона сматрају се супружници или бивши супружници, деца, родитељи и остали крвни сродници те лица у тазбинском или адоптивном сродству, односно лица које везује хранитељство, лица која или су живела у истом породичном домаћинству, ванбрачни партнери или бивши ванбрачни партнери, лица која су међусобно била или су још увек у емотивној или сексуалној вези односно која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено, иако никада нису живели у истом породичном домаћинству. Дакле, наведена лица су титулари права на породично правну заштиту од насиља у породици. Приликом одређивања круга лица којима припада право на породично правну заштиту од насиља у породици Породичним законом је омогућена заштита и лицима међу којима не постоји било какав породично правни однос, какав је случај са лицима у емотивној вези који не живе нити су живела заједно и лицима која имају заједничко дете или је дете на путу да буде рођено. Проширењем појма "члан породице" наведеном одредбом Породичног закона омогућена је заштита

не само лицима које повезује "класичан" природни однос већ и особама које су у "квазипородичним" односима које могу бити изложене насилничком понашању.

Одредбом чл. 198. ст. 12. ПЗ прописано је да против члана породице који врши насиље суд може одредити једну или више мера заштите од насиља у породици, којом се привремено забрањује или ограничава одржавање личних односа са другим члановима породице.

Суштина мера породичноправне заштите од насиља у породици састоји се у ограничењу или привременој забрани одржавања личних односа насилника са жртвом насиља. Полази се од тога да је извршено породично насиље, без обзира на интензитет и облик испољавања, довољан разлог за изрицање ових мера и да је привремена забрана контаката једини начин да се предупреди ново насиље.

Судска пракса је показала да породично насиље има узлазну линију у погледу облика испољавања и последица које изазива, те је због тога неопходно изрећи меру заштите онда када насиље још увек није прерасло у тежи облик. Изрицање мера заштите од породичног насиља има места и у периоду тзв. примирја, јер је пракса такође, показала да након фазе примирја у којој се насилник искрено каје и обећава да ће се променити наступа фаза гомилања беса која после извесног времена кулминира и прераста у ерупцију насилничког понашања.

У чл. 198. ст. 2. ПЗ предвиђено је пет посебних мера заштите: издавање налога за иселење из породичног стана или куће без обзира на право својине односно закупа непокретности, издавање налога за уселење у породични стан или кућу без обзира на право својине односно закупа непокретности, забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености, забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице и забрана даљег узнемиравања члана породице.

Сврха заштитних породичноправних мера јесте да се њиховом применом спречи поновно извршење насиља у породици, да се обезбеди нужна заштита физичког и психичког интегритета, здравља и личне безбедности члана породице који је изложен насиљу као и да се отклоне околности које погодују или подстичу понављање насиља односно извршење других видова насиља.

Одредбама Породичног закона није предвиђено ограничење у погледу броја мера које се могу тражити, односно одредити, већ оне могу бити комбиноване прилагођене околностима конкретног случаја.

У погледу налога за исељење из породичног стана, односно куће и налога за усељење изричито је предвиђено да ове мере могу бити изречене независно од права својине односно закупа на стану односно кући, што подразумева да ове мере могу бити издате и кад је стан односно куће у искључивој својини насилника. Налог да се извршилац исели из породичног стана не лишава га права својине на тој непокретности већ само умањује круг његових својинских овлашћења. Овај налог за исељење само онемогућава да извршилац насиља и даље станује у породичном дому јер је својим насилничким понашањем угрозио живот, здравље и спокојство другог члана. У ситуацији када постоји реална опасност да ће се насиље поновити оправдано је да се извршиоцу насиља привремено ускрати право становања у породичном стану јер такво ограничење оправдава интерес заштите жртве насиља.

Налог за усељење у породични стан, односно кућу, може се издати само против туженог који је извршилац насиља са циљем да се омогући жртви насиља усељење у стан односно кућу.

Мера заштите од насиља у породици може се састојати и у налогу туженом да се уздржи од приближавања жртви насиља на одређеној удаљености, као и у налогу да се насилник уздржи од приступања у простор око места становања или места рада жртве насиља која је у спору тужилац.⁶

Приликом изрицања ове мере суд мора утврдити удаљеност испод које се извршилац насиља у породици несме приближити жртви. Колика ће бити та удаљеност, одређује суд, имајући у виду низ околности: где се налази место пребивалишта или место рада извршиоца насиља и жртве, да ли се ради о градском, предградском или сеоском подручју на коме су извршилац и жртва настањени.

Примера ради истиче се пресуда којом је изречена заштита од насиља у породици забраном даљег узнемиравања и приближавања тужиљи на удаљености од 500 метара од места њеног становања. Међутим, из доказа у списима предмета произилази да је место рада туженог на 50 метара од

6 Гж2. бр. 21/11

места становања тужиље. С тога је Апелациони суд преиначио првостепену пресуду изрицањем мере заштите од насиља у породици забраном даљег узнемиравања и приближавања тужили на удаљености мањој од 50 метара од места становања тужиље и исељења из родитељске куће.⁷

Забрана даљег узнемиравања члана породице је најблажа мера заштите која се састоји у налогу туженом да се уздржи од даљег узнемиравања члана породице, што подразумева да се уздржи од сваког понашања које према законској дефиницији представља акт испољавања насиља. Ова заштитна мера може бити одређена и као једина мера заштите, али се она редовно комбинује са другим заштитним мерама као пратећа мера. Ово јер је сврха заштитне мере да се спречи даље испољавање насиља према члану породице. Пошто начини узнемиравања жртве насиља могу бити веома разноврсни то је немогуће унапред одредити које су то све радње односно понашања чије би предузимање представљало акт узнемиравања жртве насиља. Уколико би се у судској одлуци забрана узнемиравања члана породице прецизирала навођењем само извршеног или извршених видова насиља, домети ове заштитне мере били сужени. Због тога у одлуци није потребно посебно наводити видове испољавања насиља на које се мера односи, већ извршиоцу насиља треба забранити свако даље узнемиравање жртве и наложити да се док траје мера забране уздржава од сваког дрског, злонамерног и безобзирног понашања којим угрожава телесни интегритет жртве, душевно здравље или спокојство.

Коју ће меру заштите суд одредити зависи од тога који је вид насиља испољен и како је дошло до угрожавања, телесног, психичког интегритета жртве, какве су животне прилике жртве и извршиоца насиља, који је степен опасности од даљег испољавања насиља. Приликом утврђивања постојања насиља било ког облика потребна је нулта толеранција суда да би могао правилно да сагледа и утврди постојање насиља и облик истог.

Ваља напоменути да је Апелациони суд у Нишу у 2010. години, поступао у 11 предмета ради утврђивања насиља у породици и изрицања мере заштите док је до 31.08.2011. године, поступао у 6 предмета. Од тог укупног броја поступао је у 9 предмета по тужбама жена које су тражиле утврђивање насиља у породици због физичког и психичког злостављања

⁷ Гж. 2. бр. 213/10

са предлогом за изрицање мера заштите из чл. 198. ПЗ. Иначе у свим предметима у којима су жртве насиља супруге или бивше супруге, ванбрачне партнерке или бивше ванбрачне партнерке, као жртве насиља појављују се и њихова деца. У овим предметима изречена је мера заштите издавања налога за исељење из породичног стана или куће и забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености као и забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице.⁸ Апелациони суд је поступао у 2 предмета по тужби родитеља-мајке због физичког злостављања детета, а у једном предмету од стране оца због физичког злостављања детета од стране мајке. У овим предметима изречена је мера заштите исељења насилника из стана и забрана приближавања детету на одређеној удаљености као и забрана приступа у простор око места становања детета и места где похађа школу.⁹ Такође је поступано у 2 предмета по тужби супруга и бившег супруга против супруге и бивше супруге због насиља у породици због вређања, дрског, безобзирног и злонамерног понашања тужене. У конкретном случају изречена је мера забрана приближавања на одређеној удаљености забрана приступа у простор око места становања и места рада и забрана даљег узнемиравања члана породице.¹⁰ Апелациони суд у Нишу поступао је и у три предмета ради злостављања у породици по тужбама родитеља и то у једном предмету по тужби коју је поднео отац против сина-насилника, а у друга два случаја по тужби мајке, такође, против сина. Родитељи су физички и психички били злостављани те је насилницима изречена мера заштите од насиља у породици издавање налога за исељење из породичног стана и забрана приближавања члану породице на одређеној удаљености као и забрана приступа у простор око места становања жртве.¹¹

Потребно је истаћи, с обзиром на предње, и то да приликом одређивања мера заштите од насиља у породици нужно је да суд има у виду њихов заједнички циљ, сврху сваке појединачне мере и околности у којима ће свака појединачна мера бити испуњена.

⁸ Гж. 2. бр. 25/10

⁹ Гж. 2. бр. 118/10

¹⁰ Гж. 2. бр. 229/10

¹¹ Гж. 2. бр. 225/11

С тога је ради спречавања даљег испољавања насиља према члану породице, путем мера породичноправне заштите, неопходно да се кумулативно одреди више мера, а често и све законом предвиђене мере а ради потпуног остваривања заштите од породичног насиља.

Литература:

1. Н. Петрушић, С. Константиновић-Вилић: Породичноправна заштита од насиља у породици у правосудној пракси у Србији
2. М. Ајдуковић: Одређивање и облици насиља у породици
3. С. Константиновић-Вилић: Предрасуде и стереотипи о насиљу у породици
4. З. Поњавић: Породично право
5. В. Николић Ристановић: Породично насиље у Србији
6. М. Лукић: Криминолошка анализа насиља у породици
7. М. Млађеновић: Увод о предрасудама, жене за живот без насиља
8. З. Мршевић: Правни аспект структуралних узрока насиља
9. М. Ајдуковић, Г. Павлековић: Насиље над женом у обитељи
10. В. Николић-Ристановић: Насиље у браку, од жртве до затворенице, правом против насиља у породици
11. Н. Петрушић: Људска права за жене
12. Н. Рот: Основи социјалне психологије
13. Т. Игњатовић: Насиље у партнерском односу и у породици
14. М. Драшкић: Породично право и права детета
15. М. Петрушић: Процесни положај детета у поступку породичноправне заштите од насиља у породици
16. И. Стевановић: Деца као жртве породичног насиља
17. Н. Жегарац, Ђ. Стакић: Ударац по души
18. Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију: Правна заштита од насиља
19. Аутономни женски центар Београд: Живот без страха
20. Модел превентивне породичноправне заштите од насиља у породици
21. С. Константиновић-Вилић: Водич кроз систем породичноправне заштите од насиља у породици.